

《民事訴訟法教程》

第一卷

總論與訴訟前提

（法律課程三年級教材）

葡文原者：Cândida da Silva Antunes Pires

中文翻譯：馮文莊

一九九八／九九學年度中文初稿

二零零二／二零零三年度郭健雄、邱庭彪修訂

二零一零年邱庭彪再修訂

目錄

入門概念

第一編

審判權（司法管轄）、程序、程序法及訴之概念之界定

第一章

審判權（司法管轄）、程序及程序法

1. 審判權與審判職能

1.1. 作為國家職能之審判職能。公訴公正制度與私訴公正制度之演進。

1.2. 審判權與其不同分支：

通常審判權及特別審判權。民事或普通審判權、刑事審判權及行政審判權

1.3. 規範行使審判職能之原則

2. 民事審判之一般原理

2.1. 作為行使該審判權之方法之民事訴訟

2.2. 民事訴訟之結構、標的及目的

2.3. 程序一詞之多種意思

3. 程序法

3.1. 程序法及其各個不同之部門

3.2. 民事（訴訟）程序法的首個概念

第二章

訴

4. 司法訴權

4.1. 概念

4.2. 法律性質

4.3. 有權無訴

5. 訴之法定分類

6. 依形式標準對訴之分類

6.1. 具特別程序之訴

7. 保全程序

7.1. 保全程序之性質。

依目的為標準，這種程序與訴之分別

7.2. 保全程序之結構

7.3. 保全程序之分類

第二部分

訴訟（程序）法律理論

第一章

民事訴訟法

8. 民事訴訟法之概念

9. 民事訴法之特點，程序法律部門及公法部門

- 10. 民事訴訟法之重要性
 - 10.1. 理論重要性
 - 10.2. 實踐重要性
- 11. 《民事訴訟法典》規範之解釋及填充
 - 11.1 訴訟程序法律之解釋
 - 11.2. 程序法律漏洞之填補
- 12. 訴訟法律在時間上之適用
 - 12.1. 對問題之衡量
 - 12.2. 適用之一般理論
 - 12.3. 特別適用：
- 13. 程序法在空間之適用
 - 13.1 問題之提出
 - 13.2. 法院地法原則
 - 13.3. 特別情況

第二章

民事訴訟法之淵源及近似之內容

- 14. 葡萄牙民事訴訟之歷史形成
 - 14.1. 這個內容之重要性
 - 14.2. 認識葡萄牙《民事訴訟法典》之淵源

第三部分

訴訟關係理論

第一章

基本概念

- 15. 訴訟程序中之訴訟關係其性質及特性
- 16. 組成訴訟關係結構之元素
- 17. 訴訟法律關係之生命：訴訟程序之展開與發展，稍後論述。

第二章

訴訟前提

- 18 訴訟前提之概念
- 19. 與同類概念之分別
 - 19.1. 訴訟前提與訴之要件
 - 19.2. 訴訟前提與訴訟行為之前提
 - 19.3. 訴訟前提及程序存在之條件及其有效性

第三章

訴訟法律關係之結構

第一章

訴訟法律關係之主體

- 20. 當事人

- 20.1. 當事人之概念
- 20.2. 分類：主要當事人及輔助當事人
- 21. 關於當事人之訴訟前提
- 21.1. 當事人能力
- 21.2. 訴訟能力
- 21.3. 當事人之正當性
- 21.4. 強制法院代理
- 21.5. 訴之利益或起訴利益
- 22. 法院
- 23. 司法組織
- 23.1. 作為主權機關之法院
- 23.2. 管理司法之原則
- 23.3. 法院之組織
- 24. 管轄權
- 24.1. 審判權及管轄權
- 24.2. 管轄權前提之理由所在
- 24.3. 新《民事訴訟法典》在管轄權上之分類
- 24.4. 管轄權之延伸
- 24.5. 管轄權規則之變更
- 24.6. 無管轄權
- 24.7. 管轄之衝突

訴訟程序行為

總論

訴訟程序行為

- 25. 建立程序之理由
- 26. 訴訟行為之概念及一般特性
- 26.1 概念
- 26.2 一般特性
- 27. 訴訟行為之分類
- 28. 訴訟行為之要件
- 28.1. 作出訴訟行為之形式
- 28.2. 訴訟行為之時間，概述及例外
- 28.3. 訴訟行為之地點
- 28.4. 訴訟行為之主體
- 29. 特別行為
- 30. 程序行為之無效
- 30.1. 引言
- 30.2. 概念

入門概念

第一編

審判權（司法管轄）、程序、程序法及訴之概念之界定

第一章

審判權（司法管轄）、程序及程序法

1. 審判權與審判職能

1.1. 作為國家職能之審判職能。公訴公正制度與私訴公正制度之演進。

在遠古時代是容許權利人憑自己武力、權威而實際恢復行使自己之權利，用自己雙手主持公正，作出自保，針對他人之侵犯，自己採取行動作出反擊的。

倘一權利不獲尊重，無履行一相應之義務時，受害人可循事實途徑用自己方法恢復其權利。此稱為自保。部分學者將其概念與排解糾紛之概念相對照。倘在兩個利益之相對範圍內出現衝突或爭議，可透過爭議人本身之行爲或透過第三個私人之強行決定而解決。

第一種情況帶出兩個期望：其中一個爭議人同意犧牲本身之利益，或強迫犧牲另一人之利益¹。

這種屬原始社會、原始司法組織之現象，在現代法律體系內已完全消失²。

除了極少數情況外，今天是不容許以自己行爲作出公正的³。爲了抵抗對一權利侵犯或威脅之行爲，受害人必須訴諸國家機關，要求法院採取適當措施以恢復有關權利。

澳門特別行政區《基本法》第 36 條規定：

“澳門居民有權訴諸法律，向法院提起訴訟，得到律師的幫助以保護自己的合法權益，以及獲得司法補救。

澳門居民有權對行政部門和行政人員的行爲向法院提起訴訟”。

此爲公訴公正制度：由國家解決在私人間出現之衝突，除了提供更合時及更

¹ 見由 Carnelutti 《Lezioni de Diritto Processuale Civile》，第一卷（再版），Pádua，1930 年。

² 在葡萄牙“任何人不得憑自己本身之武力而要求返還其權利”之原則早見於《菲臘律例匯篇》（第四卷，第 58 編）。

³ 此爲《民事訴訟法典》之入門原則，其中第 2 條之標題爲：自力救濟之禁止，但該條有例外之情況——稍後我們便會知道。

Antunes Varela 教授（在 1992 年 10 月向澳門大學法學院生講課時指出：“《民事訴訟法典》以一個消極為起點：任何人皆不得訴諸武力以實現或保障自身之權利”。

適當之法律保護外，可以獲得比私訴公正制度更為有效及謹慎之結果⁴。

這種保護是透過審判職能之行使而作出的，此為在傳統上由國家負起之三大職能之一，即立法及行政職能以外之另一職能，是為配合國家實踐之目標，由擁有本身權力之機關履行。

在此詳細探討各種職能之分別並不適合，除了存有相當困難外，亦不能在理論上嚴謹訂立彼此的分別。而困難是在於訂定嚴謹之概念，因為在某些方面可能出現概念重疊或界限不清的情況⁵，同一種職能往往由不同性質之機關予以履行。

即使如此，在此我們簡單介紹審判職能之概念及特性：

——透過立法職能國家制定具普遍性及抽象性之法律規範，以管制在法規生效期內出現之各種狀況或關係：屬於將來可能出現之情況。

——透過行政或執行職能，具公權力之實體在法律限制之範圍內及在遵守法律規定之前提下謀求達到其目標——社會之安全及繁榮。在行政職能內，遵守法律係滿足這些利益之一種方法及工具。

——透過審判職能（廣義言之），國家實踐法律，當規範之相對人不遵守規範時，國家則將規範適用於日常生活之事實（已具體發生之事實）。故可以指審判及立法係一種互補活動，這種活動將這種潛能轉為真正之行爲⁶，按照部分學者之理論，屬於國家機關宣示法律意志之活動。

法律體系之有效性、法之具體實踐同國家某一職能（審判職能）有密切聯繫。

審判職能有一個直接目的及一個間接目的，分別是指：

- a) 前者，在實踐法律主體之利益時，由於這些主體受到法律保護，在某個時間內不能在司法途徑以外滿足其利益；
- b) 後者，將法律回復到正常軌道上⁷。

依此意思，審判職能體現在定出（透過一個具有約束力及確定性，並有確定裁判的效力、來自公正或中立機關之一個裁決）對某特定事實狀況作出回應之法律保護方式。

對於這些行使審判職能之機關，法律並非作為一個方法（媒體），以便滿足某些利益。法律本身並不代表一種限制：相反她是審判職能之目的，其組織活動之客體。所針對之目的是確保法之實踐，尊重其所定之命令⁸。

⁴ 值得指出由私訴司法制度過渡到公訴司法制度經過了漫長且漸進之歷史時期。所有制度皆反映出其逐步代替私訴司法制度之努力，同樣情況亦發生在葡萄牙，其過程的描述可見於由 Gama Barros 所著之《十二至十五世紀之葡萄牙公共行政史》。

⁵ 作為典型例子有非訟程序，有學者將其列入行政職務內，而其他人，則視其為審判職務。考慮到這個程序之非常特別之性質，僅載於《民事訴訟法典》第五卷第 15 編內之程序方為非訟程序（第 1206 條及續後數條）。稍後我們將探討這個問題。

⁶ *Jurisdictio* 這個拉丁詞的意思非常廣泛：廣義之意思是適用法律及審理違法行為之權力。狹意是管轄權之同意詞。

⁷ 澳門特別行政區第 9/1999 號法律【司法組織綱要法】內可找到關於法院之規定。

⁸ 按照 Baptista Machado 教授在其著作《*Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*》

有管轄權行使這種主權特性之工作的機關為法院——只要符合某些要件，她使法律的強制力得到實現。

依上文所述，似乎可明確地得出：這些審判機關行使一種替代性、輔助性但公正無私職能。

替代性職能，因為只在人們不和平及自覺地遵守法律時，為了重建法律之效力才採取行動。

在日常生活裏人們通常按照法律的規定，和平守法，但不能排除違反法律規定之可能性，亦由於不能完全預見在解釋法律方面所有之不確定情況，以及有共識地預見解決所有利益衝突之方法，因此，當出現該等情況時，審判權就會介入，或被要求介入。

但審判職能還有輔助性質，作為一個輔助工具，作為法律本身設置之一種方法以便強制法律規定之對象遵守有關規定。

第三方面，應指出審判職能，或更正確言之，行使這種職能之機關之公正無私之特性。這是指這些機關在利益衝突面前是中立的，凌駕衝突之立場之上，不受這種狀況影響，以第三者之身份出現，因此是公正無私、中立、及只為評出道理。

最後，還須指出審判職能之特點：審議原則、程序推動原則，請求原則。審判機關、即法院不會依職權採取主動自己運作起來，僅在應利害方之要求，按照法律賦予法院之權能運作。

此為區分審判職能與行政職能之一個重要層面。然而，正如上文所述，兩者的區分往往十分困難，尤其在實踐上。

1.2. 審判權與其不同分支：

通常審判權及特別審判權。民事或普通審判權、刑事審判權及行政審判權

倘審判在功能上是為了填補或執行實體規範而運行，倘因專門化需要而將法分成不同部門，按照相同的邏輯，在司法方面，應由審判組織之每一個專門部門去處理每一門法律。

為此，審判權具有不同形式之多元性⁹。

首先，須將之區分為通常審判權及專門審判權：前者包括普通或民事審判權、刑事審判權及行政審判權，由於標的不同或事宜不同而受制於不同之審判權。

在該些審判權形式中，民事審判權是總的審判權，即一般審判權，如非明示保留予其他審判權的，則由屬民事審理，這是因為在民事審判權內使用的規範構

（Almedina 出版社，第五版加印，1991 年，第 11 頁）一書中一番簡單但精景之說話：

「在我們日常生活內，每天我們都與法律接觸，因為我們自發地遵守許多法律規範：例如在駕駛車輛，乘坐公共汽車，購物，提出一項申請，尊重他人財產所有權等。但特別是法律生活出現病態之情況時，例如違反法律規定，私人間或私人與公共當局間之爭訟時，我們會更加意識到法律實況，且會聯想到法典及法律、法院、警察及監獄等。這是正常的：正如當我們生病時才會意識到健康之價值一樣」。

⁹見 Anselmo de Castro 教授在參考書目中之教材，第一卷，第 15 頁。

成一個（通用制度），集合了補充適用之訴訟規則，用作補充其他部門審判權的法律規範¹⁰。而民事審判權的目的是為了規範民商法，即私法之審判。

另一方面，刑事及行政審判權是為了規範刑法及行政法。前者的目的是為了調查及證明刑事法律定為犯罪之事實，並適用有關的制裁；後者屬具有本身審級之行政訴訟法院，並依據特殊的訴訟規則去適用行政法規¹¹。

然而值得強調的是審判權之多元化並不妨礙審判職能在其所有的部門法中的統一職能，因為其目的永遠是使實體法律規範適用於具體情況¹²。

因此，我們可以指出在多個部門法內審判職能之特徵：

- （1）有一個由法官組成、有別於其他機關（即使與法院共同運作的檢察院亦然），之一個公正的機關——法院，由其履行審判職能。
- （2）受載於《民事訴訟法典》第 3 條第 1 款內之辯論原則約束，此為該法典其中一個最重要之原則。在程序內該原則構成對當事人平等對待之重要保障。
- （3）起訴主動權之外顯性（相對於審判機關而言）；最後，還有：
- （4）程序本身，是為法院獨立性的保障，亦為在取得一個具有既判力之確定裁判之方法中合符經濟之形式。

簡言之，全部法律部門之審判職能形成一個整體，具有統一之精神及目的。

1.3. 規範行使審判職能之原則

a) 國家專利原則

從上條目所述之內容可得知：當未能自發及和諧地實際適用實體法之規範時，再加上這些規範之對象不自願地履行有關命令時，國家或等同之實體則會透過一個爭議之法律關係以外，擁有特殊權力——容許強制實施法律之專門機關：法院¹³代替擁有受侵害權利之人。

在此體系內，一如我們在上文所述，學理稱之為公訴司法制度，這些權力之專屬性屬於該機關，此為審判職能國家專利之所在¹⁴，而其中不容置疑之優點在於：審判職能為是透過公正司法制止無政府狀態之工具，是對法律主體實施保障及實現社會和平之重要保證。

公訴司法制度原則產生兩個必然後果：

- （1）禁止自力救濟行為；及
- （2）禁止非為國家或等同實體之機關行使審判職能。

¹⁰見前一註腳第 16 頁。

¹¹ 行政審判權由第一審法院負責，而其管轄及運作的規則主要載於十二月二十日第 9/99 號法律第十及十九條、廿三條第六款第四項、第廿七及第三十條。

¹² Manuel Andrade 教授在其《民事訴訟概要》一書（第一及第二版，第 10 頁）清楚解釋：“審判權表面上之分割係基於程序性質，是次要的，因為只是因應實體規範所屬之多個部門而出現”。

¹³ 法院之定義已在其他地方，如「訴訟之公權主體」中提及。見十二月二十日之法律第 9/99 號（司法組織綱要法）第三條。

¹⁴ Antunes Varela 在其《Manual de Processo Civil》一書中（第 4 頁）認為這個用語太過贅。然我們認為應使用這個術語。

對法律文本在這方面之規定作出批評性之分析，現在或是最好時機。

部分學者批評《民事訴訟法典》第 2 條結尾部分之保留（在法律規定之情況及限制範疇內除外），所持之論據為：倘我們將《民法典》第 328 條之規定作一對照，我們立即可知其中不協調之處：從該條文可得知，作為一般規定，可作出自力救濟。且只要不能適時訴諸司法途徑，對於所有權利皆適用，而非僅限於在法律所定之情況下方可為之¹⁵。

然而，似乎這並非一具理由充足之批評。

第 328 條第 1 款規定：「...因不及採用正常之強制方法以避免權利不能實現而有必要採用上述自助行為時」，這種概括性表述方式，並未與「在法律規定之情況及限制範疇內除外」這一表達方式產生矛盾。除了該條文所述之假設情況外，還有其他有關自力救濟之規定，例如民法典第 329 條（正當防衛）及第 331 條（緊急避險）；還有第 1202 條（自力救濟及司法保護）及第 1239 條（自力救濟），鑑於第 328 條之準用，這些例子為例外原則之適用或例子。

在澳門的《民事訴訟法典》第 2 條（自力救濟之禁止）中已然對其作出保留，但並非如此簡單，（自力救濟）須經法院事後作出確認，將該行為轉為由程序法律規定之一個措施，否則自力救濟變成無效¹⁶。

我們可以指出：對主觀狀況作公共保護之原則之例外是法律體系容許人們使用某些私人方法，其可以分類成為：

——預防方法；

——壓制方法。

以確保這些主觀狀況。

在第一種情況下，自助行為，關於主觀狀況之主體之活動，有關在不訴諸司法機關及不犧牲欲謀求之等級較高之利益之情況下，避免侵害該主觀狀況或使其無效用（《民法典》第 328 條）。

不同之情況為正當防衛——體現在對一種現在及違法攻擊行為人或第三人之財產之反應（《民法典》第 329 條）。正當防衛是以壓制方法進行自力救濟之一種方式。

無論自力救濟或正當防衛相對於公訴司法制度原則而言都僅具補充性質，作為審判職能之輔助，故此，其具有例外性質，以及須由司法機關審定其要件。

但不應視這兩類私人保護方法包括所有法律容許私人對主觀狀況之自力救濟之全部方法。

法律規定有其他之情況：《民法典》第 422 條（合同不履行之抗辯）及第 744 條（留置權）。

在勞動法範圍內，作為自助行為之體現還有罷工權。

¹⁵ 除其他學者外，有 Anselmo de Castro 教授，見引述之作品，第一卷，第 19 頁。

¹⁶ 按照法律規定，自力救濟行為之人合法性並不免除行為人要使狀況正規化之情況，倘可能應立即採用正常之強制方法（執行、假扣押、查封等）——見由 Pires de Lima 與 Antunes Varela 合著之《民法典評釋》，第二版，第一卷，第 279 頁。

禁止非國家機關行使審判權之規則並非絕對規則。

首先可以指出：在民訴程序內，可成立一個自願仲裁庭——載於舊《民事訴訟法典》第 1508 條至第 1524 條。

但自願仲裁的標的只可為可處分之權利；就仲裁裁決可向具普通管轄權之上級法院上訴，同常設法庭第一審法官所作判決之上訴一樣，此外，給付判決只可在常設之第一審法院內提起執行之訴。

為此，不可以指我們正面對該原則之一個真正限制，同樣亦不能說仲裁完全規避國家之審判權¹⁷。

b) 合法性原則

我們現在看看合法性原則

屬於一個有在當代所有成文法律體系中普遍存在之一項規則，通常是一個憲法之特有或專屬依據。

這個現代學理十分關注其危機之合法性原則補充了審判職能歸國家專利所有之原則。

其在實踐上有許多體現方式。

(一) 首先，法院不得採取法律規定以外之任何其他保護方法。稍後我們將研究，該些方法之各種類型，以及在訴權方面，法律供私人選擇之司法措施及為利於介紹及學術之掌握而通常分成之各個抽象類別。

(二) 另一方面，只有符合特定客觀要件，訴訟方為可行，即要符合法律所要求之前提。這些條件，一般稱為訴訟前提（將是稍後之學習內容）。因其非常重要，所以欠缺這些前提會產生嚴重之效果，例如妨礙裁判者對產生爭議之實體問題作出審判，因而可能作出初端駁回之批示（《民事訴訟法典》第 394 條）。

(三) 最後，法院在進行司法活動時必須遵守法律。因此，基於其性質，程序法應盡可能具規範性。在開展該些活動時必須遵守程序法預定之步驟，而其基本上載於《民事訴訟法典》內。

但並不限於此：很明顯，法院亦受其認為適用於具體個案之實體法約束。

總而言之，法官之終局裁判正是確證法律預定之結果。

但一如其他規則般，合法性原亦有例外之情況。

稍後我們知道作為這些例外情況最強烈的體現為在自願仲裁事宜方面，倘我們將其與《民法典》第 3 條之規範相聯繫，我們立即知道將依衡平作出裁判擴展普通管轄權（依公允審判）。

稍後我們將述及狹意之合法性之偏差情況。

2. 民事審判之一般原理

2.1. 作為行使該審判權之方法之民事訴訟

民事訴訟法引介無疑是對程序之各個階段作一大綱性描述。

某個權利人，其權利被另一人侵犯，決定訴諸法院以恢復其權利。必須促進

¹⁷ 我們應將之理解為：自願仲裁機關乃由當事人設定以代替國家之審判權之另一個審判權機關。

該機關之活動以達致某特定之期望，因為在私法所包含之法律關係範圍內（倘其中無直接涉及國家或等同實體之高層次之利益，法院不得依職權審理 *nullum iudex sine actore* 無原告則無案——此為羅馬法所宣示之原則）。

向法院申請某特定措施之人稱為原告、起訴人、申請人。他陳述作為其請求之事實及法律狀況，同時提出請求，即指定其欲從法院採取之特定措施（稱為主張）。

繼這促請審判機關展開活動之第一個步驟之後，接著是另一個由審判機關展開之步驟，以查明事實真相及所援引之法律規範是否存在。在此階段內，須聽取另一方當事人，最低限度是可能之另一方當事人之陳述及參與有關訴訟，至於參與之幅度亦存有變化。是給予另一方有防禦之權能，讓其針對原告之主張提出反駁。

倘受害人有起訴權，被訴人（倘他認為並無作出可歸責之違法行為）則應有反駁或防禦權（參閱《民事訴訟法典》第3條第1款，該法規內最重要之一條規範）。

行使這些權利（起訴權及辯護權）後，訴訟法律關係則確定，有兩個方面：原告／法院，以及被告／法院。

一如大部分情況般，每一方所援引之理由與另一方是不協調或有衝突的，通常亦必須借助其他參加以人之合作，此為輔助人（例證人、鑑定人及翻譯），需要舉證及辯論，有法律專業人仕、當事人之委托人，目的調查對案件裁判屬重要之事實，以及將該等事實套入所援引或甚至無援引之法律規定中。法官將就所有這些材料形成其心證，最後作出一個具有約束力之判決，給予或否定所申請之保護措施。

上文之介紹非常簡單，程序之進行，即各參加入行為之連貫性——並非每個行為獨立發揮作用，而是組成一個連串、且緊密連繫之活動。正如 **Castro Mendes** 教授指出：“在程序以外之答辯或聽證並無意思”。

稍後我們將研究程序之各個不同時期，由起訴至終結，整個過程或多或少較長及較複雜。

正是如此出現民事訴訟，意指行為之邏輯及時間連貫性，針對某個目的，按照一個在法律上預定之軌道（往往十分細微）進行。屬於一個邏輯進程，而並非純行為之連貫，屬於有秩序及有目的之行為，為此受制於一個特殊制度，例如之後我們將會探討之、有關無效之內容。

2.2. 民事訴訟之結構、標的及目的

在上文所述之原理向我們介紹了一個民事訴訟程序之結構、標的及目的之初步概念。

我們知道，程序由多個參加入之一系列行為組成，而這些行為應在準確時間內作出，並須遵守法定形式。

但從上述概念中可得知程序之標的是嘗試透過司法解決之、在私法（民事或

商事) 法律關係範圍內之爭訴、案件、利益衝突；透過程序謀求雙重目的——我們在上文已指出：直接及即時之目的——保護實體權利；間接目的是保護法律，使其回復到正常軌道上。

換言之：程序之直接目的為，當法律主體之利益面臨危險，且不能以非司法途徑解決時保護其利益。實踐在法律文本中之法律規範乃間接目的，將這些規範適用於具體個案，實現社會和諧及和平。

2.3. “程序”一詞之多種意思

由上文所述，可引致詞義上之混亂，尤其是在法律、學理及司法判例內使用一詞，甚至亦見於日常用語內。我們先看看：Processo 文首個意思是指為其個目標而互相聯繫¹⁸。

但在程序內不存在任意性，亦無偶然性。無論起訴或隨後由法院、當事人、輔助人（證人、鑑定專家及翻譯）開展之活動，皆必須遵守某些規則——其組合形成民事訴訟法¹⁹。

此可容許推測 Processo 一詞在日常用語中亦使用此意思。

在遠古時代，當程序法相對於實體法無自主性時，Processo 僅指在法院實施、以獲得某措施為目的之一套行為，是指這些行為之形式，其時間順序及程序形式（rito processual），如非今日般，是指系統化規範，當時之意思亦不包括訴訟程序之前提——稍後我們會知道這些前提並非僅指在法庭實施之行為。

就是這個民事程序之概念反映在 1876 年之《民事訴訟法典》及十九世紀初之學理上。

在該時代，一如 Palma Carlas 教授所指出：程序乃純形式之物，仿如為實體法服務之實踐創作。但 Processo 一字亦有其他意思，且更狹義甚至表示為：

(1) Processo，作為司法案之同意詞是這源自羅馬時代。

(2) 或指來自當事人之書面文件，法院之裁判，總之是指組成卷宗之文件（純物質之意思）²⁰。

3. 程序法（Direito Processual）

3.1. 程序法及其各個不同之部門

3.2. 民事（訴訟）程序法的首個概念

從上文可得知：除了實體規範外，還有其他規範集合體——相對於前者具有工具性質：是實踐組成這些規範之工具。

很自然，眾多會涉及多元性，倘我們仍記得關於各個審判權所述之內容，我們可得出程序法之分支：民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法、勞動訴訟法等。

我們可明確地指出：程序法之存在之需要乃源自法律秩序之特徵，尤其該秩

¹⁸ Processo 在字源上是指“前進”，表示向某個方向前進，邁向一個目標。見由 Castro Mendes 著之《民事訴訟法》，1963 年，第 7 頁。

¹⁹ 稍後我們用“訴訟法律”這個術語指這門法律，我們再次強調其理論及實踐重要性。

²⁰ 關於 Processo 一詞之各種意思，Paulo Cunha 著之《宣告之訴之通常程序》之首數頁十分清楚地作出了解釋（供 1939/1940 學年度用之教材），但這部作品今天仍適用。

序本身有欠完整及會被侵犯。作為人類產物之法律秩序，必定是有欠完整，故此引起疑問、威脅及實際之違反行為，此亦成為各門程序法之依據所在。

然而，最主要的一個部門，因為她是私法（民法及商法）之所有規範填補方法，故亦是一套基礎規範，就是民事訴訟法（*Direio Processual Civil*）。

我們暫時指出一個臨時性概念（我們將有機會對其作深入研究）：作為程序法之一個部門法，它是規範民事訴訟程序、其類型、形式及要件之法律規範總和。

按照 *Carnelutti* 之定義，是指訂立民事訴訟之要件及效果之法律規範總和²¹，即規範民事訴訟程序之法律規範總和（*Ugu Rocco*）²²。

——在另一個意思裏，則並非作為一個法律部門，而是作為法律科學之一章或一節，“民事訴訟法之標的是用各種方法及法學原則研究民事訴訟所提供之解決方案”²³。

²¹ 見《*sistema di Dirritti processuale*》（共四卷，具西班牙文譯本），第一卷，第 81 頁。

²² 同上，見總則，第 11 頁。

²³ 見註腳 14 之作品，第 7 頁。

第二章

訴 (Acção)

4. 司法訴權

4.1. 概念

4.2. 法律性質

A 問題之出現及範圍

在現代法學內最具爭議之課題之一是有關訴之問題，關於其真正法律性質及其按照法律之結構²⁴。

此問題並非被視為純程序之問題。相反，研究此問題之法學理論家將訴視為法學之一個主要範疇，無論是作為一般理論問題，或作為歷史問題，或實踐問題，皆是法律工作者感興趣之問題。

可以指出，一個世紀多以來，源自德國之法學從未間斷地研究這個問題，彷彿“已進入一個死胡同，難如脫身”，一如 Lieberman 悲觀主義者所說般。

另一方面，Carnelutti 指出：“從根本上說，訴之問題並非法與程序之問題。程序為法及法為程序”。

但有一種東西是肯定：我們正面對程序法之一個基礎概念——此為同實體法之聯繫點；權利（司法訴權），基於其本身結構及內容，難免同主觀權利有關，保護主觀權利乃行使另一權利之直接目的。

訴權這個詞本身模稜兩可之意思使人對問題之研究更為困難，稍後我們將會知道²⁵。

訴權有許多意思，不單在程序方面之狹義意思，在程序用語方面亦一樣。

現在我們感興趣的，僅是訴權之法律專業意思，依其意思，訴乃一個權利²⁶。

我們已經知道，對實體法所述之私權之保護今日通則是由國家作出保護——她擁有審判權。

國家，在強制施實體法之餘，必須確保對法之遵守，須設立確保對法律遵守之機關。這些機關就是法院。

在民事訴訟程序內，法院並不會自行作為，法院只會在有人要求法院介入之情況下，應促請開展審判活動。

如此，《民事訴訟法典》第 3 條明示規定：“未經一方當事人提出請求，而另一方亦未獲給予機會申辯者，法院不得解決……。”

²⁴ Salvatoris Satta 稱此為“法律科學最艱難之一章”。

²⁵ 見下文 4.2.D 項。

²⁶ 作為權利為權利人所擁有，得到法律體系之保障，權利由兩個元素組成：一個為形式要素——意志之權能；另一個為實體要素——利益，兩者互相補充。

上述條文確立了一個原則——José Alberto dos Reis 教授稱為“當事人處分原則”，Manuel de Andrade 教授稱為“處分原則”*princípio dispositivo*，而 Palma Carlos 教授稱“程序推動原則”*“impulso processual”*

司法機器，並不能自行啟動，必須由當事人啟動及推動；彷彿由他們燃點了導火線。私人可以要求法院解決其涉及之利益衝突，只有當私人行使這個權能後，法院方介入。

正是這個由私人促請審判機關作出活動之權能，稱為訴（*Acção*）；即是促請這種活動之權力。

作為純事實之訴，就體現在此。

但除了純事實之訴外，還有關於其按法律之結構問題，即訴權之法律性質（作為促請法院活動之權利）。

一如我們所強調的，這個問題引起很大爭議。原因何在？

接上文，不難指出箇中爭議之原因，我們可扼要指出：

1. 在民事程序內，需要區分敵對立場之雙方當事人（原告及被告）及一名法官，後者地位高超及中立²⁷。
2. 在程序內，會將實體法與程序法，前者之標的受制於程序，彷彿原材料；後者，規範其審理標的範圍。
3. 在分析基本概念時需要考慮（對解決問題）法律專家可處於不同之地位，但從法官之觀點而言為審判權，而從原告人觀點言之，為提起訴訟（*Acção*）。

倘在程序內有三個人物，則其中兩個擁有對立之利益，另一個全無利益，要得到一個盡可能完整之關於訴權之法律結構之理論，不應忘記第三個層面——供法律專家／研究員研究之程序制度及概念，此非容易之事。

困難及意見分歧亦由此而生。

B. 各種理論

為了使問題清晰，我們將這些理論分成兩大類，古典或稱為傳統學理及現代學理。

I — 古典學理（*Doutrina Clássica*）

羅馬法律學者將訴（作為訴權）與實體權利相識別。

對他們來說，訴並非一個獨立權利，訴乃實體權利之實踐。訴乃運行中之實體權利，處於運動中之權利。一個在被違反時不能使本身發揮實際作用之權利，實叫人難以想象。訴屬於權利之一，其本質之一個附加物²⁸。

這個古典學理，稱為實體法理論（*teoria do direito material*），在德國及意大

²⁷ 一如部分學者所說般，雙方為私利之當事人，而另一方是公正之一方見於 “Zamora Y Castillo”。

²⁸ 一如法國學派之學者 Eduardo Couture（Montevideo 大學之烏拉圭籍教授）所說般：“Le droit casqué et armé en guerre” —— 《Fundamentos del Derecho Procesal》（第二版），第 12 頁，以及《民事訴訟法入門》，第 14 頁。

利受到廣泛支持；部分民法專家，尤其是在葡萄牙之部分學者，採用折衷主義立場：從私法角度言之，訴乃權利之一個方面，與權利相混淆或相識別；從公法、程序法或技術觀點言之，訴乃公共權利。

這個理論，其優點是有綜合性（此為折衷主義之特性），按照部分意大利學理，似乎可指出訴之概念享有一定之相對性。

是否可接受這個理論？答案似乎是否定，主要是考慮到訴訟法律關係之結構及輪廓，相對於實體法律關係，訴訟法律關係享有相對之獨立性。

其中部分的論據：

1. 訴權之標的是在法院開展之活動，實體權利之標的是指由消極主體所作出之積極或消極給付。

倘，訴權為實體權利，在受到侵犯之情況下，原告應直接向被告人行使該權利，而非向國家，一如在現實所見。

透過利害關係人所促請之審判機關之活動，法院必須確保實體權利之保護。這是因為，國家有義務進行立法及保證對法律之遵守。

2. 另一方面，倘訴權為實體權利，如何解釋提起無根據之訴？在某些情況下有訴——（其中正在行使訴權），但無所主張之實體權利。

在這些因實體權利不存在，故訴之理由不成立之情況下，可能行使一個不存在之權利：訴權與欲主張之實體權利混淆。

3. 此外，還有無訴之權利，一如《民事訴訟法典》第 1 條所述：“除法律另有規定外，就所有權利均有適當之訴訟，……。”

在此情況下，雖然權利得到實體法之（法律）規範承認，但不能透過法院強行實行。

作為其中之例子我們可以指《民法典》第 396 條所規定之情況；如自然之債並未為債權人設置之一訴，然以一種法律聯繫為前提，以一個公平義務為基礎，而非純道德義務。

在此情況下，倘債務人自願及自發地履行義務，不能於後來要求返還已支付之金額；倘債務人不履行，債權人不能循法院要求履行，因這種訴一開始理由已經不成立。

4. 同時，倘認為訴僅是實體權利之實踐，而事實就是該權利可和諧及自發地實踐，且無需行使訴權？
5. 另一個依據：訴權並不一定僅由實體權利擁有人享有。法律可承認同在法院所主張之關係有聯繫之其他關係主體，甚至相對於檢察院而言亦然，例如《民法典》第 1665 條。

似乎不難指出訴權及實體權利乃不可混淆之權利。訴並非實體權利之元素。訴權有其本身之獨立性：一如現代學理所主張般。

II—現代學理（doutrinas modernas）

此理論包含許多細分之理論：尤其是，將訴，視為一個“抽象之行爲權利”；視訴為針對他方之一個形成權；最後，將訴，視為要求國家保護之一個具體權利。

A) 將訴，視為為一個“抽象之行爲權利”之理論廣泛地受到意大利訴訟法學家之支持，例 Ugo Rocco，葡萄牙學者有 José Alberto dos Reis 教授。

按照這兩位學者之解釋，訴乃一個抽象權利。即無需有一個具體實體權利存在，且與其無任何聯繫。要成為訴權之擁有人，只需有法律人格。任何人可行使訴權，即使其並不具有實體權利。然而在此情況下，該訴，必定會被裁定理由不成立，但並不因此而不能行使訴權。

這個立場亦受到批評，其依據亦是站不著腳。其支持者落入主張古典理論之對立面：訴權有別於實體權利，因為可省卻後者之存在。

但並非如此肯定……

從純實體觀點言之，任何人，即使並非一個權利之擁有人，可援引這種身份而促成法院開展活動。然對法律專家感興趣的並非這個問題之實質方面，感興趣的是向法院提出請求而開展之活動之合法性。

訴權為國家承認予私人之權利，以滿足社會和平及公正之需要，而非為了滿足個人任意計劃，否則最終引致否定設定審判權之理由。如不援引存有欲主張之實質權利為基礎，訴權將不會存在。提起訴訟而不援引一個實體權利的行為是不符合法律規定的。此並非行使訴權，而是濫用該權利。

B) 接著我們研究“主張視訴權為針對他方之一個形成權之理論”。

許多著名訴訟法學家主張這個理論，例如 Chiovenda 及 Piero Calamandrei，各人皆認為訴權乃典型之形成權。依其觀點，訴乃行使審判權所必須之條件；故訴是一個形成權或創設性權利，因為對被訴人來說，由針對其而宣告之司法措施所產生之效果會引致一種屈從狀態，其意志為何則在所不問。這亦為不能接受之理論。

對形成權之批評亦適用於對上述理論之批評。

在訴訟關係上，並不能說一定向被告施一種屈從狀態，即使他必受制於由司法判決所產生之某些效果，而這些效果亦非純因原告之意願而產生在被告之權利義務範圍內。被告人，藉其在程序內之行爲，行使其辯護權，可改變裁判之意思。

此外，訴權並非直接及僅針對被告提出，而是先針對國家提出，後者有審定所提出之請求之義務。

C) 最後，我們分析了訴權為要求國家保障之一個具體權利。

此為研究本問題之大部分學者所持之立場，即使如此，他們仍就訴權之客體爭論不休。

該權利建基於：在尊重法律秩序之具體情況之需要下、訴諸司法機關之可能性，屬於一個真正之權利——相對立的是一個具積極內容之義務，由國家機關給予司法保障，訴權是一個具體權利，因為聯繫著一個受到威脅或被侵犯之實體觀權利。

但出現分歧之地方在於：由於所有主觀權利皆有主體及客體，故須嚴謹地界定訴權之客體。

毫無疑問，主體乃原告及透過法院作為主體之國家。

但客體是什麼？似乎無疑問存在：客體乃透過一個具約束力之確定裁判、對所主張之實體權利作出審定。

但何類裁判？有關判決？對實體問題之判決（審定實體問題）？公平判決（對原告有利或無利之判決、實體或非實體判決）？

這一連串疑問表示了支持這幾個理論之人所持之不同立場。但不難發覺首兩個理論之錯覺，忘記了我們所分析之現實之基本。我們可以看看：倘國家之保護僅透過作出有利原告之判決而進行，則不應會有理由不足之訴。原告起訴時深信其權利有效存在，然而是由法院判定，只有原告真為所主張之權利之擁有人及證明權利所依據之事實，方會作出有利原告之判決（當然還要符合其他要件）。

同樣地，倘需要判決對實體問題作出審定，以便國家作出保護，為何可能因欠缺訴訟前提，法官透過一個形式判決而作出起訴不予受理之批示（《民事訴訟法典》第 230 條（駁回起訴之判決））？

即使如此，似乎不容否定的是訴訟程序之目的並非獲得一個判決。

倘程序之目的為確定爭議或不肯定之法律狀況，所希望的是獲得法院的一個公正判決，即一個以事實為基礎、依法作出之裁決。

依此見解，訴權是要求國家作出保護之一個具體主觀權利，是透過一個公正判決而實現。

C 批評及採用之立場

上文指出了對古典理論之批評以及現代理論對訴權之法律性質作出探討²⁹。

雖然這是一個重要問題，或者是理論多於實踐，事實就是在原理上我們需界定一個基本意思：以所述之制度為基礎而展開我們之研究。

我們將扼要地指出訴權之特性。

對我們探討訴訟關係之內容、性質及特徵，尤其是關於其結構，我們需指出其特性——仿如其他不同內容之法律關係，其主體特性有別於實體法律關係之特性，但相對於後者而言享有獨立性。關於訴權之法律性質，我們更易採取立場，而訴權之行使正表示訴訟關係首段之創設行為，此外，其結構性元素之一。

關於這種情況，我們已擁有理解這種情況之充足知識。

如此，雖然每個理論皆有其真實之一面，即每個理論皆有一些理由，似乎不能接受上文 B 所述之理論。

這個立場容許我們利用上述各種理論的長處，但我們傾向於較接近現實之最後一個理論；但仍有所保留。

其次，最完滿之答案是採用折衷主義之答案。

對我們來說，訴權有權利之特性，——而訴權作為一種權能、得到法律體系之保證、且滿足某一種利益，故在界定时應考慮意志元素及利益元素，兩者互相結合。

但該權利之結構有別於實體權利，很明顯，因其中一個主體地位不同，就是

²⁹ Salvatore Satta 稱此為“法律科學最艱難之一章”

法官，他地位超然及在行使一職能性義務（權利／義務）。

在這點內容上，我們同意 Anselmo de Castro 教授所說：訴權是一個純程序權利，其標的乃審定具體提出之請求，是一個在結構上有別於實體權利之權利。但我們不同意“國家、法官及被告人皆無相應之義務”，僅作為行使審判權之條件及限制³⁰。

除有其他意見外，指訴權無相應之國家義務似乎並非正確之言論，倘，訴權引致一種主觀狀況，則有別於權利³¹。

指國家乃審判權之擁有人，並無因私人之請求而負有作為之義務之言論並不正確。

由此我們按照某些理論觀點探討這個內容（並非將其理論發展至極端），訴權視為要求審判之權利，即一個要求國家給予保障或保護之抽象權利，要求國家提供審判活動之一個權利。

依此理論，Castro Mendes 教授（在進一步發揮法國學者（烏拉圭大學教授）訴訟法專家 Eduardo Couture 之理論時）認為：倘審判權係以其目的而界定，則其目的就是公平解決私人間之爭議，訴權即是要求公平解決爭議之權利³²。

但我們不能在此停步。

我們同意 Castro Mendes 教授之見解，司法訴權與不訴諸法院之權利並存，因兩者產生不同之權利。

我們亦認同，“對於有意看見自己之權利得到宣示或在違反其意志而執行之人來說，訴乃一種負擔……。為此，我們不認為訴並非一個權利。相反，在訴內，我們見到一個負擔，因此必須存有一個權利³³。

最近，這種見解被 Antunes Varela 確認，他認為，訴是一個權利，亦是一個負擔。他指出：“同一時間，負擔（由作為訴訟關係主體之私人負責促進起訴活動，此體現出私人之權利，私人認為受有損害，但不能以自己之力量作出反擊）：促成法院之活動之權利，以便法院對私人給予適當之法律保護”。

“只有引發活動後方會能知道申請人是否所主張之權利之擁有人，許多學者區分兩種情況：一是抽象意義之訴，或訴權，作為引發法院活動之權利，目的是透過法院獲得所要求之措施；另一則是實際擁有主觀權利之訴，即是《民事訴訟法典》第 1 條第 2 款所述之意思^{34 35}”。

³⁰ 見曾引述之作品，第 94 頁。

³¹ 同上第 95 頁，然而，該學者並無明確指出其認為這是主觀狀況。

³² 如上所述：審判權有雙重目的：維護法律及私人之權利。

³³ Castro Mendes 在其《司法訴權》一書中（第 53 頁）指出“舉證責任乃來自作出兩個相反行為之兩個權利一指兩個合法，在結果上有別之行爲。

³⁴ 見《民事訴訟法手冊》，第 5 頁及註腳一。

³⁵ 請各位留心該民訴大師送給澳門大學法學院 1992/1993 學年度三年級學生之講課撮要，其中有不少引人注目之新意。

訴權是一個具有公共性質之獨立權利，主要原因有三個：

似乎這是問題之焦點所在，再加上文所述之內容，我們可以指出訴權之特點如下：

a) 訴權是一個權利（要求審判之權利），因為它組成當事人之個人立場，是透過司法活動為實現一個目的而產生之立場；可用抽象或具體角度面對該權利，即對權利之一般性保護，或相當於對某個權利實際擁有人之保護。

但同時亦是一個負擔，因為該權利與不訴諸法院並存（即使在侵犯實體權利亦然），只是行使或不行使該權利會引致不同之後果。

b) 訴權是一個獨立之權利，因為並非實體權利之組成部分，兩者在客體上有別。

c) 是一個公權力，因為其中一個主體是法官（具備治權之國家公務員），形成一個主權機關：法院。

d) 訴權是一個要求按照具體情況及適用之法律而作出（以法律為依據）宣告措施、作出公正判決之權利。

D. (Acção) 一字在法律及學理之各種意思

葡語 (Acção) 一詞有廣泛之意思。

即使我們受限於現在所述之民訴範圍，各種困難並無因此而消失，需要穿透訴訟法律之用語，以便個別指出 (Acção) 之通用意思。

這個字往往在法律及學理內有其本身之意思，一時有司法訴權，在另外一些情況下，其意思相當於程序、程序形式、訴、案、爭議，甚至請求，例如訴之理由成立或不成立。

在《民事訴訟法典》內葡萄牙立法者如何確定該字之意思？

我們先看《民事訴訟法典》第 1 條第 2 款。

在這裏似乎是作為訴權之意思而出現：為了保護實體權利，宣示該權利或執行該權利，承認訴權及指出透過程序欲達之個目的：保證、宣示及實現權利，透過多種措施而達至，例保全措施，宣告之訴及執行之訴。

但在《民事訴訟法典》其他地方該字則以不同之意思出現：在訴之分類上，考慮到每一類訴，欲達之目的（第 11 條）；同意在一個訴訟中存在多個訴（第 63 條）規定當起訴狀依規定被法院辦事處收到後，視訴已提起（第 211 條第 1 款）。

閱讀這些條文可知 *acção* 並非作為訴權之意思而使用。

我們記得上文述及之內容：訴權之行使及要求提供法保護。

要求這種保護必須透過遵守規範司法機關活動之法律而進行，這些規範亦界定了實踐實體權利應遵守之形式程序。

此形式 (*rito*) 就是程序。

-
- 1) 此為探討私證制度過渡到公證制度之最佳立場；
 - 2) 實踐指出了許多訴被裁定為理由不成立，是因實體權利時效已過：在此情況下有訴無權；
 - 3) 有一些保全程序（例臨時扶養），行使訴權可引致裁定扶養之臨時給付，但後來可得出另一個結論：收取扶養費之人並無該權利。

訴權係透過程序而行使，起訴之人須提起程序。

程序乃行使訴權之渠道，使訴權由其靜態走向動態。

訴權是程序之起因或起始，但並非純起始點，而是一個較長時間之行爲起因，存於整個程序（案）待決期間³⁶。

在日常用語內經常混淆，即使在技術用語上，因與果互相混淆。甚至訴訟學家亦產生混淆，使程序與訴之概念混合。

此亦見於《民事訴訟法典》第 261 條：當所用之訴一詞乃指程序、提起一程序，行使訴權。

我們可以指出此爲訴一詞之程序意思。

但訴訟程序本身是利益衝突之體現。爲了解決利益之衝突，一方行使其訴權，產生訴訟程序。

用何種方法？

透過原告提起一請求之方法，而被告人有權反對該請求，之後法官決定誰有理由（部分學者稱此爲正反及綜合）。

在《民事訴訟法典》第 11 條內，既不考慮權利之訴、亦不考慮程序之訴，僅考慮由原告主張之目的而將訴分類，此則同請求之訴有關。

訴在該規範內，僅使用其中一個元素：請求——明確訴之目的，但它並非訴。相反地，訴乃主張請求之法律權力。

何謂請求？

指原告向法院提出之請求，當事人所作之意思表示，提出一個請求。

現在我們看第 63 條所用之 *Acção* 一詞。

在該處並非作爲權利，亦非作爲程序，更非指主張。權利已被行使，程序已被提起，原告之主張亦已確定指出。

法律上如何解決之？

訴一詞在此指訴內容之核心即指由審判人審理出現利益衝突，即 Carnelutti 所稱之 *lide*。

第 63 條容許各種訴之合併之可能性³⁸。

此爲在葡萄牙程序法律內出現之關於 *Acção* 之部分意思³⁹。

³⁶按照 Antunes Varela 教授在 1992/1993 學年給三年級學生講課時所用之術語：訴權並非在一時行使，而是在兩個不同時間內行使：一是起訴時，另一個則是被告人反駁或防禦之時。

³⁸ 當我們探討訴訟前提時我們會考慮主觀及客觀聯合。

³⁹ 純是基於好奇，我們可以指出一些學理所舉出關於 *acção* 這個詞含糊之例子：

a) Paulo Cunha 教授指該字有三方面之意思：作爲司法爭議問題之同義詞：案、爭議、訴訟；作爲訴訟方法；作爲權利；司法訴權。

Eduardo Couture 亦指出三個意思：權利、起訴及權能。

b) Manuel de Andrade 教授則僅指出兩個意思：實體之訴（但有公共性質）；訴。

c) Pekélis 指該字最少有十四個意思，雖然存在該等意思，但部分意思並不十分明確且不適合。

4.3. 有權無訴

關於（司法）訴權法律性質之問題，上文已指出了是否存在無訴之權利，一如《民事訴訟法典》第 1 條第 2 款所述般。

當時我們援引這種情況作為探討實體權利理論之其中一個理據，依此理論，訴權與實體權利互相混淆⁴⁰。

實際上，在某一些情況下，有些權利雖被實體法規範承認，但不能透過法院強制實行。

例如，自然債務（《民法典》第 396 條）：並無為債權人設定之一種訴，但以存在一種法律聯繫為前提，並以公平義務為基礎，而非一般道德之聯繫。此聯繫體現在獲得所欠之債（倘自發地作出給付）。

根據《民法典》第 297 條規定時效已完成之債，時效的完成並不引致權利之消滅，而是會轉成一個自然債務。自然債務之淵源是分散在法律之中，只要屬合法及無其他無效之原因即可，如《民法典》第 1171 條第 1 款規範賭博及打賭之債務；還有其他法律所定之情況。

在實踐上出現許多有疑問之情況，學理在對其進行分類時，應屬自然債還是民事債存在，意見分歧⁴¹。

在自然債務之情況下，債務人可以在自願的情況下履行債務，及後不得要求返還所作之履行。然而，倘不願履行，債權人不得透過法院要求債務人履行，但屬因時效而完成之自然債務除外。倘為此目的而起訴，債務人可透過抗辯而提出辯護，聲明該債為不可要求履行之債。無論如何，該訴是理由不成立。上文已述及此點。

5. 訴之法定分類

現在我們將注意力集中在訴之分類上，即按類別將其分組。

無論在學理或法律上，所採用之立場皆不相同。一如大家所理解般，一切視乎用作分類之標準而定。

我們看看：

- a) 倘我們考慮欲保護之實體權利之類別，我們可以區分：對物之訴及對人之訴；
- b) 倘我們考慮訴所針對之財貨或物之類別，我們可指出有：不動產之訴及動產之訴。

如此類推。

但我們的注意力將放在現行民事訴訟法律對訴之分類上，這種訴係同面臨危機之實體法律關係之類型有關。

倘我們否定現時法定分類之前身，我們會發現 1939 年之《民事訴訟法典》（第 4 條）將訴分成五類：

⁴⁰ 見條目 4.2.。

⁴¹ 例 1983 年 5 月 10 日葡萄牙最高法院之合議庭裁判（公布在 BMJ（葡萄牙司法部公報），327 期，第 636 頁）。

- (1) 確認之訴；
- (2) 給付之訴；
- (3) 保全之訴；
- (4) 形成之訴；
- (5) 執行之訴。

學理將前四類列入**宣告之訴**之類別內，與其相應的是**執行之訴**；然而許多人批評這個法定分類，所持論據是這是一個純學術分類。

因為既不與法典之系統編排相符，亦不與法律所定之多種訴訟形式相一致。

現行《民事訴訟法典》第 11 條嘗試排除這些缺點，故先對訴作一個簡單區分：**宣告之訴**及**執行之訴**（第 1 款），然後在前者範圍內，按照原告欲獲得之目的，分成**確認之訴**、**給付之訴**及**形成之訴**。

在法律用語上，宣告之訴包括：

- a) **確認之訴**——唯一之目的是宣告某權利或事實存在或不存在（第 2 款 a 項）；
- b) **給付之訴**——以獲得一物或一事實給付為目的，或預防一個權利受到侵犯（第 2 款 b 項）；
- c) **形成之訴**——目的是容許在既存之法律秩序內作出一種變更（第 2 款 c 項）。

另一方面，執行之訴是指：“原告（申請執行之人）申請實際彌補被侵犯之權利之適當措施（第 11 條第 3 款）。執行之訴之直接客體為在事實層面上強制實行被侵犯之權利。

保全之訴之法定類別已經消失，不再列入訴之分類內，《民事訴訟法典》第 1 條第 2 款指“為確保訴之有用效果所需之措施”。這些措施並不被現行法律視為獨立之訴，故不會產生真正之訴訟，而僅產生程序：保全措施（*procedimentos cautelares*）——在《民事訴訟法典》第 326 條及續後數條規範。

現在我們看看真正之訴之法定分類。

面對法律之表達形式，Palma Carlos 教授指出：藉**宣告之訴**有意在思想層面上作出一個司法作為，對某個權利作出宣告、界定，或使其變得肯定；藉**執行之訴**，有意在實質層面上要求作出一個司法作為——借助判決或執行名義滿足或實現之前已確定之權利⁴²。

現在我們分析每一種法定之訴。

一、宣告之訴

a) 確認或單純宣告

1939 年之《民事訴訟法典》結束了關於是否在葡國法律內一般性地接受確認之訴之疑問。

當向法院提出具體個案時，這個問題變得複雜。

例某人之出生證明書內遺漏了關於父母親之資料，有人稱其為某女士之兒子，故對該女士提起一親子關係之訴。

但後來發現法院對此案之裁判無管轄權，因此，程序終結。但原告仍繼續公

⁴² 稍後我們學習這些概念。

開稱自己為該女士之兒子。由於產生許多不便，故該女士決定提起一否認親子關係之訴，並由 Alberto dos Reis 出任訴訟代理人。

後來訴訟被裁定為理由不成立，因法院認為（即使在二審法院亦然）不接納在法律明示容許之極少情況以外，提起僅為終止不確定狀況之訴訟，即確認之訴。

後來，Alberto Reis 及其他大師接受這類訴。在 1939 年之《民事訴訟法典》內（草案由 Alberto Reis 教授負責）在第 4 條內規範了這類訴訟⁴³。

在這類訴內，原告人有意終止一權利或事實之不肯定性。此為其目的所在，一如法典第 2 條指出般：“所有權利……有相應之訴，目的是請求法院承認其權利……。”

在這種司法措施之法定類型裏，無需援引一權利所受之侵犯或損害，原告人僅需對一種不肯定之狀況作出反應。

這種訴（在學理上亦稱為純宣告之訴可用積極形式提出（《民法典》第 1655 條所述之情況就為一例），或以消極方式提出（例針對某人提出否定父子或母子關係之訴）。

在前述形式裏，有意宣告一權利或事實之存在，在後述情況下，提起訴訟之目的為宣告一權利或事實之不存在。

然而，必須強調：一積極確認之訴之最終判決可以宣告有關權利或事實不存在，可變成一消極之宣告。對於作為訴之積極或消極之分類是考慮請求之內容，起訴人申請之具體措施，而非法院後來宣告之措施。

最後，按照多名著名訴訟法專家之意見，再結合上述之見解，對特定之權利直接地作明確界定之宣告之訴亦間接地保證了法律與法律關係之肯定性；對預防或有之爭議擔當一個重要之社會功能，亦必然對加強法律行為之肯定性作出貢獻。

此外，這種訴有一個無限之適用範圍，針對所有及任何法律關係，即使不能用給付作衡量亦包括在內。

b) 給付之宣告之訴

現在我們學習宣告之訴之另一組分類：**給付之訴**——以要求給付一物或一事實為目的，以假定或預計侵犯一權利為前提（第 11 條第 2 款 b 項）。

作為前提，有一個由義務主體、即被告人現在作出或將作出、或已作出或可能作出之一個違法行為。

當提起這類訴時，原告針對其權利之侵犯作出反應。該訴以令實體法規範內所定之懲罰性機制運行為目的，以便克服對其命令作出反對之行為。

倘這是正確之內容，在這種訴內有其確認之一個方面；不能在未預先調查原告援引之權利是否存在之情況下依請求而判定被告人：此為確認之訴及給付之訴之共通點。

然而，對權利存在之認定（確認）及對該權利之侵犯，在給付之訴內僅作為達至一個最終之目的（給付判決）之途徑；不同的是在確認之訴內，確認乃審判

⁴³ 這類訴載於現代民事訴訟法典內，例德國、奧地利及巴西之民訴法典內。

活動唯一欲達之目的。

但不應認為在給付判決之訴內有兩個重要之訴。訴僅有一個，但包含兩個不同之邏輯元素——在程序進行過程中連續出現。

換言之，在給付之訴內集合了兩種判斷：一是確認（默示地進行），另一為給付判決（明示地表述）——兩者無程序之獨立性。

典型之例子為：例被告被指不履行債務，債權人請求法院，經承認其擁有權利及被告違反義務之情況後，命令債務人（被告）作出欠缺之給付。通常稱此為債務之訴。

但作用更大的是有一種雙重預防：

- 1) 一方面，在給付之訴內、不一定判被告人作出給付而終結；只要原告之訴求是要求一項給付判決即可；訴則會因應原告欲得之目的而分類。
- 2) 另一方面，並非僅在給付之訴內作出給付判決，在這種判決內，法院強制敗訴方作出一個或多個行為、且不取決於（作出判決之）訴之性質。

例在確認之訴內作出之判決：判敗訴方支付訴訟費，或在任一類訴內判定其中一方罰款。

基於給付之訴本身之性質，只有存在執行之可能性方有給付之訴，故可以同體現在給付之物質權利有關。

確定不履行債務乃作出給付判決之必然邏輯前提，為此法官須全面證明權利之存在及被侵犯。我們在上文已述及此點內容。

但在某些情況下，法律滿足於一種可能出現之違反狀況，容許提前作出給付判決，例如，當債務人不支付其中一期之定期給付；故可在原告之訴求內包括已到期的及債務人將要繳付之各期款項（《民事訴訟法典》第 393 條第 1 款）。不履行其中一期已構成足夠理由使人相信債務人不會依時履行其他各期債務。此為一法定制度。

C) 形成之訴

最後，宣告之訴這個細分類載於《民事訴訟法典》第 11 條第 2 款 c 項內，其規定為“如其旨在直接創設、變更或消滅一法律狀況。”

我們可以知道這類訴可與**確認之訴**及**給付之訴**相對立，在前述兩種訴內，僅審定先前存在之狀況。**形成之訴**不同的地方是雖然以對先前之一種狀況作出審定為基礎，但對其變更作出宣告。在這種訴內，透過司法當局之協助，原告有意獲得一種新之法律效果——在被訴人（或在被訴人及原訴人）之法律權利義務範圍內產生一種變化，被訴人之意志為何則在所不問。

這種新之法律效果，雖為應原告之請求而產生，但是由司法裁定直接確立。故出現法律名稱。

作為這些訴之例子——藉此建立一種新之法律關係，變更或消滅一種既存之法律關係，依順序計有：

1. 設定通行役權之訴（《民法典》第 1441 條）；
2. 推翻親子關係之訴（《民法典》第 1698 條）及

3. 離婚之訴（《民法典》第 1628 條及續後及撤銷任何法律行為之訴；還有其他例子。

形成之訴有三種形式：

1. 狹意之形成之訴——藉此訴創立一新之法律關係；
2. 變更之訴——藉此訴變更一既存之法律關係；
3. 消滅之訴——以終止在提起訴訟之日存在之一法律關係為目的。

按照認同**形成權**存在之學者⁴⁴，形成之訴同行使這些權利有一種聯繫，判決僅限於在分析有關前提後對該權利作出宣告或許可。

視乎各種情況，在實體層面上，判決之效果可於下述時間開始產生：

1. 自作出判決之時起，即自判決確定時起（*ex nunc*），例離婚案；或
2. 追溯至之前之一個時間——可以是起訴之時，或（有意變更或消滅之）法律關係形成之時刻（*ex tunc*），例在任何行為之撤銷之訴內就是如此⁴⁵。

但在形成之訴中，雖然判決是在法律主體之權義範圍內發生變更之原因，並不表示判決創設法律（或稱法官造法）：變更乃源自法之強制力，而非法官之意志，變更之前提載於實體法內（法院在行使其職能時須遵守）。

依此結論，我們可以說，從上文關於宣告之訴之分類內容可得出：在各類宣告之訴內，皆有一個共同元素：對一既存或如此主張之狀況作司法審定及宣告之活動皆具有全部或局部之宣告性質。

在某些情況下，審判權在宣告後終止；在其他情況下，所作出之宣告僅是為了解採取預防性或形成性措施之途徑或方法。

從上文所述之內容可得知：在每類訴內所作出之判決，並不一定與原告之請求內容一致，但這種情況並不會變更對按照法定標準對訴之定性。

B. 執行之訴⁴⁶

最後，《民事訴訟法典》第 11 條第 3 款將這種訴界定為：其目的是“獲得彌補被侵犯之權利之訴訟”，此為一個不完整及解釋不清之定義。較理想的定義是視其為：藉主張一載於具特別力之文件內之債務無被履行，原告（請求執行人）請求法院實際恢復其權利，即用債務人財產之等額代替債務之給付。

故**執行之訴**必須：

1. 以一**執行名義**為基礎，且必須屬於《民事訴訟法典》第 677 條所述之其中一類；
2. 以一**給付**為目的：支付一定金額、交付一定物或作出事實給付（積極或消極給付）（《民事訴訟法典》第 12 條第 2 款）；

⁴⁴ 形成權給予其權利產生一個全新之法律效果（透過權利人之意志或司法裁判）的權能。有權在不取決於義務主體之意志之情況下形成權利，而義務主體則處於屈從之狀況，要承受因他人行使權利而產生之法律後果。

⁴⁵ 多年來關於判決之創設性效果，德國學理意見分歧，有人（例如 **Kisch**）認為僅產生將來效果，不會溯往生效，而其他人（例如 **Goldschmidt**）則持相反見解。

⁴⁶ 在此我們僅限於指出這類訴及執行名義之基本概念，將會在民事訴訟法 II 學科內作詳細探討。

3. 以**財產**或**財貨**為標的。

基礎、目的及標的乃執行之訴之三大要件。

典型之執行名義為**給付判決**（第 677 條 a 項）；此外還有非司法之執行名義——其中包括公證文書及經認證之文書，甚至在某些情況下包括私文書（《民事訴訟法典》第 677 條 c 項）。

稍後我們會知道，執行之訴有相應的、有別於宣告之訴之訴訟程序形式；法律要求認定某些訴訟前提——與宣告之訴之訴訟前提不同。

現在只需要知道：相對於其他類別，**執行之訴**乃一種獨立之訴訟，它並非宣告之訴之一個新階段，但部分學者曾經支持這種理論，依據是執行之訴僅為為實際實踐被宣示之權利⁴⁷。

在現實裏，執行之訴並非宣告之訴之延續。**執行之訴**並不一定以**給付判決**為基礎而提起，可引用其他執行名義。此外，**給付之訴**並不一定接著是執行之訴（例被判定履行債務之被告人真正地履行其債務）。

在**宣告之訴**內，訴訟關係因判決而消滅（《民事訴訟法典》第 229 條）；**執行之訴**不會使宣告之訴復甦，相反會產生一新之爭議或訴訟（法律）關係。

所有這些問題將在民事訴訟法 II 這一科目內詳加闡述。

6. 依形式標準對訴之分類

6.1. 具特別程序之訴

無論宣告之訴或執行之訴皆具有不同之形式，故有各種不同之程序形式。

這個內容見於《民事訴訟法典》第 II 卷第 4 編內。從第 369 及第 370 條開始，以及包括宣告之訴與執行之訴之共同規定，之後有四個關於**宣告之訴之一系列規定**，兩個關於**執行程序之規定**。

我們先分析共同之規定。

第 369 條規定：“1.程序可為普通或特別程序。2.特別程序僅適用於法律明示規定之情況；普通程序通用於所有無相應之特別程序之情況。”

當要提起訴訟時，最重要的是知道法律有否規定了特別訴訟程序，倘無則引用普通程序。這個普通形式並不能被當事人排除⁴⁸。

特別程序載於《民事訴訟法典》第五卷之第 837 條及續後條文內。其中包括宣告性質之程序（例如，對外國判決之審查）、執行性質之程序（例如，扶養之特別執行）⁴⁹以及非訟事件之程序⁵⁰，又或採用 Antunes Varela 教授之啓發性用

⁴⁷ Dias da Silva 多年前已主張這個意思。

⁴⁸按照 Alberto dos Reis 教授清晰及明確之表述方式，將原告人所提出之請求及目的與特別訴訟程序相對照，如兩者均相等，則特別程序乃適當之程序。否則適用普通程序，又或其他特別程序。簡言之，程序形式與訴之主張相配合。見《民事訴訟法典評釋》，第一卷，第 333 頁及《特別程序》，第一卷，第 6 頁。

⁴⁹只有法律明示指定時方有特別程序，且在程序之間無共通性，而每個程序按其本身之特別模式制定。有人指這是不和諧之整體，完全無組織上之連繫。

還需注意源自《民事訴訟法典》第 369 條之“法律”這個詞。分散在其他法典內有許多特

語，後者為“特別程序之近親”。

非訟事件之程序之問題（在學理上爭議很大，因仍未能確定其與司法審判之分別），Albertos dos Reis 教授在《特別程序》一書內對此作了深入之探討。

該著名訴訟學家提出了作為區分之多個標準外（由傳統以至純形式之標準，甚至 Chiovenda, Wach 及 Zanzucchi 之不同理論——以創設性目的界定非訟事件程序，最終亦承認此為一個無肯定基礎、且未決之問題）。

為此，在《民事訴訟法典》關於非訟事件之程序之處理問題上，將其放在特別程序內。如此出現了概念上之問題，立法者選擇了在法典內詳細列出所有非訟程序，然在整理這些程序時卻帶有任意性。

後來 Anselmo de Castro 教授強調：“我們的《民事訴訟法典》或者是唯一一部完整及詳盡整理非訟事件之程序之法典（在葡國生效的《民事訴訟法典》第 1509 條及續後，而在澳門生效的《民事訴訟法典》第 1206 條及續後）”。

何謂非訟事件管轄？與司法審判有何分別⁵¹？

我們看看：

- a) 司法程序是指爭議人由於未能和好地達成協議，故向法院提出相對立之請求，以便法院界定出現問題之權利及主持公正。在任何情況下，有利益衝突，有爭議，且有利益間的相互矛盾。
- b) 非訟事件之程序係指循司法途徑實施某個行為之可能性，以便法官監察及給予其一個不容爭議之認證性質，即使所有利害關係人同意實踐相同利益，又或彼此間有分歧，但均不體現在利益衝突上，而僅是在滿足唯一一種利益之方式上意見不同，正有意循司法途徑確定這種利益。並不存在一個真正之爭議，因無矛盾存在。

作為司法訴訟程序的例子有：催收債項之訴：原告請求支付一債務，或要求被告履行一先前與之訂立之一合同債務。

作為非訟事件之程序有親權之約定——兩願離婚之父母求諸法院以便以訂立將來行使親權之制度。

在這程序內，在法律上並無處於衝突之利益：法官僅考慮兒子之利益，法官之裁定乃按兒子之利益而作出。

在《民事訴訟法典》內之所列舉僅為經驗方面之列舉，並無界定有關概念，一如我們在上文所強調般。

別程序，例《民事登記法典》，《物業登記法典》。在此提醒大家，這些法典在規範有關範疇之特有程序時，有時稱為特別程序，有時稱為普通程序。屬於這些法律範疇內之一些相對性概念，即使在這些範疇內屬於普通程序，相對於《民事訴訟法典》所規範之程序而言，則有特別程序之性質。

⁵⁰ 我們可稱此為特別程序內之極特別程序。

⁵¹ 有人將真正之訴訟審判之反面視為自主訴訟（自願訴訟）。在第一種訴訟內將參與人稱為當事人，在第二種情況內，將之稱為參加人。

在比較法層面上，最少 1884 年之墨西哥《民事訴訟法典》稱為混合審判。

然而，第 1206 條指明這類程序具有下述特點：

- a) 強調調查原則優於處分原則或程序推動原則相對立；

第 1207 條第 5 款給予法院調查事實、要求證據及搜集資料之完全自由，公開地在非訟事件之程序內確立**調查原則**。

相反地，在司法程序內實行處分原則（《民事訴訟法典》第 563 條第 2 款），雖然有法官之主動權加以調節。

- b) **衡平原則優於合法性原則**一如將《民事訴訟法典》第 1208 條及第 567 條作一比較所得出之結果般，第 1208 條乃關於非訟事件之程序。

相反地，在司法程序內，該規範命令法官將解釋及適用法律於事實，並作出最後裁判。

- c) 不能向終審法院上訴。

《民事訴訟法典》第 1209 條第 1 款指出：“不得就非訟事件之程序按適當或適時準則所宣示之解決方法向終審法院提起上訴”⁵²。

- d) 對在非訟事件之程序內所作之措施之決定可自由變更。

在司法程序內所作之裁判轉為確定判決後具有確定性；在非訟程序內所作之決定通常得以情事變更為依據而作出變更（第 1209 條第 2 款）。

然有例外之情況：宣告兩願離婚之判決轉為確定後不可變更。

最後，提醒大家須記起非訟事件之程序這個概念非常受爭議，尤其是因為許多學者不視其為真正之司法案件，視其有行政程序之性質。

一如 Anselmo de Castro 教授所述般，葡萄牙程序法立法者列出非訟事件之程序之立場並未未能消除這個概念產生之疑問：“問題依然存在，關於知道《民事訴訟法典》以外有否一些行為應視為非訟事件之行為。尤其是關於民事登記法典及物業登記法典之某些規定，這個問題仍然存在”⁵³。

對這種爭論我們不作深入探討。

我們再談談依形式標準之訴之分類及有關程序。這種分類之需要在於何處？

在邏輯上我們理解到：

- a) 一方面，形式應與原告針對之目的相對，即在訴內提出之請求相符。

- b) 另一方面，某些權利之特徵在保護上需有一特別程序。

6.2. 普通訴訟程序及其二種形式：通常訴訟程序及簡易訴訟程序。

我們先談談第 370 條之規範其標題為一般規定：“普通程序為通常程序及簡易程序”。

如眾所知，這條規範適用於宣告之訴及執行之訴，但在每類訴內，區分成三種形式之標準並不相同。

⁵²例外之情況是在兩願離婚之訴內所作出之判決，其訴訟利益值按《民事訴訟法典》第 254 條訂定，為中級法院之法定上訴利益限額加 1 澳門元。

⁵³似乎載明非訟事件程序涉及開展純行政性質之活動，是人們所稱之“私權之公共管理”之組成部分（Zanobini）。故有學者稱該審判既非自願、亦非審判——此為 Chivenda 之佳句。

我們僅分析關於宣告程序之規範，尤其是第 371 條。

但對規範之完全理解須先理解某些概念——將是稍後研究之標的：案件之訴訟利益值及法院之法定利益上訴利益限額。

關於訴訟關係之附隨事項，我們之訴訟法律在第 247 條至第 261 條內規定了案件之利益值之訂定⁵⁴。第 247 條第 1 款規定“對每一案件須設定一定利益值，其以在澳門具有法定流通力之貨幣表示，並代表有關請請求之直接經濟利益”。第 2 及第 3 款提及受案件之利益值影響之各個方面：普通訴訟程序之形式，案件與法定上訴利益限額之關係、訂定訴訟費用及其他法定負擔。

在續後條文內訂立了適用於設定案件利益值之一般及特別標準：某些屬於自然標準（第 248 條）；其他則為擬制之標準（第 254 條）。

採用這些規範命令及所有關於這個事宜之命令，我們可以決定一案件之價值，之後按照第 371 條之規定容許找到有關訴訟之形式（在法律所定之程序之制度內）。

但案件之利益值這一元素本身並不足夠；我們要限定另一個概念：法定上訴利益限額。

Alçada 這個字有一個簡短的歷史，其意思隨著時間而演變，這個歷史對我們有用。

Alçada 原先指一個法院或一個巡回委員會——到各地去處理司法活動。在 Frei Luís de Sousa 作品中指出：“人們稱法院為 alçadas，其以皇權之名義管理百姓，在日常巡迴行程裏處理上訴案、懲處濫權者。

後來，alçada 被 Casas da Relação/Desembargos（中級法院）代替。

在這個概念內，我感興趣的是一個法院之法定上訴利益限額——即指有關金額之內該法院作出之判決不能上訴（《民事訴訟法典》第 583 條第 1 款），亦即指確定性判決。

在澳門，根據 12 月 20 日第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》第 18 條第 1 款及第 2 款規定，有兩個具法定上訴利益限額之法院：初級法院及中級法院，其上訴利益限額分別為的五萬澳門元及一百萬澳門元。現在我們探討另一個同普通宣告訴訟程序之形式。

《民事訴訟法典》僅詳細規範通常程序之程序步驟（第 389 條至第 580 條），對於另一個訴訟程序（簡易訴訟程序：第 670 條至第 676 條）並無完整之規範。

有人會問：對後述之訴訟程序無特別規定之情況下，如何進行有關程序步驟？

答案在第 372 條，彷彿在填補程序法律漏洞時訂立一個等級般。第 372 條（規範簡易訴訟程序及特別程序之規定）規定：一、簡易訴訟程序及特別程序受本身之規定以及一般及共同規定所規範；對於上述規定中並無規範之事宜，須遵守就通常訴訟程序所定之規定。二、在特別程序中尚須遵守下列規定：a）記錄證言須遵守第 447 條之規定；對終局裁判提起平常上訴之規定（第 448 條）；b）如

⁵⁴ 《民事訴訟法典》第 258 條。

須變賣財產，則變賣按執行程序所規定之形式進行，且事前須按第 755 條第 1 款之規定命令作出傳喚，以及依據經作出必要配合之第 758 條及隨後數條之規定審定債權。

7. 保全措施 (procedimientos cautelares)

7.1. 保全程序之性質。

依目的為標準，這種程序與訴之分別：

現在我們分析這個程序之概念，先由最近之歷史說起。

前文已指出在 1939 年之《民事訴訟法典》(第 4 條)內除了確認之訴、給付之訴、形成之訴及執行之訴外，還有**保全之訴**。後者是一類獨立之訴訟(法律將其與其他訴訟放在同一層面上)。

這個法定分類當時受到學理之猛然批評，指其將性質截然不同之訴訟、例宣告之訴及執行之訴放在同一層面上。

在這個方面，訴訟改革之高潮是 1961 年公布及於同年生效之葡萄牙《民事訴訟法典》接納了過去認為預防程序及保全程序無獨立性之見解，而只是訴之先前程序或附隨事項，故不再出現在第 4 條之規範之內。

現行訴訟法律在程序之一般性規定內有一章專述及“保全程序”(第 326 條及續後)，其中區分：

- a) 訴或主要程序(其中包括一個確定性之最後裁判)；以及
- b) 視乎一個主訴之措施，而且作為一個先決或附隨事項——提起一個保全程序，而非一個真正訴訟程序，其中只作出一個臨時性裁定。

從訴訟法律中還可得出這種從屬之情況。

從《民事訴訟法典》第 1 條及第 2 條可得出訴(目的為在法院內承認權利或可以有權利使用強制執行去保障其權利)與保全措施是為了使訴能夠達致預期之有用效果之必需措施。第 328 條第 1 款規定“保全程序須取決於存有以被保全之權利為依據之案件，並得於宣告之訴或執行之訴開始前提起或作為其附隨事項提起。”故保全程序必以現時或將來存在一主要訴訟程序為前提。

屬於預防訴訟因審判緩慢而產生之危險⁵⁵。按照第 2 款之規定，係權利擁有人可採取之方法，其目的是保全訴訟之有用效果。Antunes Varela 教授表示：“為了使判決不成為一個純理論決定⁵⁶。目的是確保訴訟之效果，維持原有之狀態，使其不發生變化，避免使被侵犯之權利無法復原，此外，鑑於實現權利緊急性提前行使將可能實現之權利。

確保首個目的之措施中，有假扣押、制作清單及新工程之禁制。

假扣押指對債務人之財產作司法扣押，避免債權人在查封前可能承受之風險

⁵⁵ 雖然《歐洲人權宣言》第 6 條第 1 款聲明：公民有權要求其案件在合理時間內得到審判，但在葡萄牙，訴訟程序緩慢是一個事實。

⁵⁶ 見 Antunes Varela 教授《民事訴訟手冊》，第 2 版，第 23 頁，按照 Montebano 之見解(見其作品《La Tutela Giurisdizionale del Diritto》：“在事情變得太遲之前，必須能夠就現在之情況作出決定”)。

（《民法典》第 615 條至第 618 條及《民事訴訟法典》第 351 條及續後），一如提前進行一金額之執行之查封階段（第 351 條及續後）。

透過制作清單（《民事訴訟法典》第 362 條及續後），有意排除因司法裁判緩慢而使權利不能恢復之風險。

同樣地，關於新工程禁制（《民事訴訟法典》第 356 條），其目的是確保一權利之實際實踐⁵⁷。

其法律結構是：某人開展一項損害他人所有權、占有或其他用益物權之工程。但發現這種情況後，法院承認受損害之人有禁制工程之權利，即可要求立即停止或中止有關工程⁵⁸。

作為提前行使將來可能實現之具有緊急性質權利之保全程序之例子，如臨時扶養——規範在《民事訴訟法典》第 344 條及第 347 條，作為從屬於扶養費之訴（具確定性質）之保全程序。

所有這些情況皆為保全措施、保護法律規定之權利之方法——載於第 1 條第 2 款及作為一般及特別規範載於《民事訴訟法典》第 338 至第 368 條內；保全程序乃申請保全措施所進行之程序。

7.2. 保全程序之結構

今日，在我們的法律制度內，當將這個概念列入程序內、而不列入訴內時，等於刪去其獨立性：這些程序取決於一個待決之訴訟，或將來提起之訴訟，視乎各種情況，成為訴訟之程序或附隨事項；基於本身性質及其特殊目的，其結構比訴更為簡單。

一如 Calamandrei 所說（見《保全程序系統研究引介（Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari）》一書）：保全措施並非一個目的，而是一個途徑。

這些措施基於兩個特性，要求符合兩個要件：表面上，一為，申請人援引之權利確有可能存在（*fumus bonni juris*），二為，因未滿足該權利而產生之危險（*periculum in mora*）。

要符合第一個要件，只需作一個可能性之判斷；並不要求法官在程序內具備確定之證據。

但在審定第二要件時需作一個肯定性之判斷。

我們知道：保全措施之功能在於排除遲延之危險；Calamandrei 指出：“保全措施表示對處於衝突之兩個要求作出一種協調：快捷性與謹慎性。在快與好之間找出平衡，保全措施之目的在於快捷，容許.....在較後時間才依照通常訴訟程序之詳細程序步驟解決裁決之實質公平問題。使訴訟程序能平靜地進行，因已命令作出了適當的預防性措施，使確定性措施一旦宣告時，即能產生有用之效率，達

⁵⁷ 這個概念源自古羅馬，亦規範在《律例匯編》（第三卷），在後來之葡萄牙立法內保留作保全程序：《最新之司法改革》，1867 年之《民法典》，1876 年之《民事訴訟法典》（放在“訴之預防及預備行為”，還有 1939 年之《民事訴訟法典》（預防及保全訴訟）。

⁵⁸ 被通知禁止工程的被禁制人仍繼續工程會觸犯違令罪（見《澳門刑法典》）。

致實際之效益”。

保全措施是來自民事司法機關之司法措施，目的是指向一個實體問題作出裁判，以確保有關效果。鑑於這種功能，這些措施稱為保全措施，其理由在於不損害對權利之司法保護，此為對權利作實際司法保護之原則所在——此為 Chiovenda 宣告之原則，他提出關於程序之期限、解決訴訟爭議所需之時間之規範，不應損害原告人之權利⁵⁹。

另一方面，保全程序之法定制度是按照某些特性而加以界定，我們可以將其綜合如下：

- a) 屬緊急性及例外性措施，所作之裁判為臨時性措施。
- b) 這種緊急性足以成為違反辯論原則之理由（不聽取申請所針對之人之陳述——見《民事訴訟法典》第 330 條第 1 款及第 335 條第 2 款）；
- c) 無獨立性：作為訴之預先或附隨事項——以被保全之權利為依據（第 328 條第 1 款），為此在第 334 條所述之情況下，保全措施會失效；
- d) 有一個較簡單之結構——當與訴訟相比較時（舊法典指法官簡略理解案情（*summaria cognitio*），以強調舉證與審證之簡單方式）——參閱《民事訴訟法典》第 329 至及第 330 條。

7.3. 保全程序之分類

除了上文我們所述之特定保全程序外，在澳門現生效之《民事訴訟法典》還有普通保全措施，藉此制度使未被特定保全措施所保護的其他對實際實現權利出現危險之狀況。

似乎可以邏輯及合理地指出：只有申請人描述之事實狀況與法律所明確定出之措施不一致時方不引用普通保全措施（*providências especificadas*）。

毫無疑問，第 326 條的情況是對特定保全措施的一種後補適用的制度，一如 Antunes Varela 教授所指般：“用意為向申請同類情況之措施大開門戶”⁶⁰。

綜上所述，在法律上確立的保全措施，即使其無程序上的獨立性，必須謹慎地使用及認真、公正及快捷（但可能草率）運用。故希望找一個平衡點，將公正與和諧及快捷相協調，希望盡可能對前述每一種價值產生最少的影響。

⁵⁹ 見 Elio Fazzalari 著之《法學百科全書(Enciclopedia del Diritto)》，第三十七冊，第 341 頁。

⁶⁰ 見 Antunes Varela 教授《民事訴訟手冊》第 2 版第 27 頁。

第二編

訴訟（程序）法律理論

第一章

民事訴訟法

8. 民事訴訟法之概念

掌握了一些介紹訴訟法之概念後，尤其是關於其不同之部門（一套以其客體作區分之規範），並扼要地指出了民事訴訟法之初步概念後，現在須繼續深入探討這個概念。

民事訴訟法，或簡稱為民訴⁶¹，屬於在功能上填補民法、商法，即私法之一門法。

倘法包含一套規範私人之間或私人與公共實體之間（非在行使統治權時）之關係之法律規範，民事訴訟法結合了規範民訴之類型、形式及要件之規範，還有在提起訴訟及訴訟進行過程中應遵守之手續⁶²。

換言之，民事訴訟法是規範民事訴訟程序、起訴之要件，以及隨後當事人、法院、訴訟輔助人及其他參加人在訴訟中開展活動之一套規範，目的是獲得一個具有約束力之裁判。

作為一個程序法部門，民事訴訟法包括民訴之類型及要件，關於訴訟前提之規範（進行實體問題判決之要件），包括了民事程序之形式主義或程式之規範，規範實施行為之形式、時間、地點及順序之規範。

在規範民事訴訟程序之餘，民事法規定在普遍及抽象性方面由實體法授予權利之保護方法，透過法院將這些實體規範適用於具體個案而進行。

在不同層面言之，民事訴訟法是為民法服務，故向其提供運作所需之原材料。

9. 民事訴訟法之特點，程序法律部門及公法部門

之前我們談到審判功能之不同部門，每一部門有一個相應之特殊規範。

這些不同部門法分別可因其標的及介入程序之當事人之身份而確定私人或實體（民事訴訟程序）；一個私人與一個國家——公共行政機關之據位人（行政訴訟程序）；國家——作為代表集體之一般性利益（刑事程序）。

這些區分並無排除這些程序法部門間之互補性，例在民事程序內審定一個只有刑事或行政法院方有管轄權之問題（《民事訴訟法典》第 27 條），或在刑事程序內就一項與刑事責任有關之民事責任賠償（經 9 月 2 日之第 48/96/M 號法令通

⁶¹ 見由 Salvatore Satta 著之《法學百科全書(Enciclopedia del Diritto)》，第十二冊，第 1100 頁，指出“民事訴訟法”這一詞非常新，因為拉丁文化之傳統是使用“民事程序”這一個詞。

⁶² 見 Antunes Varela 教授《民事訴訟手冊》第 2 版第 7 頁。

過之《刑事訴訟法典》第 74 條)。

一點也不足為奇，這些審判部門法之間存有一些共通特點，而作為程序法整體亦存有某些特點。

通常強調程序法之輔助性。

但我們應如何理解這門法之輔助性？

民事訴訟法並非是調解利益衝突之法律規範，通過這一部門法並不能為某個財產的所有權、占有之類的問題給予答案。這個解決方案是由民法之規範以普遍性及抽象性之方式提供，而《民事訴訟法典》提供之具體解決爭議所需之途徑。在實體權利之保護層面上，程序法僅作為一個途徑或工具，並以之作為標的，通過有關程序以維護正當之實體利益。

依此見解，明白到程序法與實體法相對稱之名稱，亦清楚知道輔助性乃主觀狀況及可能提供保障或通過法院確認其權利兩者間關係之結果。

再者，

可對程序法之輔助性設定等級，即：

1. 在某些情況下為某特定主觀狀況提供唯一之實踐途徑（例在《民事訴訟法典》內，收養）。
2. 在其他情況下，引用訴訟程序形式是因為實體關係以外之事實所引致之一種選擇。

在第一種情況下有第一級輔助性或主要輔助性；在第二種情況下有第二級輔助性，因為解決相對立之利益亦可透過非司法途徑進行（例在民事程序內通過財產清冊程序對遺產進行分割）。

但須注意：程序法這一名稱並非完全等於一般單純形式之法。在開展程序時對一些細微手續之遵守並不構成《民事訴訟法典》之核心⁶³。

法定程序及形式主義（使程序具一定莊嚴性），屬於必要及必須遵守之要件，以達到程序之目的。但《民事訴訟法典》並不限於此：亦包括對非常重要之事宜之規範，例訴訟前提——並非反映在程序進行過程中所作出之行為，而是關於這個程序之前的“一些事情”。輔助性與形式性並非《民事訴訟法典》之一個相同特性⁶⁴。

作為一部門法，程序法是一門公法。

⁶³ 在過去之某個時期內，視民事訴訟為較不重要之事宜，而民事訴訟法僅包括規範程序形式之規範（見 1876 年之《民事訴訟法典》），Palma Carlos 稱此為“形式／程序”。今日這些意思已過時：因為民事訴程序之規範除了管制程序形式之事宜外，還管制其他重要之事宜。

⁶⁴ 關於民事訴訟程序之輔助性質，Manuel de Andrade 教授指出：“訴訟法律並無規範屬我之物及屬你之物，並無指出屬於某個人之物；亦無規定每個人之財產，但只管制在法庭辯論之模式”。

這句精景之說話載於該科英布拉教授著之《民事訴訟程序之基本概念》。

另外，Antunes Varela 教授亦談及其民事訴訟法之輔助性（程序性）：“……僅規範取得當事人之間之衝突之解決方案，或滿足實際被侵犯之權利，此為源自民法之解決方案，但同在抽象或普遍層面上所定解決方案無關”（見《民事訴訟手冊》第 2 版第 8 頁。）。。

我們深入探討關於區分公法與私法之理想標準，可以指出即使是為了補充兩門私法（民法及商法），今天，《民事訴訟法典》毫無疑問是一門公法範疇的法律。

按照一般法律學者接受之標準，公法包括管制其中一個主體行使統治權之法律關係。此亦見於訴訟關係內：法官在這種關係內行使一種職能——審判職能。（根據《基本法》，在澳門特別行政區內，雖然主權是屬中華人民共和國，但審判權是由澳門法院行使。）

即使對於某些人來說，正確之區分是以有關規範所保護之利益之性質為準，對於《民事訴訟法典》之性質無任何疑問存在，因為除了當事人之利益外，還有群體利益及社會和平之利益是需透過良好管理司法的法院而進行的。

將程序法定為公法部門在學者之間是無一致見解的。部分意大利學者，以 S.SATTA 為首，得出下述之結論：程序法並非公法，亦非私法，而是一門異類法。因為當中包括多類型之規範：強制性規範、處分規範，補充規範，而公法之規範應全部為強制性的規範（依該訴訟法學家之見解）。

今日這個理論已過時，即使仍有一些程序法規範，其適用可被當事人合意排除（補充性規範）。

但在上述有限之範圍內，意志元素之重要性與法官行使主權職能並不發生衝突，亦不與聯繫著程序之公共利益之總方針發生衝突。

現在我們將關於一般程序法特性所述之內容搬到《民事訴訟法典》上。

作為一門程序法，其包括訴之類型及要件之規範，尤其是在向法院提起訴訟及其發展要遵守之模式，亦包括訴訟前提及程序形式，作出有關行為時要遵守之形式、地點、時間及順序⁶⁵。

無論如何，《民事訴訟法典》——基於利益之私人性質，比較其他審理的公共利益較明顯的審判程序是有更多可處分性規範。

最後，在此似乎有需要作出一個忠告。

是按規範之標的（客體）而決定法律規範（實體或程序）性質，而非法律規範所列入之法規而定。

有許多實體規範被列入《民事訴訟法典》之條文內，例如關於破產第 1047 條及之後數條，同樣亦有程序規範載於《民法典》內，尤其是第 1540 條第 3 款（要求法院批准使用前配偶之姓氏之請求．．．），第 1631 條（兩願離婚之首次會議），第 1647 條第 2 款及第 1648 條第 2 款（離婚之效力）。

10. 民事訴訟法之重要性

10.1. 理論方面重要性

鑑於這門法之輔助性，如將民事訴訟關係之特點與實體法法律關係相對照，因而得出一些問題對法學理論學者而言是重要的之結論並不困難。

最低限度自十九世紀中葉起，《民事訴訟法典》成為了一門真正的科學，放棄了訴訟僅規範形式之想法，以及僅限於一個僅對法律工作者有用之想法。

⁶⁵ 按照 Manuel de Andrade（見 Antunes Varela 教授《民事訴訟手冊》第 2 版第 28 頁）之見解，此為臨時及非嚴謹之概念。

雖然今日承認訴訟關係相對於實體關係之不可爭議的事實，亦較為簡單，但在時間適用上則比較實體關係受到更大之限制。

即使如此，極複雜之程序問題仍然不少，葡國等外國著名學者在繼續深入研究這些問題之同時，為爭議之學理提供了大量材料。

毫無疑問，鑑於對終局裁判、程序正當性、事實事宜與法律事宜之區分⁶⁶之研究增加，使得法律學理豐富起來，而關於訴權之法律性質之問題更不用多說。

此外，是在民事訴訟法之範籌內最能深深反映出法相對於其他調整社會生活之規範之特性：強制性。Manuel de Andrade 教授指出“民事訴訟程序同法律具體實踐之程序有關，尤其是當實體規範無被私人自發性地遵守時”。

由此可見其對正確地認識法律精華之重要性，使對法律之基本概念有一個更全面及穩固之理解，此為在法域內穿梭各個邊疆所必需之知識。

10.2. 實踐重要性

《民事訴訟法典》之實踐作用並不小。

在正確適用規範時，可對由原告提出之請求產生決定性影響。

對《民事訴訟法典》規範之無知或認識不足及援引程序不正確可危及原告之請求，並對訴之進行產生負面之影響。

可以肯定的是，作為司法行為準則之《民事訴訟法典》是在過分重視形式主義多於訴訟結果之形式主義時代裏不遵守某些手續所可能產生之損害會比今天訴訟關係主體產生之損害更大。

現在，我們可以指出，自 1926 年開展改革之後，這種危險之範圍大大減少了，且曾將與這種改革之理由相反之理論，則自始確保對實體法規範作正確解釋及適用，以達到實質公正之結果。

因訴訟法律適用不當而產生不利裁判之後果自始大大減弱，但仍不能完全消除。

作為不遵守程序規範而產生之不利影響之例子，我們可以引用《民事訴訟法典》第 405 條第 1 款之不到庭之效果：倘被告不於為此設定之期間內答辯，視為承認原告分條縷述之事實，或同一法典第 582 條之規定：不於法定期內就判決提起上訴，轉為確定判決後，即使敗方有推翻裁判之依據亦不能再提起。倘進行上訴，則可能在上級法院取得有利判決。但如不上訴，則必定敗訴。

但因疏忽適用程序法律亦會產生不利後果，除涉及當事人之外，還可涉及提供法律服務之律師、負責作出某些程序行為之公務員及應該指導或審定訴訟活動之法官。

甚至在許多情況下，在程序內之某種行為產生之不利之效果可反映在金錢上，例如，在無需要之情況下請求對權利作出宣告或保護之附隨事項之當事人：由其承擔訴訟費用。有別於作為通則由請求之當事人承擔，而非敗訴方承擔，這樣有別於一般之規定（《民事訴訟法典》第 378 條第 1 及第 2 款）。

此為對這個《民事訴訟法典》理論及實踐問題所作一個簡短探討，今日基本

⁶⁶ 按照 Antunes Varela 教授在 1991 年 3 月在澳門之一個研討會上所述：這種區分已出現危機。

上已有統一之見解。

11. 《民事訴訟法典》規範之解釋及填補

11.1 訴訟程序法律之解釋⁶⁷

一如任一法律部門般，在適用法律時必須面對解釋法律的問題。

這種由應用法律者之一種預先活動，目的是確定包含在法律文本內之規範之真正意思，特別是當其文字包含多個意思時，最低限度，從這些文本中得出規範之意思，透過一定形式而將內容反映出來（與立法活動恰巧相反）。

法律規範（包括民事訴訟之規範），由於屬於普遍性之宣示，或多或少並不完整，並不能完全預計在日常生活裏包括所有人類可能作出之行爲。

對法律規範之理解往往出現疑問，引致在實踐方面出現爭訟；所有這些對於法律規範之理解之疑問及不確定皆透過《民事訴訟法典》第 562 條第 2 款之規定由法官解決：對抽象法律作出解釋、填補及將其適用於具體個案裏。

然而，如眾週知，解釋法律之活動並非隨意進行之活動，其必須遵守使條文意思盡可能統一之一般性指示。

關於廣義之法律解釋方法（成文法規範之解釋及填補）之一般性原則載於《民法典》第 8 及第 9 條內，對這兩條條文學者們有很多批評。

其中所定的並非單純之邏輯標準，而是針對法律應用者之謹慎任意性而設，這些規範係真正之約束性規範，指明了所使用之方法及欲達之目的。

我們暫時不深入研究這個問題，但必須澄清這些條文之規定完全適用於訴訟程序法律⁶⁸。

一方面，在訴訟法律內無訂立任何關於解釋程序法之特別標準；另一方面，訴訟法律關係之特別性質亦無強制要求訂立一套有別於一般法律解釋制度之標準。

然可存在一種特殊情況，訴訟法律解釋者及適用者須緊記：民事訴訟是由一套基本原則組成，在我們研究時須小心及從狹意解釋與這些原則有偏差之任何例外規範。換言之，所有同上述原則不協調之規範不應用廣義解釋⁶⁹。

結論：在解釋程序法律方面，法律工作者應跟隨《民法典》第 8 條所定之方法進行，嘗試將公正之利益及包含其他利益在內之法律秩序之發展與法之確定性及法律行爲之安定性之利益互相協調。

11.2. 程序法律漏洞之填補

⁶⁷ 關於法律解釋之課題，有大量著作可作參考。值得強調的有《法律解釋理論初探》一書（Maunel de Andrade 教授之博士論文），見於《Coleção Studium》一書中，並附有 Francesco Ferrara 之作品之譯文，題目的為「法律之解釋與適用」。還有由 Alessandro Groppali 著由 Manuel de Alarcão 翻譯之《法學入門》（第 3 版），第 229 頁及續後各頁，科英布拉出版社，1978 年。

⁶⁸ 這個法律學科關於程序法律規範之解釋及填補漏洞之規定，對於理解在時間與空間之適用問題亦適用。

⁶⁹ 記得：限制解釋乃解釋之一種形式，因應解釋活動之結果，除了一致解釋及擴展解釋外，其亦列入分類之內。

一如民法範圍內，程序法律之解釋——適用者在工作時可能面對在規範上出現缺項之漏洞情況。

在法之具體適用方面，曾對於某些毫無疑問地應受到法律保護之情況、但對之並無設置任何法律制度加以規範時，則存在一法律漏洞（lacuna）：

1. 無論是因為在公布法律時無預見有關之情況；
2. 或在作出規範時（較為常見、且難以避免）之錯誤；
3. 又或者對在學理上仍未明確之情況，難以用普遍及抽象方式加以管制，使立法者果斷地放棄對這些情況訂立任何規範制度。

由於在我們之法律制度明示禁止法官以法律無規定為藉口而拒絕審判（《民法典》第 7 條第 1 款），然而面對上述問題時，法律上如何解決？

無論在解釋方面，或在填補漏洞方面，《民事訴訟法典》並無訂立特別制度，而是適用填補法律漏洞之一般制度。

《民法典》第 9 條所定之規定是完全適用的，故此可以指出：缺項是按適用於類似情況之規範處理，在無類似之情況下，則解釋者在按照法律制度之精神，亦即是說，按照其風格、特定形式及制度之一般取向，好像自己在立法般自行創制規定⁷⁰⁷¹。

有趣地，Manuel de Andrade 教授提醒我們留意下述的情況：“原則上，無任何理由可以妨礙類推適用其他程序法律規定以填補民事訴訟法律之漏洞。”但他還道：“這種情況很罕有，因為在此情況下，因無一種真正之類推性存在。相反當其他程序法律不完整時，該些法律規定援引民事訴訟法律作為補充規定。”⁷²⁷³

然而，事實就是《民事訴訟法典》之適用者常發現現行規範欠缺有關規範，故必須面對填補法律漏洞之問題。

雖然可舉出部分例子澄清這種情況，但就立法者應對某一些事宜立法律保護而不作為之情況，較佳的方法是將這種研究留待予其他學科。

12. 訴訟法律在時間上之適用⁷⁴

12.1. 對問題之衡量

《民事訴訟法典》一如在其他任一法律部門般，因有一新法律生效而改變了對程序之重要內容之規範。

如此，需決定每一條法律在舊法及新法生效之間的繼受問題，或換言之，必需在時間上界定每一條法律之適用問題。

⁷⁰ 這個立場基本上與瑞士《民法典》之理論一致。

⁷¹ 這條規範在民法及民事訴訟法內有效，但刑法內則不同，主要是因為事宜之條件限制。

⁷² 例經 3 月 16 日第 14/87/M 號法令通過之《澳門民事登記法典》第 187 條，其標題為“補充法”。由上文所述之特點中可得知民事訴訟法規範之輔助性質。

⁷³ 見（《民事訴訟概要》Elementares de Processo Civil）一書，科英布拉出版社，1979 年，第 39 頁。

⁷⁴ 關於這內容，見 Antunes Varela 教授（《民事訴訟手冊》Manual de Processo Civil）第 2 版第 45 頁。

當將這個問題由私法方面轉到《民事訴訟法典》時有特殊性存在。這方面與法律解釋及填補漏洞之內容不同。然無論在任一方面，可從多個角度理解該問題：法律在時間上之適用；法律之有時限適用，法律適用之時限範圍；法律之繼受；法律適用之時間層面；法律在時間上之衝突。上述的陳述皆僅反映出一個相同之核心問題。

例如：在同一個國家法律秩序內，基於某個具法律重要性之狀況的一個或多個元素先後與在不同期間出現之法律規範有聯繫，而這些法律規範是以不同之方式規範相同狀況者。那麼應適用哪一條法律？舊法或新法？或倘可能是兩者同時適用時如何適用？

法律工作者面對上述情況之可能性在過去很小，但今日這種可能性大大提高了，因為需要將法配合社會生活之急速演變。

倘相對於實體法這是正確之言論，在程序法內出現這種問題之可能性就更大。一如我們所知般，程序是指一連串在時間上較緩慢開展之行爲組成，故特別容易受到法律在時間上衝突之問題影響。

爲了決定適用之法律我們應考慮哪個連結元素？

民法所定之制度或一般性指引可否引伸至程序法？或在程序法律內有否關於這個內容之特別規範？

在程序法範圍內，最低限度可以想象：法律在時間上適用之問題可出現在三個時間內：

1. 爭議之法律關係之成立時；
2. 起訴之時；
3. 在程序內作出某個行爲之時。

即是指新之法律可以在實體法律關係成立時出現——在這種關係內產生利益衝突，及在提起有關訴訟時出現，或在司法程序開始後出現。

爲了解決這個問題，可以選擇透過一條衝突規範以決定適用之法律規範，或透過一條過渡規範以解決兩條法律之過渡適用問題。

人們所稱之過渡性規範⁷⁵可放在某一種法規內（特別過渡性規範），以確定該法規內之新規範之時間範圍；或列入一法律文本內，使之對所有新法律皆有效，或對規範某些事宜之法律有效。後述之過渡性規範稱爲一般過渡性規範。

倘法律無作任何規定，須跟隨學理爲決定管制跨越多條法律範圍而定之一般標準。

此爲問題之資料。

12.2. 適用之一般理論

在民法方面，學理一致認爲通則是新之法律只適用於將來，並不適用於過去之事實。

此爲《民法典》第 11 條所規定之內容，該條文所提供之指引亦適用於刑事歸責之法律方面(澳門刑法典第 2 條第 1 款)。

⁷⁵ 某些人反對這個用語，因爲其適用之過渡性在實踐方面時間可能非常長。

在私法方面，雖然承認新法相對於舊法而言，是一種進步之表示，“認為在商業法律行為上，使人們受制於在事實形成時不能預見之後果是不公平及不適當的。”⁷⁶

各事應受其發生時生效之法律管制。

此稱為“過去事實論”——但無需考慮成因事實，且受法律規定之法律狀況除外。例如關於配偶間之人身及財產關係之某些方面。

當將這個問題轉移到《民事訴訟法典》方面，具有他本身之特殊性。“一條新之程序法律亦立即適用於已提起之訴訟中於新法生效後所作之行為”——Manuel de Andrade 教授指出。

一如在分析解釋及填補法律漏洞方面之事宜般，這個解決方案似乎受一個原則支配（相對法律總論而言）。

但如何？且看看：

José Alberto dos Reis 教授用下述方式提出問題：

“支配程序之法律在時間上適用之原則就是：此乃基於程序本身之性質，訴訟程序法律即時適用，即新法律適用於所有自該法律生效後需實施之行為。”

理由在於：“所述之原則乃源自訴訟程序法律本身之性質……訴訟程序法律最終乃述及行使一種國家職能——審判職能……；當公布一條新法律時，表示國家視舊法律對掌理司法或管制司法權之運作欠缺完整及有缺點。此足以使新之法律立即適用⁷⁷”。

另一個面，Manuel de Andrade 用三個理由指出訴訟（程序）法律立即適用原則之理由：

1. 基於民事訴訟程序之公法性質——新法律有意更佳地規範同這門法有關之公共利益，為此有立即適用之便利；
2. 基於民事訴訟程序之輔助性質——因為新法律只改變各方當事人在法院內保障自身權利之方法，為此“新訴訟程序法律立即適用之可能性並無影響當事人之財產，亦不影響實體法對利益衝突而定之解決方案，更無損害當事人之任何期望……”。
3. 基於這個原則默示地包含在所有法律內：法律只為將來而設。“此原則適用於程序上正反映了不同之程序行為受行為作出時生效之法律管制。”⁷⁸

原則上所有法律皆是立即適用，所有法律開始生效便適用。但在適用時要尊重舊法規範之過去事實，按照《民法典》第 11 條之規定，新法律應該以不溯及既往之方式適用。

此亦適用於《民事訴訟法典》。

雖然這個原則無概括及明示地表達在《民事訴訟法典》內，但亦無被排除，

⁷⁶見 Antunes Varela 教授(《民事訴訟手冊》Manual de Processo Civil)第 2 版第 47 頁。

⁷⁷ 見《通常及簡易程序》第二版，第 32 頁。

⁷⁸見 Antunes Varela 教授(《民事訴訟手冊》Manual de Processo Civil)第 2 版第 42 頁。

甚至在某些規定內我們可找到這個原則之體現⁷⁹。

似乎在程序事宜上亦適用時間管制行為之規則：每個行為受作出行為時生效之法律規範。

但這個規則仍不足夠。

第一個保留是要考慮為程序事宜所定之特別規定。因此要尊重這些規定之內容，而不引用一般性原則或學理標準⁸⁰。

但肯定的是：雖然通則是新法立即適用，但訴訟程序法律無溯及既往效力，其理由在於一個古舊原則：“所有溯及力皆為一種不公平”。

為了不產生溯及既往之效力，程序法律應該尊重：

1. 在舊法生效時作出之行為之法律價值（之有效性）；
2. 在舊法生效時有效作出之行為之主要實際效力；
3. 在舊法生效時形成之既判案；
4. 按舊法已確定之既得權利。

確保任何上述一種價值之需要可引致在新訴訟程序法律立即適用原則之問題上訂定例外之情況。

例如，為了尊重首兩項之價值，倘只為避免使過去之行為變成無用或浪費已作出的行為，可使舊法律仍適用於在新法律生效後之行為。

簡言之：

- A. 《民事訴訟法典》無載明關於訴訟（程序）法律在時間上適用之概括性規範，此為相當於《民法典》第 11 條之規範。

為此，學理就載於第 11 條內之過去事實論，就其是否亦適用於程序法內出現爭議；我們認為答案是應適用於訴訟法。

- B. 但在現行《民事訴訟法典》包含具普通性質之規定（過渡性規範），第 13 條關於規範管轄權之法律及第 92 條關於訴訟行為之形式之法律——我們稍後分析這些規範。

在這些事宜上，確定適用哪條法律之問題由程序法律本身所解決。

當新之程序法律包含特別過渡性規範時——僅對其本身在時間上之適用有效，亦能解決有關問題（例：在核准新《民事訴訟法典》之 10 月 8 日之第 55/99/M 號法令之第 2 條，第 6 條，第 7 條規範）。

- C. 在法律無規範之情況下，古民事訴訟法方面學理接受之一般性規定為新法律立即適用⁸¹。

12.3. 特別適用：

A. 關於法院管轄權之法律

我們先指出一些概念，可以說一個法院之管轄權乃指其審判權之尺度，規範管轄權之規範訂立了作為各個法院分配審判權之基礎標準。

⁷⁹ 例如第 92 條——我們稍後分析。

⁸⁰ 我們以《民事訴訟法典》第 13 條及 12 月 20 日之第 9/1999 號法律第 21 條為例子。

⁸¹ 見 Oliveira Ascensão 教授《民法總論》第 80 頁。

但是關於管轄權之規範變更範圍的大小或深淺則較為常見，針對上述而產生的法律繼受的問題上須區分兩類變更：

1. 組織上之變更——成立新之法院或撤銷一個或多個已存之法院；
2. 純職能上之變更——由現存之法院重新分配管轄權。

關於時間適用之問題，倘關於這個內容出現一條新法律，應採用哪個學理？若按立即適用之規定，倘在法院內有一宗待決案，然而公布了一條新法律——將審判該案之管轄權分配予另一法院，待決案理應要移送予另一法院。

但這並非法律所規定者

在《民事訴訟法典》中有一些特別規定關於這事宜：第 13 條——其標題為“規範管轄權之法律”。按照第一項之規定：管轄權於提起訴訟時⁸²確定，後來之事實變更並不重要。

一個在澳門特別行政區可能並不準確的，例子（因澳門的法規並未以區域而區分管轄權），例原告人，向有管轄權法院提起一訴訟，後來原告人遷往別的住所，法院仍有管轄權直至訴訟終結。原則上根據上條第 2 款規定法律變更亦無關重要，除非待決的案件的所在法院被撤銷或法律將管轄權給予一個正在審理有關案件，但其原先無權審理之法院。

在 12 月 20 日的第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》第 21 條中亦載有上述規定。

結論：

根據 12 月 20 日的第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》第 21 條第 1 款及《民事訴訟法典》第 13 條第 1 款之規定管轄權在提起訴訟時確定，並一直維持至訴訟終結，相當於《民法典》第 11 條之規則。

及後即使出現法律變更及事實變更均無須要理會，但出現《民事訴訟法典》第 13 條第 3 款規定情況則除外。

如原先有管轄權之法院被撤銷，或將管轄權授予正在審理有關案件，然其原本並無管轄權之法院時，則按第 13 條第 3 款處理。

B. 關於程序形式之法律

接著我們研究組成《民事訴訟法典》之一套規範制度：規範在提起訴訟及其發展時作出之行爲之規範，以及每個行爲本身之形式及步驟。

在此方面，存有一般過渡性規範（《民事訴訟法典》第 92 條）——使能確定新法立即適用原則完全適用性。

改變訴訟行爲形式之法律生效時，不單包括將來之訴，亦包括在待決訴訟裏將要作出之行爲。

在此我們完全採納新法律立即適用原則：因為《民事訴訟法典》之公法性質及輔助性。

但須作出一個（由 José Alberto dos Reis 提出）忠告，須將規範訴訟程序步驟之法律區分出來。

⁸² 《民事訴訟法典》第 211 條

1. 其就組成訴訟程序之每個行為之形式（獨立之考慮），適用第 92 條第 1 款規定（無例外之情況）；
2. 當規範程序形式（普通或特別程序；通常或簡易程序）時，按（第 92 條第 2 款規定）以提出訴訟時生效之法律為準。

亦很易明白箇中原因：若新法律適用於待決訴訟案——由於較按舊法律所採用之形式為不同，可引致之前實施之行為失去效用，故違背當事人之期望，且溯及既往之效力亦非新法律本身之精神。

但現實是當研究核准澳門新《民事訴訟法典》的第 55/99/M 號法令第 2 條第 2 款規定時會發現：現在之《民事訴訟法典》僅適用於自（1999 年 11 月 1 日生效之日起提起之訴訟程序，而仍待決之訴訟程序，則繼續受現被廢止之法典所規範，但不影響其後數款規之適用。）

C. 關於上訴之法律

上訴是就司法裁判提出爭執之方法，目的是由上一級法院重新審理下一級法院之裁決之問題。

為此，在關於過渡性規範在上訴時之時間適用問題上需區分為：

1. 對訴訟提起上訴，舉證及審判時要遵守之程序規範（參閱《民事訴訟法典》第 587 條）；設定接納上訴條件之規範（例《民事訴訟法典》第 583 條）。

關於第一類之規範，由於屬於處分性規定——僅規範程序形式，不對實體法律關係造成影響，對於新法律立即適用無疑問存在。

關於設接納上訴之條件之規範——可具有很大的影響，甚至是針對實體法律關係，故須小心區分：

- A. 在新法律開始生效之前作出之司法裁判；
- B. 在新法律開始生效仍未作出之司法裁判。

在 A 這種情況下，還可區分兩種細小情況：

- a. 新法律容許上訴，但舊法律不容許；
- b. 新法律不容訴上訴，但舊法律容許，上訴已提起或還未提起。

在這兩種情況下，新法律皆不立即適用，否則既存之裁判轉為具有一種依作出裁判時生效之法律中並不存在之價值，相當於新法律溯往生效。

在 B 這種情況下，關於仍未作出之司法裁判，似乎很明顯應採用新法律立即適用之一般性原則。

但是我們亦需留意核准澳門新《民事訴訟法典》的第 55/99/M 號法令第 2 條第 6 款關於上訴之規範（及澳門特別行區的《司法組織綱要法》第 72 條及隨後數條的規定。）

D. 關於證據之法律

我們先認識證據之概念

證據指法院用以查明爭議之事實之方法，而按照適用之法律規定，這些事實

對案件之決定屬重要之事實⁸³。

規範這事宜之制度總和稱為證據法，通常分成兩類：

1. 實體證據法——包括設定可採納方法之規範、以證明事實真相及確定每一項方法在證明事實時之價值或證明力；
2. 形式證據法——指如何在法院舉證規範之總和。

爲了嚴格界定新法及舊法生效之範圍，似乎界定這兩類規範之真正法律性質十分重要，此爲在學理上最具爭議點之焦點之一。

由訴訟法學家理論（認為無論是實體證據法或形式證據法規範皆爲程序性法律規範），以至中性理論——對上述立場引入限制，事實就是對大部分法學理論家來說，實體證據法規範載於《民法典》內（第 334 條及續後），而形式證據法載於程序特殊規定內，具有輔助性質。

選擇一個在某種程度屬於中性之理論，難免會被認為倘新法律規定關於不同之證據方法如何在法院舉證之事宜，即受新法立即適用原則約束，不單適用於將來之訴，亦適用於在新法生效時待決之訴，針對所有之證據措施，舉證模式明顯屬於程序之形式。

另一方面，在實體證據法內，鑑於有關規範之內容，我們可區分下列各種情況：

1. 倘新法律是關於採納新證據方法以爲證明一般之法律事實時，似乎無任何東西可阻止新法律立即適用這個原則，即使是爲待決之訴訟案件亦然，因爲相對於舊法而言，無任何需受保護之期望；
2. 倘新法律是關於被採納新證據方法以證明特別之法律事實時，例如，法律行爲（negócios jurídicos），將當事人受制於有別於在作出行爲時之法律規範並不合理，因爲損害了行爲設定時產生之期望。在此，似乎應理解爲仍適用舊法，因爲相反則變相是新法溯往生效⁸⁴。

同時亦需留意在核准澳門新《民事訴訟法典》第 2 條第 2 款的過渡性規定自 1999 年 11 月 1 日生效之日前起提起而仍待決之訴訟程序，則繼續受舊《民事訴訟法典》規範，但及後提起之訴訟程序則適用新《民事訴訟法典》規範。這樣不單爲關於形式證據法律規範在時間上適用的疑問上，亦可以說爲法官在適用證據方法之程序上提供了全面性之解決辦法。

E. 關於司法期間之法律

期間（prazo）是一個應作出一個行爲之時期（período），如在期間內不作出則實施該行爲之權利消滅，屬於行爲期間或解除期間。

但期間亦可以是爲開始計算另一個時間而設之一段時間：中間期間。

兩者之分別載於《民事訴訟法典》第 95 條內，該分別是十分重要。

⁸³ 有關事實內容部分將留待討論普通訴訟程中研究。

⁸⁴ 關於這一問題有不同之立場：見 Anselmo Castro 教授在 “Direito Processual Civil Declarações” 第一冊作品第 64 頁至第 70 頁；見 Antunes Varelhas 及 Manuel de Andre 教授在提及之作品第 61 頁及第 47 頁。

倘一條法律改變司法期間，如何解決時間衝突？

《民法典》第 290 條提供了一個一般性指引：通則是新法律直接適用，但在計算期間時要遵守一些特別之處。

如此：

1. 倘新法律縮短或延長一個中間期間，無特別問題提出來，分別適用《民法典》第 290 條第 1 款及第 2 款：新法律適用於進行中之期間——一如第 290 條所規定般。倘按照縮短中間期間”之新法律，期間已完成（有別於舊法之規定），自新法律開始生效之日起視該期間已屆至。
2. 倘新法律延長一個行為期間（prazo peremptório），新法立即適用，然而期間自起始時起計算已過之時間。
3. 倘新法律縮短一個行為期間，立即適用於進行中之期間，但期間只自新法律開始生效時才開始計算，除非因此引致期間之延長，在此，情況下則仍適舊法。

在此制度內需常記不損害當事人之正當期望，即不應與《民法典》第 290 條之精神相反。

這個一般性指引（制度）通用於《民事訴訟法典》，因為無被排除之任何理由。

當適用時亦需整體地考慮有關制度，例如在《民事訴訟法典》清楚可見之任何分離的理由是已考慮過渡性之規範在有關期間內適用法律繼受的問題。

但在理解上述的事宜時是可以從載於核准澳門新《民事訴訟法典》第 2 條第 4 款規定內找出相關的答案。

13. 程序法在空間之適用

13.1 問題之提出

只要某一個法律關係的結構元素與不同國內法律有連繫，即與不同國家之法律體系有聯繫，則這一法律關係可以被稱為跨地域之法律關係，並須透過法律從該關係與那些法律有聯繫中選出最合適的則該被選定的規範制度為優先適用。

然而，我們在上文所分析之問題，是指法律在時間上連續出現，但僅限於在適用一國家法律秩序內。現在所談及之問題並不相同：出現兩條或更多相對照之法律，所有皆在生效中，同時橫向地與不同之國家空間有聯繫。

同法律關係有聯繫之法律彼此間對這種關係產生規範之競合，即為法律之衝突。此為國際私法之主要客體，其規範稱為衝突規範，作為指示對某些關係之規範之“明燈”。此為《民法典》第 13 條及續後所規定之情況。

其中所包含之情況在實體法內為常見的，只要是基於全球各國間合作所致。

然而，倘實體法律關係將在法院內討論，並有意就一種同多個國家法律秩序有聯繫之關係獲得司法保護，哪個民事程序法律適用？

13.2. 法院地法原則

對一般法律來說，今日實行地域原則：來自一國機關之法律原則上僅在該國領土內適用，乃基於主權原因。

但在這方面可以指出《民事訴訟法典》受《民法典》啟發，依部分學者之意見，民事訴訟法有一個特殊性：在其他規範中有通則之偏差情況，但在《民事訴訟法典》內無任何載於法律內之例外情況。

依此理論，程序規範僅限於地域適用；必受法院地法管制，此表示一國之法院只可適用國內程序法律，不能適用他國之法律，即使一訴訟案在主觀及客觀元素上與一個或多個不同之國家有聯繫。

澳門法院僅適用於在澳門特別行政區生效之程序法律，即使案中當事人或其一方是中國公民、泰國公民、印尼公民、菲律賓公民亦然。根據《司法組織綱要法》第 1 條第 2 款規定澳門特區法院，除《基本法》第 19 條第 3 款所規定的國家行為外，澳門特別行政區法院對澳門特區所有的案件均有管轄權。

這個程序法律地域原則——在《民事訴訟法典》中並無明示表示，但可以在第 15 條、第 16 條、第 17 條、第 1199 條及在許多其他規範中找到。

很易解釋這規範之理由。

倘對一法院之組織及結構之規範由國家負責，其運作之規範法律亦應是該空間內之法律。按照每個國家之觀點，其程序法更有能力保護公共利益——此為程序之優先利益。此外，鑑於程序之工具性，法院地法不會適用被採用之實體法之程序規範制度。

然對於在意大利學者間出現之某個學理來說，他們認為地域規則乃基於審判權之行使，是國家主權行為之其中一個表現方面。

為此，法官在其領土內行使其權力，須適用當地之程序法律。

13.3. 特別情況

地域原則不會為程序法律開立任何例外情況之意見得到我們支持，亦得到 Adelino da Palma Carlos 及 José de Castro Mendes 兩位教授之支持。

但 Anselmo de Castro 則持不同之理解：接受有例外之情況。法院地法律適用之規則是受限制的，並指出澳門舊之《民事訴訟法典》第 187 條第 2 款之規定：其中法院須遵守由外國當局請求之手續形式，只要不違背葡萄牙法律即可。關於規範證據之採納及價值之法律規範，因有對實質內容有一定影響，在適用上應適用行為地法原則，即訂立行為地之法律。

然而對 Palma Carlos 教授來說，上述情況只不過是地域原則之表面例外情況（適用於程序法律）⁸⁵。因為在這些情況下，葡萄牙法院適用一條外國法律，是基於葡萄牙法律本身容許這樣做。

按照這位教授之意見，當在葡國承認在外國有效地實施之程序行為之效力時，情況亦一樣，葡萄牙法律對由外國法院所作之判決給予這種效力，經中級法院複核及確認後方具有執行力（葡現行《民事訴訟法典》第 49 條第 1 款及第 1094 條及續後；澳門現行《民事訴訟法典》第 1199 條及續後）。

真正之例外情況只有一個，並非法定情況，而是約定情況，透過仲裁庭，指

⁸⁵ 現已不適用，即使在葡國法院，當審理有關之法規與葡國法規產生衝突時，亦不一定採用葡國法律準用之外國法規。

明時間及應遵程序（6月11日之第29/96/M號法令——廢止舊《民事訴訟法典》第四卷），故當事人可引用一條外國程序法律。

在尊重這些意見之餘，似乎是基於相同之理由，關於舊《民事訴訟法典》第187條第2款，在採用仲裁庭之情況亦一樣，當事人行使法律賦予之權能（在法定限制範圍內）。

最後，這種情況，倘是地域規則之例外情況，將會是法定之例外情況，或嚴格言之，並非一種例外，一如上文所述之其他情況般。

我們感興趣的是強調由法律接受之法院地原則之相對性，即適用於民事程序法律之地域規則之相對性。

第二章

民事訴訟法之淵源及近似之內容

14. 葡萄牙民事訴訟之歷史形成⁸⁶

14.1. 這個內容之重要性

對法學的歷史研究，不論是那一部門法，皆有不否定之理論及實踐作用，此番言論並非新意。

意大利學者 Allorio 在探討「研究程序法之歷史意義⁸⁷」這一題目時提出如此忠告：“有需要使法學史，尤其是近代之法學史，並不限於指法律公布之歷史……”。

關於葡萄牙民事訴訟法，是科學與教學之產物，對其研究有助於認識這門法之演進及其各種制度。

14.2. 認識葡萄牙《民事訴訟法典》之淵源

A—狹意之民事訴訟（非商事）

a. 1876 年《民事訴訟法典》之前之情況

當時有許多法律文本——是法典化之前之民事性質之規範。

在更遠古的時候，當時葡萄牙仍是君主制，作為皇朝之一般法律是採用了 Visigótico 法典，及規範整個伊比利安半島基督徒之紀律制度。但逐漸以地方性立法為優先，出現 forais（地方法律），這些文本無提及司法組織，亦無同其有關之內容。

當時由君主以口頭方式解決私人利益衝突，無須遵守既定的形式，亦無法院存在。

然而，隨著德國之傳統程序由一個公開的口頭及形式主義，開始被廣泛使用。當時提起程序之主動權屬於當事人，即使在刑事方面亦然。審判者僅擔當一個消極角色，仿如觀眾目睹原告人與被告人間之爭鬥般，並按衡平原則審判，再加上一般性法律、地方性法律及習慣法作為調節適用。

這種私人性之制度亦重複見於 1876 年之葡萄牙《民事訴訟法典》內。

隨著公共權力之確立，審判者開始加強了在組成之程序行為之主動性，例已由法院書記傳喚被告人到法庭，但仍很罕有地用書面形式作出判決。

這種演進，亦伴隨著政治制度之演進，開始採用一個在技術上較為完整之一個程序模式，同時出現了受天主教法及羅馬法啟發之國家立法。

在葡萄牙第一個皇朝年代裏，發展起關於程序之行為及環節；但仍未著重司法組織。但皇朝舊法律及習慣之生效；除了引用羅馬法作為補充法外，在實踐上出現許多困難及矛盾。

⁸⁶ 見 Antunes Varela 教授《民事訴訟手冊》第 2 版第 27 至 41 頁。

⁸⁷ 見《Sistema di Diritto Processuale》。

必須修改當時存在之法規及將其匯編，但只在 Afonso 朝代這項工程方完成了首部法律匯編——後來稱為《亞豐素律例匯編》。

屬於首部皇朝法律匯編，日期是 1446 年。

自當時起，我們可以將 1876 年《民事訴訟法典》之前段時間分成兩個時期：

1. 第一個時期是自由主義之前期——在該段期間將民事程序之行爲及環節收入《律例匯編》內；
2. 第二個時期爲自由主義期間之後——特點是先行實行三大方面之司法改革。

在這個《民事訴訟法典》歷史時期，在葡萄牙出現了兩次《律例匯編》，兩者稱為《律例匯編》(Ordenações)，係用動議制定這些匯編及公布並採用君主之名字而命名。

兩部律例匯編(《馬奴利拿律例匯編》及《菲臘律例匯編》)——皆繼承了《亞豐素律例匯編》之制度、分章、精神及原則，在所有這些匯編內，皆於第一卷內規範司法組織，亦有第三卷關於程序(狹意言之)。

在每部律例匯編內皆包含當時生效之新之法律。

在葡萄牙出現印刷術後，使這套法律現代化及公布之工作更爲方便，故將《馬奴利拿匯編》作第二次印行，第一版在 1505 年誕生。

菲律皇帝一世(西班牙二世)嘗試更佳地掌理司法，建議對民事訴訟進行改革⁸⁸。但後來在《菲律匯編》所定之程序環節遠遠超過當時之需要：形式太多，濫用羅馬法及天主教法之複雜程式，一如部分研究學者指出般：“使訴訟成爲永久性爭議”。

瑕疵、不足及矛盾之多足使人們將第三卷書之內容嘲笑爲“菲律主義”。

雖然如此，《菲律律例匯編》所包含之規範生效了一段長的時間。改革之嘗試不斷出現，但當時之氣候不大利於立法改革，這種情況持續了一段時間。

Marquês Pombal——他能夠在實體法上作出徹底改革，但在程序事宜上就未能獲得同樣之結果；應指出的是 Lei da Boa Razão(理性法律)給予 Assentos(強制司法解釋)強制力——是 Casa da Suplicação 爲統一判例所作之決議。

在 Pombal 年代，在程序法方面出現真正之立法熱潮，此令程序法之適用者之工作十分困難。制定了許多匯編，但結構不佳之菲律之新版本，還有增補篇，但文本十分零散。

直到法國革命之原則開始在葡國實行，自由主義繼而出現。

在自由主義初期，當 D.Pedro 四世宣誓效忠 1826 年憲章時，爲新一輪之司法組織改革奠下了基礎，而其特點早已見於 1822 年之憲法內。成立了審判委員會(Jurados)，由其審定事實事宜，還設有太平法官(juizes de paz)——在將爭議送交法院之前，嘗試調解當事人。

欽定憲章後之政治動盪過後，預備了各種普通法律——由其充實載於該憲章內關於民事程序及其環節之原則。

常將這些法規分成三大類：

⁸⁸ 雖然這部匯編以本國作品爲主，但其名稱則源自菲律一世之朝代。

1. 1832 年之司法改革（由 Mouzinho da Silveira 發起）其核心內容載於 1832 年 5 月 26 日之第 24 號命令（Decreto）內。主宰這些規範之原理是程序快捷性，而創新之處在於確立法官自主及獨立原則，同時成立了最高法院、三間中級法院，以及在法區內成立一審法官職銜。

但律例匯編之某些不足之規定仍適用於具體個案⁸⁹，因為不相信會有一個如此有效率之簡單化程序；為此成立了一個委員會，從其工作中出現：

2. 由 Passos Manuel 於 1837 年促成之新一輪之司法改革，（因需要從新修改司法組織及民事程序及環節，這些事宜以重建司法人員之信心之方式加以規範，當時這些人對 Mouzinho da Silveira 命令引入之簡單化存有疑心及認為過分誇張。

由於又再次採用律例匯編之規範，故情況越來越複雜，這些律例匯編仍然生效，故引致出現：

3. 1841 年之最新一輪之改革（由 Costa Cabral 促成）——廢止與該次改革相反之規定，由於空泛及不明確，對司法人員造成許多不肯定之情況。

由此引致：至 1876 年《民事訴訟法典》開始生效之時（葡萄牙《民事訴訟法典》歷史之三大標記之首），有關之規範載於：1832 年改革之律例匯編之第三卷書內，1837 年之新一輪，改革及 1841 年之“最新一輪改革運動”及後來出現之法律內。

由於“最新一輪改革運動”所出現之遺漏，故有需要透過其他法規，作出修改，還有由其他法規產生之混亂及席捲歐洲之法典化運動，迫使要將許多矛盾之法律進行匯編，故成立了草擬一部《民事訴訟法典》之各個委員會。

b. 1876 年《民事訴訟法典》

在 1876 年公布之葡萄牙《民事訴訟法典》促使用一部單一及有秩序之法規代替大量混亂之訴訟法律。

Alexander de Seabra 法律專家自發性地提出一份《民事訴訟法典》之草案，經多次修正後，透過 1876 年 11 月 8 日之皇室法律予與公布（於 1877 年生效）。

此為葡國之首部《民事訴訟法典》。

新之法典僅包括狹意之民事程序；司法組織事宜仍由“最新一輪改革運動”所規範。

該法典由四卷書組成，其系統編排十分簡單——這種編排已源自 1832 年之司法改革：

“一般之程序；在第一審法院之程序；中級法院內之程序；在最高法院內之程序”。

在當時而言，無疑該法典標誌著一種明顯及不容置疑之改善，一種明顯之進步，可視為一份高質素之作品。

然而亦有一些缺點，例：

⁸⁹ 第 24 號命令撤銷了有衝突之全部舊有法律。

一、過分注重形式：法定程序過多，往往無實際效用，引致形式重於內容。

二、程序過於嚴謹，引致太多不必要之程序活動。

另一方面，無論案之利益值為 30 (reis)或 30 千度(contos)只使用同一個程序，最後在 1907 年才為小額案件訂立一個程序——學理稱此為簡易程序。

另一方面，例外之情況除外，程序必經過法律所定之所有階段，而非如今天般，倘被提交之起訴狀出現明顯的問題後則可作成駁回起訴之批示馬上解決問題，或在提交訴辯書狀期過後，在清理批示內解決之。

三、程序之私法觀念過重，結果引致過分強調當事人處分原則。

過去將程序視為一個僅具私人性質及利益之事宜，任由當事人之意志支配。程序活動僅取決於當事人之引導⁹⁰。法官僅有權限支持這個由雙方當事人進行之“司法搏鬥”，判決並非真正代表個案之〔實質真相〕被解決，而是這場搏鬥（形式真相）之結果。

過分強調當事人處分原則相應的結果就是法官之無自主性或被動性〔德國學理甚至稱此為 Juiz-fantoche（傀儡法官）〕。

4)書面形式重於口頭形式

此不單使程序之行進更加複雜及緩慢，還引致法官只能透過往往為不屬實之報告之間接方法才能認定證據（尤其是證人之口供），不容許法官與證人、鑑定專家直接接觸等……以便對證供之可信程度獲得更清晰之印象。

1876 年之《民事訴訟法典》在 1877 至 1939 年間生效；但在這六十二年內曾出現很大之修改。

除了一些較不重要之改革外⁹¹，我們應特別指出兩項改革：

——1926 年之改革⁹²；及

——1932 年之改革⁹³；

1926 年之改革以 José Alberto dos Reis 之文稿為基礎，同時受到意大利法典草稿之啟發。

這些法源集合了三大基本指引原則：口頭原則、集中原則及法官活動原則，三者今日仍成為葡萄牙民事程序之塑造性結構原則。

口頭原則或者是最重要之一個原則，亦是今日最具爭議之一個原則⁹⁴。

⁹⁰ 某天，一名律師有意押後一宗審訊。他記起了甚麼？他提交口頭申請文件，向書記長宣讀《民事訴訟法典》的條文，由第 1 條起直至使審訊不能在當天進行，而法官則束手耐心地目睹這個場面——此為 1926 年 9 月 22 日第 12353 號命令之報告書，載於《民事及商事修改程序》，第三版，1923 年。

⁹¹ 部分我們已提及，見 1907 年 5 月 29 日第 3 號命令，由 João Branco 公布，創立了簡易程序。

⁹² 透通 1926 年 9 月 22 日第 12353 號命令公布，後來由 1926 年 10 月 14 日之第 12488 號命令修改及重新公布，亦被 7 月 25 日第 13979 號命令修改（這條命令雖然在 1927 年公布，但通常列入 1926 年之修改內）。

⁹³ 1932 年 5 月 26 日第 21237 號命令，1932 年 9 月 29 日第 21694 號命令。

⁹⁴ 見由 Vasco Soares da Veiga 著之《口頭方式》（科英布拉），1961 年。

1876 年之法典基本上以書面程序為指導，因而產生我們在上文所指出之不便之處。

繼 1926 年改革後，在葡國引入口頭原則——自始支配著我們的《民事訴訟法典》。

為了容許法官直接接觸不同之證據方法（直接原則）⁹⁵，某些較重要之程序行為，尤其是調查（舉證）（例：詢問證人）在庭審時（在裁判人面前）以口頭方式進行，通常不作成書面記錄。

集中原則來源自口頭原則，依此原則，以口頭方式作出之程序行為不應在時間相隔太久之情況下作出；相反，應盡可能連續作出（集中地進行）。

在書證制度上，為了澄清疑問或重新記憶事實，任何人可查閱卷宗。但在口頭制度裏，則側重依賴審判人之記憶，為了免使這些記憶過多，聽證應盡可能在短時間內進行。

法官活動原則是詢問原則在現代民事程序內的表現形式，與解決當事人自由地向法官提出之問題之形式有關。

在 1926 年改革之前，直至作出判決之時，法官在程序內並無主動權，對當事人之意志及活動只能採取無自主性態度。在現代程序內，無論是決定作出其認為適宜之行為，或“拒絕其認為屬於拖延時間或無關重要之行為（葡萄牙《民事訴訟法典》第 266 條）”，法官享有主動權。

如此，法官承擔起領導程序之工作。

這些 1926 年改革之主流原則——是次改革將現代民事程序引入了葡國——經改良後成為現行《民事訴訟法典》之各個原則。

現在我們談談 1932 年之改革。

由 1926 年改革所產生之革命十分深化，以致引起了批評及引起了不少問題。這一切都是為了關注連續多次之深化改革（改革中之改革），這幾次改革使程序立法產生混亂。

在 1932 年，為了嘗試克服這種狀態，公布了兩份法令（decretos）——藉此推行 1932 年之改革。

這次改革之主要作用是將分散在多份法規中之規範進行清理及集中，但亦有一種創新功能，因為重新將最簡易程序列入民事程序內及撤銷了商事司法組織。繼這兩份命令後，其他作用不大之各項法令及 1876 年之《民事訴訟法典》一直生效至 1939 年，當年公布之第二部《民事訴訟法典》。

C)1939 年之《民事訴訟法典》

1876 年之《民事訴訟法典》，雖然曾作出修改，但並非規範民事程序之完滿法律基礎，直至 1933 年，由 José Alberto dos Reis 教授負責草擬一份新法規之草

⁹⁵ 一如 Maunel de Andrade 教授所稱般（《民事訴訟程序概要》，第二版，第 243 頁，第 369 頁及 370 頁）：這點內容之原則為直接原則——體現在法官同各種證據來源直接接觸，作為集中，口頭及法官識別原則（法官應主持程序，尤其是預審及審判（倘無其他預審法庭），此為直接原則之必然後果）。

案。

草案提出後，由修改委員會、草案人及當時之司法部長 Manuel Rodrigues 進行多次修改。直至 1939 年 5 月 28 日，透過第 29637 號法令（稱為 1939 年《民事訴訟法典》之序言法）通過了新之《民事訴訟法典》，該法典於同年 10 月 1 日起生效。

這份法典之啓發性原則為 1926、1927 及 1932 年多份命令之各種原則，結論就是：實行真正之公正而非形式之公正。

這個新程序以當事人與法院合作制度為基礎，但以法院之地位為優先。舊有程序出現了徹底之變革，消除了許多無用之法定程序，將程序法統一，將商事程序規範列入同一法典內⁹⁶。

然而，儘管法典之序言法第 4 條包含一個傳統規定（並無作用），目的是避免這種情況⁹⁷，新《民事訴訟法典》在 1939 年頒佈及生效並未完整在這些事宜上之立法。

可以知道：修改《民事訴訟法典》之首份法規（這份法規比法典本身還要早出現）與《民事訴訟法典》同時生效⁹⁸。

繼這份法令後出現其他更重要之法令，使 1939 年《民事訴訟法典》喪失其作為某個法律部門之完整規範之性質；而正是這個性質界定了真正之法典。

D)1961 年之《民事訴訟法典》及後來之多次改革

鑑於 1939 年之《民事訴訟法典》已不合時宜、且產生許多疑問，在 1954 年決定進行修改。

當時這項工作交由法典之原起草人 José Alberto dos Reis 教授負責。

在 1955 年 9 月 2 日，這位教授逝世後，委任了一個委員會，由最高法院法官 Eduardo Coimbra 任主席，成員包括里斯本法學院之 Adelino da Palma Carlos 教授、最高法院法官 Eurico Lopes Cardoso、中級法院法官 Armando Simões Pereira 及 Dias Freire，還有有擔任檢察長職務之 Lopes Navarro 後來後述之成員退出該委員會，補上的有最高法院法官 Sousa Monteiro 及 José Osório 及中級法院法官 António Ferreira Pedrosa（他是署任司法局局長）。

委員會之多次會議內當時之司法部長 João de Matos Antunes Varela 主持——並親自作出最後幾次之修改及調整。

就是從這些作品中產生出 1961 年之法典——由 1961 年 12 月 28 日之第 44129 號法令通過，基於該法令之第 2 條之規定，於 1962 年 4 月 24 日起生效。

按照部分訴訟法專家之意見，例 Palma Carlos 及 Castro Mendes 教授，這並非一部新法典，而只是 1939 年法典之新文本。

⁹⁶ 稍後我們述及這點。

⁹⁷ 將來對民事訴訟法典所作之修改視為法典之組成部分及將修改部分放回原處，而這些修改應代替被修改之條文，撤銷無用之條文或增加條文之方式進行。見 1867 年 7 月 1 日 Carta da Lei 第 6 條（《民法典》，1876 年 11 月 8 日 Carta da Lei 第 9 條《民事訴訟法律》等。

⁹⁸ 1939 年 9 月 30 日第 29950 號法令。

但這並非其他大師之立場，尤其是 Antunes Varela 教授，他們認為這是一部真正之法典。

關於這方面，這位教授指出：

“修改之原意是僅針對一些被司法界批評之解決方案，但最後擴展至全部民事程序事宜，故無論在形式上及內容上皆屬一部真正全新之法典”⁹⁹。

在支持其言論時，這位教授還指出，這部法典有一個全新及更現代化之結構，同時在實質方面，引入了許多新意——關於程序之階段、證據制度、上訴及執行程序等。

在 1961 年之《民事訴訟法典》之後來之立法，值得區分：

——因為 1966 年新《民法典》生效而須配合之立法，於 1967 年 5 月 11 日之第 47690 號法令；

——還有 1974 年 4 月 25 日（葡國革命）運動後之立法，其中有下列之法規，改變了法典之部分條文：這些法令包括有：

——5 月 27 日之第 261/75 號法令；

——1 月 6 日之第 4/76 號法令；

——5 月 1 日之第 165/76 號法令；

——5 月 25 日之第 366/76 號法令；

——7 月 24 日之第 605/76 號法令；

——10 月 16 日之第 738/76 號法令；

——9 月 3 日之第 368/77 號法令；

——9 月 30 日之第 533/77 號法令；

——12 月 27 日之第 513-X/79 號法令；

——7 月 1 日之第 207/80 號法令；

——10 月 10 日之第 457/80 號法令；

——9 月 28 日之第 381-A/85 號法令。

由於四月二十五日革命產生了新的條件限制，葡萄牙政府計劃有步驟地全面修改民事程序立法及製定補充立法。首階段之改革於 1982 年及 1983 年進行，公布了 6 月 8 日之第 224/82 號法令、3 月 12 日之第 128/83 號法令及 2 月 26 日之第 3/83 號法律——後者追認前兩份法規。

當時 Rui Manchete 出任司法部長，由其組成一個修改民事程序立法之委員會，其工作高潮是在 1985 年 7 月 9 日公布第 242/85 號法令〔稱為中間性法規〕——對現行條文內引入了重大修改，這是由葡萄牙引伸至澳門、在《政府公報》上刊登之最後一份法規。

B. 商事程序及其淵源之演進

長期以來，民事及商事案件（後者指源自商業行為之案件）¹⁰⁰享有下述特性：

⁹⁹見 Antunes Varela 教授《民事訴訟手冊》第 2 版第 35 頁。

¹⁰⁰ 1905 年之《商事程序法典》第 4 條規定：所有因商業行為、商標、失損賠償產生之訴及其他法律明示規定屬商事管轄者由商事法院管轄。

1. **審判權之專屬性：**這些案件由專門法院審理：商事法院。
2. **程序之專屬性：**透過特有程序進行審判（商事程序）。

很早前在葡萄牙已有為商事爭議設立之專門審判及特別程序：至少自 Cardel D. Henrique 時已成立“領事法院”（tribunais do consulado）起，或甚至之前亦設有“領事裁判法院”（tribunais consulares）。

在 1833 年公布了《商法典》——草案由 Ferreira Borges 提出。這部法典之特點是包含程序事宜及商事司法組織之事宜。

一如在民法內《民法典》般，因公布 1888 年《商法典》而對商法作出之修改促成公布一條關於商事程序之新法律。

在 1895 年公布了首部《商事程序法典》。由於這是一部在獨裁時代公布之法典，而政府更必須得到國會之同意。後來議會在作出小幅度修改之情況下同意了該法典，在 1896 年公布了《商業程序法典》。其修改對象的是破產之事宜。

在《商法典》第四卷書內規範破產事宜，然而在 1899 年公布一部獨立之《破產法典》。

通過《破產法典》之法令（Decreto）規定重新公布 1896 年之《商事程序法典》，並將破產部分列為其中內容。

為了遵守這條規範，政府在 1905 年公布了一部新之《商事程序法典》——只不過是 1896 年之法典，再加上 1899 年之破產法典及配合 1901 年 4 月 11 日之有限公司法律，還有其他作用不大之法規。

然而趨勢是使商業程序之專屬性消失，無論是狹意之程序特性，或審判權之特性（司法組織之特性）。

首先取消的是司法組織：透過第 21694 號命令之第 1 條（1932 年改革之其中一份命令）¹⁰¹撤銷商業管轄權。所有私法問題（商業及民事）改由相同之法院審理。

在 1935 年將破產事宜從 1905 年之《商事程序法典》中抽出來，形成一份自主之法規：即 1935 年之《破產法典》。

最後，1939 年之《民事訴訟法典》結束了商事程序之專屬性。甚至將《破產法典》列入由 Manuel Rodrigues 教授主持之部級（司法部）之修改議程內。

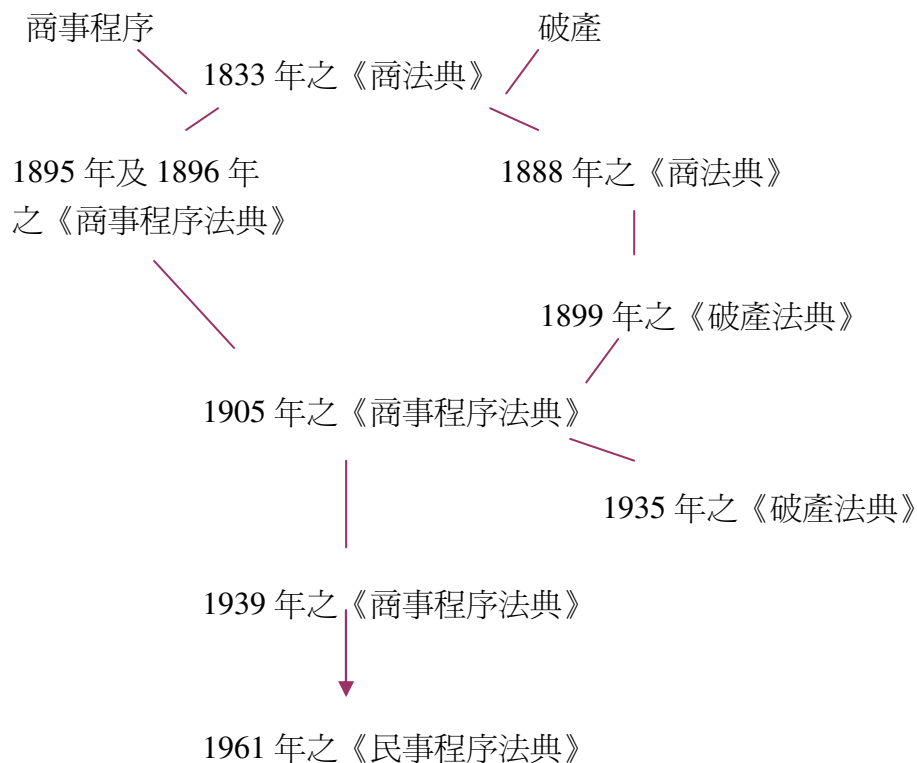
1961 年之法典仍保留這個體系。

簡言之，我們可就商事程序之法定範圍作成下列圖表：

現在我們指出下述關於商事程序之法律基礎：

獨一段：雖然行為屬商業行為，但只同其中一方當事人有關，由此產生之案件受商事管轄。

¹⁰¹ 9 月 29 日。



特別提及澳門¹⁰²

由 1961 年 12 月 28 日第 44129 號法令通過之葡萄牙《民事訴訟法典》於 1962 年 4 月 24 日在葡萄牙大陸及其群島開始生效（按其序言法第 2 條之規定）¹⁰³。

於 1963 年 1 月 1 日於澳門地區生效¹⁰⁴。

由當時至今對已多次對文本作出修改。

在 1967 年，因為新《民法典》生效，爲了確立這些創新性及修改，對由 1967 年 5 月 11 日第 47690 號法令通過之原文本之多條條文作出修改¹⁰⁵。

自始，出規對葡萄牙程序法作出多次修改之法規：

- 7 月 11 日之第 323/70 號法令；
- 7 月 10 日之第 439/74 號法令；
- 5 月 27 日之第 261/75 號法令；
- 3 月 1 日之第 165/76 號法令；
- 3 月 19 日之第 201/76 號法令；

¹⁰² 關於這點內容，見《民事訴訟法典——在澳門生效之文本》一書之引言，由 Cândida da Silva Antunes 及 Amílcar Batista Feio 合編。

¹⁰³ 透過 19305 號訓令公布在 1962 年 10 月 9 日之政府公報上。

¹⁰⁴ 透過 1967 年 12 月 30 日第 23090 號訓令引伸至海外省——在第 52 期政府公報上刊登。

¹⁰⁵ 除外的有 7 月 10 日第 439/74 號訓令（公布在 1974 年 8 月 3 日第 31 期《政府公報上》——修改了《民事訴訟法典》第 709 條第 3 款之文本）；10 月 10 日第 457/8 號法令（公布在 1980 年 11 月 9 日第 45 期政府公報上）。

——7月24日之第605/76號法令；
——10月16日之第738/76號法令；
——9月3日之第368/77號法令；
——12月30日之第533/77號法令；
——5月3日之第21/78號法律；
——12月27日之第513-X/79號法令；
——7月1日之第207/80號法令；
——10月10日之第457/80號法令；
——9月23日之第400/82號法令；
——7月9日之第242/85號法令；
——9月28日之第381-A/85號法令；
——7月2日之第177/86號法令；
——8月29日之第31/86號法律；
——7月18日之第557/89號訓令。

鑑於在公佈時並無提及要在《澳門政府公報》上刊登，所以大部分這些法規並無在澳門生效，。

由於葡萄牙主權機關之法規無一個關於引伸至澳門生效之機制，故是否在澳門生效取決於遵守《澳門組織章程》第72條之規定，此引致對《民事訴訟法典》之連續多次修改並未在澳門生效。

在1987年初，在當時司法事務辦公室主任之建議下，要求葡萄牙政府公布一份法令（認為適宜將在葡國公布之部分法規引伸至澳門），故將部分作出修改¹¹⁶之法典之法規引伸至澳門，並作出配合，將與澳門不符之規定排除在外。

透過葡萄牙政府之動議，於5月29日之第221/87號法令實現了這個目的，還有葡萄牙共和國議會透過6月18日之74/88法律¹¹⁷之許可法而公布之11月28日之第437/88號法令。

因此，多份法規引伸到澳門生效：

1. 7月24日第605/75號法令——第1條及第3條及其第2條除外——而其中第2條條文修改了《民事訴訟法典》第1404條第2款、1407條第2款及第7款、第1420條第1款、第1423條第1款、第2款及第4款之文本；
2. 9月3日之第368/77號法令：第2條、第3條及第4條除外，還有該法令對第972條及第1414條第1款之修改之本；

關於補充立法，在澳門連續公布了多份法規：

——9月1日之第269/28號法令《司法法院組織法》，1979年7月20日之政府公報第28期（副刊）；
——6月5日之第39/78號法律《檢察院組織法》，1979年3月24日第十二期

¹¹⁶ 當時由立法事務辦公室草擬之法令草案。

¹¹⁷ 公布在1989年4月10日第15期政府公報上。

- 政府公報；
- 9月3日之第348/80號法令《修訂司法組織法》，1980年9月8日第45期政府公報；
 - 4月27日之第129/84號法令《行政及稅務法院通則》；
 - 7月30日之第21/85號法律《司法官通則》，公布在1985年8月23日第33期（第二副刊）；
 - 第47/86號法律《檢察院組織法》，公布在1986年12月15日之第50期《政府公報》上。

最後，還需指出：自1987年2月9日起，澳門還有一份本身之法院辦事處組織法（2月9日之第6/87/M號法令——公布在該日之第六期《政府公報》上），這份法令代替9月9日第352/72號命令（舊之海外法院行政辦事處組織法）——藉此管制澳門法院各行政辦事處之架構，其規範明顯已不適合程序及澳門新之政治及行政條件。

此為仍生效之組織法，僅後來才配合了澳門檢察院之等級（7月4日之第60/88/M號法令——見同一日之第27期政府公報），其中第3條、第5條、第31條已及第32條被修改，因為要將司法文員之工作時間配合法院運作之需要。

應特別注意澳門司法組織之立法（在趨向於脫離葡國而享有自主），還包括仍未配合澳門、但同民事程序有關之規範。

13.3.認識澳門《民事訴訟法典》之淵源及相關條文

A. 澳門《民事訴訟法典》之淵源，要件及法規：

經1961年12月28日第44129號法令核准之葡國《民事訴訟法典》及在1962年10月9日第40期澳門政府公報副刊公報之1962年7月30日第19305號訓令批准於1963年1月1日開始生效。

現行之《民事訴訟法典》於10月8日之法令第55/99/M號通過，並曾被12月20日之第9/99號法律序言法第81條修改。

B. 澳門《民事訴訟法典》相關條文之淵源，要件及法規：

12月20日之第9/99號法律《司法組織綱要法》；

10月25日之第63/99/M號法令《法院司法費用制度》；

5月6日之第31/91/M號法令通過之《律師通則》後經第42/95/M號法令修改；

10月25日之第65/99/M號法令通過之《未成年人教育及司法保護制度》；

6月11日之第29/96/M號法令通過之《內部自願仲裁制度》；

11月23日之第55/98/M號法令通過之《對外商業仲裁制度》；

8月1日之第41/94/M號法令通過之規範之《司法援助制度》。

第三編

訴訟關係理論

第一章

基本概念

15. 訴訟程序中之訴訟關係性質及特性

在上文已提及民事訴訟在結構上是一套連貫行為，遵從一個由法律規定之規範制度或形式（程序步驟合法性原則）而進行，而這些行為具有一特定形式，並由某些主體在一定時間及空間內作出，而且有特定之目的。

有關主體是透過程序行為之作出而行使法定之權力及受制於某些由程序法律規定之特定法律後果，為此，在程序發展過程中各個主體的參與是會產生一套與權力義務有關之法律聯繫，即某些特定之主觀法律狀況處境：原告人之法律狀況，被告人之法律狀況，審判人（法院）之法律狀況，如似類推。

然而由這些不同之主觀法律狀況而組成具特定身份之各個個體，自程序之產生，直至消滅是會在整個程序過程中皆維持這個身分，但亦有例外，例如《民事訴訟法典》第 215 條第 1 款：因繼承或生前行為代替爭議實體關係之任一方當事人。

程序有其本身之一個特性：按照幾乎一致認同之主流觀念，這種特性可引伸至法律關係之概念¹¹⁸：訴訟法律關係——民事訴訟法律稱為訴訟程序（《民事訴訟法典》第 211 條及續後）。

簡言之：

在民事訴訟法律關係一詞上，有意將訴訟主體間在法院內所建立之關係形成一個聯繫；但嘗試包括所有法律後果，是指法律秩序與向法院所主張之事實相聯繫而產生之後果。

然而，程序法律關係對實體法律關係之依賴僅具功能性質：即實體關係與程序關係之間並無任何其他聯繫存在，因程序關係享有自主性。

此外，還有一種特殊性：訴訟關係有其動態之性質：要遵從由多個階段所組成之程序步驟，此為民事訴訟關係之外觀。

16. 組成訴訟關係結構之元素

為了研究這點內容，現在要研究程序之內部，即需要了解其結構，這個問題在學理上並無劃一之見解。

在此詳盡地解釋著名訴訟學家對程序關係之結構之各種觀念十分有趣，這種程序關係明顯有別於實體法方面之關係。

¹¹⁸ 這種法律關係今日受到很大質疑（作為法律現象之解釋框架）。

簡言之，我們僅限於談及訴訟關係特性之各種意見。

分歧最大的一點是關於當事人與法院間之關係，兩者皆為程序之主體。

部分人認為民事程序是當事人間之直接關係，而非當事人與法院間之關係，原因很簡單，因為法院之地位是中立及公正無私，而訴訟程序是當事人間之一項爭議，而非各方當事人與法官間之關係（Kohler 之理論）。其他學者則嘗試指出在民事訴訟內引入法律關係這個概念之不便之處，否定訴訟關係具有這種特性。

對每個立場作出批評並非難事；首先是因為忽視了訴訟關係之結構，否定在這種關係裏法院所擔當之角色及剝奪了法院之自主性，其次作為法律現象之解釋，在訴訟關係之概念上存在困難及爭論點，並無排除當事人與法院間存有之關係列入真正之法律關係之範圍內。

如何解決此問題？

讓我們研究：

民事訴訟法律關係之結構基本性元素是訴權（其被行使時會引致原告人同法院建立聯繫），辯論權及防禦權（當其被行使時使被告與法院發生關係），最後，審判權乃代表國家行使。

我們正面對一種三邊關係，主體方面有原告人、審判者及被告人。

訴訟中的原訴人與被訴人之間是相對的之辯論關係，但並非一方當事人直接向另一方提出，而是兩者向法院提出。而作為國家代表之法院擔當一個獨立之角色，並與各方當事人之權利保持等距。

一如 Anselmo de Castro 教授所說：“無論是訴或辯論關係，最終是相當於要求法院聽取當事人之權能（賦予原告人及被告之權能）¹¹⁹”。

然而，這種由當事人與法院間建立之聯繫，在法律上發揮的作用及受其約束之聯繫，鑑於其內容，並不同於實體法關係。

在程序內雙方當事人並非向對方承擔義務；與法律給予原告人之權能相對應的並非被告之義務，相反亦然。

任一方當事人不實施某些行為並不會因此而承受某些懲罰。按一般的規定，對他們來說僅是一項負擔——此為民事訴訟程序一個重要概念，作為受當事人意志處分之權能，極罕有地會實施義務。通則是遵守某些特定行為會產生某些有利之後果。

作為民事訴訟程序之負擔之例子有：舉證責任，不履行之後果是產生一個對一方造當事人原為有利變為不利之決定（《民事訴訟法典》第 516 條）¹²⁰。

同樣地，當《民事訴訟法典》第 403 條第 1 款指出：“被告得於獲傳喚後三十日期間內答辯……”，答辯與否由被告支配，他可以選擇作為或不作為，兩者皆為合法之行為。法律僅限於設定一種或另一種後果，而這些後果則不受被告人支配。

¹¹⁹ 故突出程序之“程序之雙向性”——見 Luso Soares 引述 Calamandrei 之《宣告之訴之程序》一書，第 106 頁。

¹²⁰ 關於證據功能及舉證責任，見《民法典》第 334 條。

在期間（prazos）事宜上亦一樣，基於快捷性及其他原因，對不作為規範不利之後果，但無明示表明依期履行期間較有利，如透過強制實施一個法律義務而進行一般。相反，選擇了負擔這個制度。

對於此，法律僅接受隨後出現之負擔，並給予法官某些主動權：以當事人自行負責原則為主並以調查原則相協調。

17. 訴訟法律關係之生命：訴訟程序之展開與發展，稍後論述。

基於上文所述，有人否定訴訟關係是真正法律關係之性質：認為如果一主體擁有權利、但無相應之法律義務，如何會有法律關係？有人如此質疑。

似乎在訴訟程序內負擔這個法律制度之重要性先於“法律義務”、並不表示足以否定訴訟關係所具有之真正法律關係之性質。

記得我們在上文關於程序之動態性質時之所述（在此需再重述），我們會立即發覺在訴訟關係之發展過程中有創設、變更及消滅之情況出現——此為程序關係生命之中不同時間，是一個一體性之法律現實。法律本身視其為一整體，否則不會接受連貫性之現象。

此為源自《民事訴訟法典》第 215 條之內容：

“在訴訟程序中各主體是可變更的：

- a) 由於繼承或生前行為而引致代替任一方當事人，是一種正當的移轉。
- b)”

肯定的是繼承並不會自動發生，相反須某些條件方出現；即使如此，已清楚指出了法律本身承認訴訟關係有可移轉之法律關係之性質。

但不應認為：

- 在民事訴訟程序內對當事人不實施任何義務；
- 或視負擔為民事程序之專有概念。

在這類程序內，在當事人之義務之中，突出了當事人只要為此而被通知有親身到場之義務，還有在程序上提供合作之義務（《民事訴訟法典》第 8 條第 3 款），倘違反，經法官適當考慮後會採用罰款或實施其他強制方法（第 442 條第 2 款）。

但我們認為，這些見解並無就決定程序法律關係之性質問題提出新意。

最重要的是這種關係之各種特徵——容許區分這種特徵及賦予這種關係自主性，（相對於實體法律關係之性質而言）。

在這種關係內，其特徵計有：

- a) **請求原則**——以有一個原告人為前提，通常是指受法律保護之權利人；
- b) **自主性**——實體法之概念及邏輯思維並不完全適合程序法（例：無效制度——稍後我們將會學習，在此特別重要的是法律確定性、安全性及穩定性）
- c) 程序所針對之法律效果（判決）——並非源自當事人，因為在程序發展過程中，要向法院作出認知聲明，而非意志聲明；
- d) **複雜性**——訴訟關係分成兩組關係：起訴關係及防禦關係（此點已清楚在上文中表達出來）。

簡言之，作為真正之法律關係，民事訴訟關係由組成任何一種其他法律關係

之元素組成。

其中有主體（當事人——主當事人及輔助人）及法院；有其標的——待決之爭議，即私人利益之衝突——受原告之請求及有關訴因限制；還有一個構成事實（創設性事實——體現在由原告作出之起訴行為）；最後，還有保障——指在程序法中當主體不遵守所定之程序義務及負擔對之採取之一套懲罰及後果之制度。

稍後將探討訴訟法律關係之開始及發展——我們之法律稱為訴訟程序。

第二章

訴訟前提 (pressupostos processuais)

18 訴訟前提之概念

訴訟前提之理論為現代民事訴訟之現代理論。

對這個課題所作之歷史研究促成了 Oskar Von Bülow 在其《抗辯理論與訴訟前提》¹²² 之前衛作品，在十九世紀時已被稱為訴訟科學之開始¹²³。

在該作品內，該學者將訴訟前提界定為訴訟關係之結構性元素，而這種關係是公法之關係，是當事人與法院間之關係。

對於該德國學者來說，作為訴訟關係之結構性元素，前提是一個整體程序存在之要件。

對該學者來說，當具備了訴訟前提，當事人才可以就標的進行辯論及要求法院作出審理：法院除了要分析實體關係之附隨事項外，還須分析程序法律關係，及對該關係作出表示。

這個意思逐漸演進，按照德國學理之取向（Bülow 亦認同這個理論），前提不再被視為訴訟程序之結構性元素，而轉為對實體問題作出決定前必要符合之條件。換言之，前提之條件功能不再是指訴訟程序之存在，而是對實質問題作出裁判前要符合之要件。

葡萄牙學理亦認同這個理論。

Manuel de Andrade 教授使用下述方式表達：

“訴訟前提是指要求法官作出實質裁判前所必須符合之要件，對原訴人之請求之司法措施給予許可或駁回”¹²⁴。

對 Antunes Varela 教授來說：前提“是指法官對請求作出裁判前必需符合所依符之要件，即批准或否定所申請之措施……，此為保證一個適當裁判之有益效果所必需之基本條件¹²⁵。”

另外，對 Anselmo de Castro 教授來說，前提是指：“行使審判職能必需之條件，目的是確立裁判之公正（依法作出），另一方面，是為了避免無用或不必要之裁判”，同時亦強調指出：“一如這個術語本身所啟發般，這些前提並非程序前提或程序存在之條件，非如 Bülow 所認為般……因為這些前提本身成為審查及

¹²² 見《Die Lehre Von den Prozesseineeden die Prozessvoraussetzungen》，有西班牙文譯本，於 1964 年由 Buenos Aires 發行。

¹²³ 見 Castro Mendes 教授 “Dtº Processual Civil” 第 1 冊第 5 頁。

¹²⁴ 見 “Nações Elementares” 第 74 頁。

¹²⁵ 見 “民事訴訟手冊” 第 2 版第 104 頁。

決定之對象，當然是要假定這些前提存在”¹²⁶。

有一件事情值得肯定：訴訟前提之重要性足以要求對其作出小心及詳盡之探討。

然而，在這一章內，我們僅介紹這個課題，介紹有關概念及其特點——正是這些特點使訴訟前提有別於其他同類概念。

從上述學理中可很易得出下述結論：在民事訴訟程序內，法官必須預先調查是否存在審理案件實質問題所需之要件，即原告人向法院提出之請求是完全具行使審判權之條件，此為實質問題之先決問題。

由此可知：法律要求符合之前提有助於突出程序法相對於實體法所享有之自主性：將實體法適用於現實生活之具體個案會面對程序法之先決問題，不會與實體法之問題混淆。

19. 與同類概念之分別

依上所述，訴訟法律關係（我們的法律稱為訴訟程序 *instância*）始於一方當事人、即原告人提出保護之請求，即當他向法院提出請求、要求法院解決問題。

法院對向其提出之起訴，可採取不同之立場，在各個可行決定中選擇一個。我們舉例述之¹²⁷。

1. 初端駁回之批示（《民事訴訟法典》第 394 條）

在程序剛開始後，辦事處將卷宗向法官送閱時，倘欠缺其中一個關於當事人或法院之訴訟前提，且已被法官發現，應阻止這個程序繼續，鑑於在該程序內已禁止法官對實質問題作出裁判，在此情況下，被告人不會被要求到法庭為己辯護，因為他介入程序完全無意思。

但如訴訟程序已發展至已命令傳喚被告人階段，法官才發現欠缺一個前提，法官已不能使程序從頭開始，不可初端駁回起訴。在此情況下，會採取另一個立場，即

2. 作出駁回起訴之裁定（《民事訴訟法典》第 412 條第 2 款）

在訴訟法律關係成立或發展初期，只要不符合訴訟前提所需之要件，法官應拒絕向其請求之利益衝突作出判決。

雖然無論起訴狀初端駁回或駁回起訴（*absolvição da instância*）皆引致產生對被告人及其利益十分敏感之後果：但初端駁回可由許多其他原因引致——並非因為欠缺其中一個訴訟前提。

但法官還可作出：

3. 駁回請求之裁判——對事實認定及適用法律規範後，作出利於被告人之裁判，即駁回原告人之請求。

最後，法院還可以：

4. 依請求作出給付裁判：法官認為應以利於原告人之方式解決衝突。只要

¹²⁶ 見由 Alfredo Soveral Martins 之作品：《宣告之訴之民事訴訟程序》，第二卷，第 7 及 8 頁，還有《民事訴訟教程》（訴訟前提）1969 年 Coimbra 出版第 5 頁。

¹²⁷ 我們只指出同界定訴訟前提有關之利益之決定。

符合 Chiovenda 所稱之**訴之要件**，這種情況會出現。

19.1. 訴訟前提與訴之要件

我們需要分析及將同類概念作一比較，兩者皆有其重要性：訴之要件或訴之實質問題之要件及上述的真正之訴訟前提。

另一方面，“**訴之要件**”這一術語是指使訴被裁定為理由成立所需之要件。屬於對實質問題有關之要件（同具體實體法律關係有關連），欠缺任何一個要件引致訴訟（即請求）被判為理由不成立。

訴之要件為原訴人以適用之實體法而提出正當請求的依據。為此，該條件為必須符合實體法之條件。

綜上所述，訴之要件主要為：

- a. 存有主張之實體主觀權利；
- b. 該權利可透過司法途徑要求（並非無訴之權利）——《民事訴訟法典》第 1 條第 2 款及《民法典》第 396 條及續後；
- c. 存在一個利害衝突（《民事訴訟法典》第 3 條第 1 款）。

傳統學理將另外兩個要件列入其中：**提起訴之利益（訴之利益）**及**正當性**；但今日已對這種見解作出修正，因為這兩個概念皆被視為訴訟前提，因為其中集合了案件之形式及實體內容。

結論：**訴之要件**是使訴訟理由成立所需之條件，以便作出一個有利原告或提起訴訟之人之判決；是給予或否定所主張之保護措施之要件——涉及調查所援引之主張與有關事實狀況間相符及實體權利之關係，及或證明兩者間並不相符（例：消極確認之訴）。

不同的是訴訟前提——是指當這些要件存在時，法官必須對實體問題作出裁判。倘欠缺這些前提，則禁止法院對訴之要件之存與否在作出審理。

換言之：

倘程序所針對之司法判決之目的是審定由原告申明之權利是否受到司法保護，要許可這種保護，必須將程序性質之要件結合實體性質之要件。

故訴訟前提是完全行使審判權之基本要件。

這些要件基本上是為了三個目的：

1. 確保裁判之公正——例法院之管轄權，立法者藉此規範出法院可以審理案件的範圍。
2. 確保辯論原則之完全及正當運用——例關於當事人之前提：當事人能力及訴訟能力，正當性或稱為正當化（Manuel de Andrade 教授之用語）。留意：藉此途徑落實第一個目的，因為當事人要同法院合作，以便作出裁判。
3. 避免無用或不必要之裁判——例訴訟已繫屬及提起訴訟之利益，一如 Manuel de Andrade 及 Calamandrei 所述之訴之利益。

訴之條件是指訴訟理由成立所需之要件、作出一個有利於原告判決所需之要件；而訴訟前提則不論是否對原告有利。倘欠缺前提，法官不可以作出不利原告或利於被告之裁定，只限於以適當之技術方法中止或結束有關之訴訟程序。

一經符合訴訟前提，程序之正常後果必須有一個針對案件實質問題進行裁判或判決，即針對訴訟中之利益衝突（《民事訴訟法典》第 3 條）作出判決，此為一個實質判決¹²⁸。

簡言之，訴訟前提乃對實體問題判決之前提或形式要件。

按照一個由 Bülow 提出、且獲得廣泛支持之理論，法官必須審定在程序內之行爲是否符合規則；之後方能審定實質問題，即訴之標的。訴訟前提之確定為獨立於對實質問題之審定¹²⁹（前者乃後者之先決問題）。

但我們回到現實層面上，我們從實踐角度研究這個問題。

在作出一份實質判決之前，法官可借助一組向自己提出之問題而界定訴訟前提。

這些問題基本上是：

1. 法院應否對問題作出表示？
2. 要求該問題之解決方案之人（原告或被告），在抽象層面上可否為提出有關要求之權利人？
3. 要求解決方案之人可否自行提出（親身）？或在法院內須適當地有人出任其代理？
4. 要求解決爭議問題之人在爭議問題上之身份（地位）是否符合由其向法院提出要求？
5. 要求解決方案之人在法院內是否要由一個法律專業人士代理（倘法律如此要求）？

如對上些問題給予否定之答案必引致，法官無對實質問題作出判決之義務；相反，法官有義務終止該程序，裁定起訴不予受理。根據《民事訴訟法典》第 230 條規定訴訟前提欠缺或不規則原則上引致起訴不予受理，但亦有例外之規定，如根據《民事訴訟法典》第 6 條第 2 款法官須依職權採取措施予以彌補。

嚴格而言《民事訴訟法典》第 230 條只規定了必須駁回起訴之部分與訴訟前提有關之原因。因為只要《民事訴訟法典》第 413 條所規定之任一項**延訴抗辯之事由**理由成立（法院相對無管轄權則除外）即引致駁回起訴（《民事訴訟法典》第 412 條第 2 款）。

綜上所述，按照現行制度之規定，訴訟前提之理論應以第 230 條及第 413 條之規定為基礎，兩者緊密聯繫，一如第 230 條第 1 款 e 項所述般。指出法官應拒絕審理案件之實質問題之各種情況，是應用了相反方式去指出有關之訴訟前提；一如現行法律以消極方式列出訴訟之前提。

然而，可以想象：對訴訟前提是否存在之審定，可透過兩個制度之其中一個進行：

¹²⁸ 對我們來說，意大利學者 Onofrio 所持之立場十分有趣，而該立場獲得 Paulo Cunha 教授之認同：前提是指法官可以履行其職責所需之條件，同請求之實體問題無任何直接關係。

¹²⁹ 近來，有學者反對對宣告之訴之前提作出預先審判。如 Miguel Teixeira de Sousa 教授——見公布在律師公會雜誌，第 49 年，1989 年。

1. 法官之主動受理之問題：法官依職權審定是否符合全部所需之訴訟前提；或
2. 將前提是否存在之問題交予當事人監察，容許當事人以抗辯方式（延訴抗辯）指出前提之欠缺，且規定只有任一當事人提出抗辯，法官方會考慮欠缺前提之問題。

我們的法律採用了哪個制度？

可以指屬於一個混合制度。

為此，繼在第 412 條內指定了阻止法院審理實質問題之延訴抗辯及在第 413 條內以列舉方式列出法律接受之延訴抗辯後，《民事訴訟法典》第 414 條作出規定：“除非抗辯以違反排除管轄權之協議或案件原應由自願仲裁庭審理為由而提出，否則所有延訴抗辯均應由法院依職權審理。”

並非有意借此指出當事人對於大部分之前提禁止提出抗辯，法典給予當事人提出抗辯之權能，在有充分理由下促請法院留意欠缺訴訟前提之情況。簡而言之，倘透過程序，即使被告無提出抗辯，倘法院得出之結論是欠缺其中一個訴訟前提，則法院會依職權認定該事實、以便駁回對被告之起訴。

只有在第 414 條所述之保留情況下才不如此，計有：

- 違反排除管轄權之協議；及
- 由自願仲裁庭審理。

最後，我們扼要地指出訴訟前提所遵從之制度之一般特性（該制度中各人在訴訟要件的關係）：

- 相對於對實質問題之審定而言，訴訟前提屬於先決問題；
- 要求審定訴訟前提突出了程序法相對於實體法所享有之自主性：將實體法適用於現實生活之具體情況會面對程序法這先決問題——有別於實體法本身之問題。

為此，

- 訴訟前提乃基於公正掌理司法之公共利益而強制實施之要件，不能忽視這些原由，亦不能被當事人之意志排除。

鑑此：

- 訴訟前提是啟動法院運作的第一門檻，從而表現出法官只須對國家承擔之一個義務，並非直接介入調整訴訟關係之私人主體（當事人）之利益。
 - 大部分之訴訟前提之審理都是由法官依職權進行，即使在上訴或在《民事訴訟法典》第 415 條及第 415 條規定，但亦不排除上述由被告提出抗辯之事由。
- 駁回起訴並不會阻止當事人就同一標的提起另一訴訟（第 575 條）。
- 關於訴訟前提所取決之事實條件並不取決於當事人之陳述。
- 原則上，當事人在訴訟前提方面之協定並不具效力（某種程度是保留管轄權）。
- 關於對訴訟前提之認定及使訴訟關係之正常化（補正欠缺或將案件移送予另一法院），法院享有廣泛之權力，此有別於實體問題（第 6 條第 2 款）。

- 對訴訟前提之裁判轉成既判案，但在某種層面，在理解這點內容方面，我們需先區分形式既判案及實體既判案。

形式既判案，亦稱為對內既判案，是形式裁判之一種特性——僅針對訴訟關係而作出。僅可普通上訴外，並不會阻礙已裁決之事宜在新訴訟程序內，由同一法院或另一法院重新審理（第 575 條）。實質既判案乃實質裁判之一種特性——對實質法律關係作出審理，對爭議之法律關係作出決定，同時約束所有法院，法律解決方案已確定，不能再作爭議（第 575 條第 1 款及第 2 款）。

關於訴訟前提之裁判產生形式既判力或實質既判力？

試舉一例子看看。

我們假設在一父親身份調查訴中，法官根據以第 413 條為依據作出駁回對被告起訴之判決，這樣使程序終結，而這份判決轉為確定後，在程序內具有強制約束力。

但這份判決會否阻止法官在當事人提起另一相同之父親身分調查訴內作出意思相反之判決？其確定性僅限於該案內或延伸至案件以外？

關於管轄權這個前提，在我們的法律內此問題已被《民事訴訟法典》第 33 條及第 34 條解決了。故無任何問題存在。

關於其他前提，主流學理，例 Alberto dos Reis 及 Chiovenda 教授認為這些裁判無實質既判力。所持之依據為：該判決並非以針對爭議之主要標的而作出，並無授予或否定法益，無理由將其強制力延伸至程序以外。

但這並非 Castro Mendes 教授之立場。

他認為裁判之不可變更性應超出程序以外。倘有關的依據在新程序重複提出，可合法地用既判案為由提出抗辯。

面對這些分歧之立場，Anselmo de Castro 教授在闡述其思路時，指出主流學理之兩個基本理由：

1. 第一方面，歷史方面之理據——強調 1939 年葡法典（前為 1961 年法典及現澳門生效之 1999 年法典）制定時之環境；
2. 第二方面，衡量到問題之所在並非實質利益衝突，應排除有實質裁判可能性。

然而，針對其為形式性及實質性互相混合的前提，應對主流學理引入一個限制：例**正當性及訴之利益**。由於裁判已涉及實質利益，須承認其實質既判力。為此，該些裁判，雖然針對程序關係，並非單純不可列入第 575 條之文字意思範圍內。

稍後對此問題作深入研究及指出有關解決方案。當學習關於當事人之訴訟前提時，尤其是正當性時，談論此點更為適當。

19.2. 訴訟前提與訴訟行為之前提

學理亦區分關於整個程序之前提（訴訟前提——一如我們所指之特徵般）及僅關係於某些行為或一套程序行為之前提。

一個訴訟行為之法定規範制度應具有下述元素¹³⁰：

¹³⁰ 稍後我們詳述其理論——見第三部分第三章第三節。

- a) 在規範方面指出行爲之前提，即可以或應該作出行爲之狀況；
- b) 在規範上描述該行爲；指出其主體（意志）、內容、客體、行爲之原因及行爲之外顯形式；
- c) 在規範上界定行爲之價值；
- d) 行爲之效果，即法律爲行爲所定之結果。

如此，對組成訴訟之每個行爲，有關規定，（作爲行爲之前提）規定行爲如何進行及作出行爲與行爲間之順序；不按照法律規定，則不能如此作爲。換言之：每個訴訟行爲設定：在程序發展過程中，會因作出行爲而創設特定之狀況。

這個原則乃源自民事訴訟本身之結構：將傳喚被告一事通知原告以事前作出一個傳喚行爲爲前提；判決（典型之程序行爲）爲以當事人、法院、輔助人之一連串多元性及無數之行爲爲前提。

爲此，訴訟行爲之前提乃行爲存在及其有效性之要件。其欠缺引致行爲**無效**及續後之行爲亦**無效**，但並不引致整個訴訟程序無效（例無傳喚被告會引致續後之訴訟行爲無效，但並不包括作爲程序開始之起訴狀——《民事訴訟法典》第140條）。

19.3. 訴訟前提及訴訟存在之條件及其有效性

後者爲訴訟關係在法律上存在及有效之必須要件，而非對實質問題作出裁判之可行性所需之要件（訴訟前提）。

兩者之區分有其巧妙之處，因爲欠缺程序之存在及有效條件（雖然只是間接地）引致對實質問題作出之裁判無效；但亦不得作出其他類型之裁判.....。

程序之存在及有效之條件指訴訟法律關係之結構性元素：主體、標的（客體）及法律事實（保障由法律本身設定）。

例如：仍未向法院提起之訴爲不存在；例無原告之訴亦爲不存在之訴，無被告之訴亦一樣。

第三章

訴訟法律關係之結構

第一章

訴訟法律關係之主體

20. 當事人

先在動態層面上學習訴訟法律關係，我們先研究第一個組成元素，一如在任何法律關係般，就是主體——在訴訟關係內其稱為當事人。

20.1. 當事人之概念

繼在入門課講解之內容後，很易得出下述的結論，當事人為程序之主要人物及推動者，正如 Calamandrei 稱為“司法劇之主角”，訴訟關係中作為積極主體：原告、原訴、申請人；及消極主體：被告、被訴人、被申請人。而上述的各種身份在法院上合稱為訴訟當事人。

當事人須是訴訟上表現，但其根源是來自實體法。

法律本身在其條文內稱為訴訟推動人為當事人，一如在《民事訴訟法典》第316條第1款內，由此可得出程序之雙向性，即必有當事人間之兩個立場。

當事人指自行或經適當代理而參加訴訟程序、在法院出現、提出其請求或反對他人（維護受法律保護之利益）請求之自然人或法人。

在 Chiovenda 之古典定義裏，當事人是指以其名義要求作出法律意志之人，以及請求所針對之人；即指要求解決爭議及要求所針對之人。

當界定當事人概念時，不應忘記其純形式性質：當事人是指提出請求之人及請求所針對之人，而非應作出請求之人或請求應針對之人。為此有非正當當事人，無當事人能力之當事人，無訴訟能力之當事人，還有在訴訟中當事人亦是負擔訴訟費用之人。

除此之外，當事人亦是在訴訟程序內以個人名義作出行為，在程序內維護其主張之個人利益之人。為此，在代理關係上，當事人是被代理人，而非代理人。

如不是當事人，相對於訴訟關係而言則是第三人。一如西班牙訴訟法學家 Jaime Guasp¹³¹ 所澄清般：“訴訟中之第三人不享有當事人身分之人，或不受制於這種身份之人，即使在訴訟層面上同真正當事人有某一種關係亦然”。

20.2. 分類：主當事人及輔助當事人

以參予程序之身分為標準，學理還區分主當事人及輔助當事人。

主當事人：當自主地參予程序，獨立地維護自己之利益。以自己名義提起訴訟之人為原告，訴訟所針對之人則為被告，兩者皆為主當事人。

¹³¹ 見《Derecho Processal Civil》，第2版，第52及第55頁。

輔助當事人是指參加訴訟，亦為維護一利益（否則並非當事人），但其利益只與其中一方主當事人之利益相聯繫及協調。以從屬於主要訴訟人之身分而參加訴訟（第 276 條第 2 款），在訴訟活動發展過程中提供輔助（《民事訴訟法典》第 276 條第 1 款）¹³²。

在法律內典型之例子為輔助人——見於《民事訴訟法典》第 276 條至第 282 條。

在該幾條條文內定出了整個制度，以“擁有法益之人”介入訴訟之可能性為基礎，而該訴訟內，裁判會利於其中一方當事人。為此，只要輔助人為某一種法律關係之主體，而這種關係之實際或經濟持續性取決於被輔助人之請求。

作為這些情況之例子是：在由檢察院依職權提起之父親身份調查之訴裏（《民法典》第 1717 條），未成年人之母親可作為輔助人而參加訴訟，因為她是法律上有擁有重要利益之人——在勝訴時，她會得到經濟利益，與父親共同分擔未成年人之支出（扶養、教育、服裝等）。

另一個輔助例子是房地產之分租承租人——他有輔助承租人（住客）之法律利益（在針對其而提出勒遷之訴時）；又如，要求返還一房地產之所有權之人之債權人。

在這些情況下，輔助人可於任何時候參加訴訟，但需接受在介入時程序所處之狀況。要參加訴訟，則須提出一份申請書或提出其參加訴訟之請求，或陳述被輔助人仍可及時要求他人參加訴訟（《民事訴訟法典》第 277 條第 2 款）。

21. 關於當事人之訴訟前提

21.1. 當事人能力

A. 概念與範圍

在上文已學習了訴訟前提——作為對案件之實質問題（即對爭議之實質問題）作出一司法裁判前所需符合之要件。

依上所述可知某些前提（作為整個訴訟之要件）關於當事人，而其他之前提則同法院有關，兩者皆為程序法律關係之主體。

現在我們開始有系統地學習關於當事人之訴訟前提，按照現行《民事訴訟法典》之順序編排而進行。

在“當事人”之標題，程序法律先後規範**當事人能力**及**訴訟能力**（第 39 條至第 57 條），當事人之**正當性**（第 58 條至第 71 條），訴之利益（第 72 條及第 73 條）及在**法院之代理**（第 75 條至第 86 條）。此為關於當事人之有名前提。

根據《民事訴訟法典》第 39 條第 1 款規定當事人能力係指可成為當事人之資格。同條第 2 款規定具法律人格者，亦具當事人能力。因此當事人能力同法律人格相一致，為此，按實體法之規定，有法律人格之自然人及法人皆有當事人能力，故可成為訴訟程序之主要當事人或輔助當事人¹³³。

¹³² 體現了對主要當事人之從屬，很明顯反映在《民事訴訟法典》第 281 條：捨棄並不影響主要當事人之權利，可自由地作出捨棄或和解，在任一情況下則終止其參與。

¹³³ 有人學者將當事人能力稱為訴訟之權利能力，以區分行為能力。

現行訴訟法律確立了法律人格與當事人能力相一致原則、或稱等同原則或相應原則。

如所有具備法律人格之自然人及法人均具有當事人能力，相反之說法則並非完全正確。特別是基於公共秩序¹³⁴，訴訟法將當事人能力賦予某些無法律人格之實體，主要是考慮到有效及快速地維護這些實體之債權人之利益。

該等例外之情況可見於《民事訴訟法典》第 40 至第 42 條（一致原則或相應原則之例外情況），且分成不列幾類情況：

第一組：

a. 待繼承之遺產（第 40 條第 1 部分）

待繼承之遺產指已開始繼承、但仍未確定擁有人之財產，或仍未宣告為歸澳門特別行政區所有之財產（《民法典》第 1884 條及第 1993 條；《民事訴訟法典》第 1031 條）。

雖然無法律人格，但有積極當事人能力（作為原告）及消極當事人能力（作為被告）。

可以由管理遺產之人提起訴訟或針對遺產而提起訴訟（《民事訴訟法典》第 54 條），或由檢察院提起訴訟（《民事訴訟法典》第 51 條）——當不確定人為被告時代表不確定人，無需識別繼承人，故亦無需待確定繼承人之身份¹³⁵。

b. 類似之獨立財產（第 40 條第 2 部分）

獨立財產是指經法律作自主化處理之一系列財產，以便受制於一個負債之特別制度，該些財產之擁有人並不明確，但該些獨立財產與其他財產相區分及供特別承擔特定債務之用。

例如：

1. 以贈與或遺囑方式留給胎兒之財產（《民法典》第 946 條、第 1873 條第 2 款 a 項及第 2070 條第 1 款）；
2. 屬於一群人之財產，但不承認其整體具有法律人格（《民法典》第 190 條至第 192 條）；
3. 撥給仍未成立之財團法人之財產，故仍無法律人格；
4. 分層樓宇之共有部分（《民法典》第 1313 條及續後。）

在程序層面上，獨立財產包括所有擁有人仍未確定之情況，故需有一個適合其代理之法律制度，容許其有效及快捷地作為。此為“用途待決之財產”——等待界定擁有人之身分之財產¹³⁶。

第二組：

當事人能力及法律人格之相符原則之界定之另一組例外情況有分支機構、代

¹³⁴ 是用司法途徑保護正當利益之一種有效方法（在無權利人身份之情況下）——此為 Antunes Varela 教授之言論。

¹³⁵ 一如 Anselmo de Castro 所述般，第 6 條之規範所述之未繼承之財產只是紙上文字。現實的情況是遺產之債權人針對繼承人及不確定人而起訴，而非針對遺產而起訴。

¹³⁶ 見 Luso Soares 之作品。

辦處、子機構、代理處或代表處（《民事訴訟法典》第 41 條）。

這是公司總行之分支部分，是公司代理之各種方式。

它們並無當事人能力，但法律容許分支機構、代辦處、子機構、代理處或代表處（《民事訴訟法典》第 41 條）被起訴及可以直接起訴，故有積極及消極之當事人能力。

但明顯的是分支機構代替公司或作為總公司之代表（公司不參與訴訟程序），故透過公司之主要管理機關可反對對公司之司法裁判之效果

無論公司之主要管理機關設在澳門或非設在澳門，當出現《民事訴訟法典》第 41 條第 1 款及第 2 款之情況，只要該管理機關以第 41 條第 3 款作出有關行為即視具有當事人正當性。“其目的是使公司之地方管理機關的運作更為靈活及方便”¹³⁷。

第三組：

最後，《民事訴訟法典》第 42 條所指出之不規則之法人為第 40 條所定之原則之例外情況。

這些實體指法律要求以公證書組成，但無按法定形式組成之實體。

按照《民事訴訟法典》第 42 條第 1 款之規定，債權人既可起訴該法人，亦可起訴須就該法人之行為負民事責任之人，或同時起訴兩者。

這些不規則之法人在其作為被告而參加之程序內，可提出反訴（反請求——在某些情況下法律容許被告在答辯時反對原告而提出之請求，見《民事訴訟法典》第 419 條）。

由此可得出下述結論：不規則之法人僅具有消極法律人格（只可作為被告），即使可提出反訴亦然。在訴訟程序內不能作為原告而出現。

例子：

A 是不規則法人 B 之債權人，債權金額為 20 萬澳門元。

另外，B 是 A 之債權人，債權金額為 10 萬澳門元。

B 不能訴 A 而要求償還 10 萬澳門元，但如果 B 被 A 起訴，要求他償還 20 萬澳門元，B 可在反訴中要求償還 10 萬澳門元，故進行債務抵銷。

然而，當出現《民事訴訟法典》第 42 條第 3 款之情況時，亦可以獲得保障。

B. 無當事人能力之程序後果

無當事人能力基本上產生兩個法律後果

1. 倘無當事人能力十分明顯，在程序開始時法官亦已知道，應對起訴狀作出一個初端駁回之裁判（《民事訴訟法典》第 394 條第 1 款）；
2. 倘法官只在稍後才發現無當事人能力，應放棄對案件實質問題之審理（見《民事訴訟法典》第 413 條第 1 款 c 項），駁回對被告之起訴¹³⁸。

¹³⁷ 見 Alberto dos Reis 教授之作品。

¹³⁸ 即使在提交訴辯書狀階段後才發現這種欠缺，在清理批示內駁回起訴（第 429 條第 1 款 a 項及第 563 條第 1 款）。

正是這個前提，一如其他前提般，在以法院對其作出審理時之情況為準，法官應要求當事

倘其中一方當事人無當事人能力，則程序會消滅，但並不妨礙相同之當事人，對相同之問題、針對相同之標的而重新提起另一訴訟。

C. 無當事人能力之補正

原則上任一方當事人無能力是不能補正的。

現行《民事訴訟法典》第 41 條第 3 款及第 42 條第 3 款針對這些分支機構及不規則法人的當事人能力，是可以補正的。

但可以發生：在訴待決期間，即作出初端駁回或駁回起訴批示之前，無當事人能力之當事人取得這種能力。

例未依法定形式成立之不規則公司提起一訴訟，但在作出初端駁回批示之前，這間公司按法定方式成立。

在此情況下，這訴訟可繼續，因為嚴格言之，這個瑕疵已終止，而非被補正《民事訴訟法典》第 42 條第 3 款。

21.2. 訴訟能力

A. 概念及範圍

關於當事人之訴訟前提，一如上文所述般，目的是確保完全落實辯論原則，最終乃保證作出一個適當、公平及有效用之裁判。

此稱為**在法院進行訴訟的正當性**，其概念及尺度定於《民事訴訟法典》第 43 條內：獨立進行訴訟之能力，無須由法律規定之代理人代表，其能力範圍與權利能力一樣。

能力乃法人固有之特性——在程序上體現在有效地自行行使訴訟權利及履行有關之義務及負擔，但不應將這種概括性能力與**對案件之正當性**混淆——後者是指提起某特定案件之正當性。

這樣，**訴訟能力**相當於行使訴訟權利及承擔義務之一種能力，與當事人可自願地選定之一名代理人而參與訴訟無關（例受權人），亦同由律師輔助之可能性無關（屬於技術代理），即使聘請律師屬強制性亦然。

公司及法人組織代理亦非因無訴訟能力，因為在法院訴訟過程中須由章程或法律所定之代理人任代表；基於其本身之性質，在法院內須有代理人，一如在非司法關係上亦然。

按照實體法之規定無**行為能力**者則無**訴訟能力**，前者乃後者之標準（《民事訴訟法典》第 43 第 2 款）。例未成年人之無能力並非完全無能力（《民法典》第 116 條）¹⁴¹，任何無能力人只可透過法定代理人才可參與訴訟程序（《民事訴訟法典》第 44 至第 46 條）。

故在這點內容上實行一致之法定原則，一如當事人能力般。分別僅在於**當事人能力**並無尺度可言：只是有當事人能力或無當事人能力。

在實體法上之行為能力與（程序法上）訴訟能力之關係較易設定，前者是後

人糾正這種缺陷。

¹⁴¹ 對於因勞動而取得之財產之處分行為之有效性，十六歲之人可在法院爭論這些行為。

者之楷模（即由前者決定後者）。

作為這個原則之必然後果：

1. 有實體法之完全行為能力（權利及義務）（程序法稱為行使權利之能力）之人，有完全之當事人能力；
2. 無實體法之完全能力者，在訴訟法上亦一樣；
3. 在民法上只有部分能力之人，或獲得法律授予特別能力（法人——見《民法典》第 144 條），在訴訟法方面原則上亦是以實體法為準界定有訴訟能力之人或無訴訟能力之人。

此為通則及其必然後果。

但有例外之情況：在某些情況下，為了認定某人在一個程序內為有能力人或無能力人，我們先須調查產生實體關係之法律上之行為是否屬於該人之行為能力範圍內。倘屬於該範圍，該人可獨立起訴或應訴，否則不能。

現需作出某些便於學習及明白這個訴訟方面之概念之區分。

首先，法律區分自然人之**法律能力**及**訴訟能力**（稱為自然能力），與法人及公司之**法律能力**（行為能力）及**訴訟能力**（組織上之法律能力）。

按照另一個標準，無能力之狀況還可分成兩種：**法律上之無能力**及**事實上之無能力**。

我們舉例說明之：

A. 法律上無能力之情況：

1. 未成年——通則是未成年人無法律能力，按實體法之規定須由親生父母或監護人任代理。
2. 禁治產人——無保佐人任代理，禁治產人不得參予訴訟程序（《民法典》第 122 至第 134 條）。
3. 準禁治產人——見《民事訴訟法典》第 47 條，在這種情況下，法律要求有一個保佐人輔助（《民法典》第 124 條）。

b. 事實上無能力之狀況：

指載於《民事訴訟法典》第 48 條之情況，只是述及消極無能力，或者是認為處於這些異常條件下之人（精神異常或其他嚴重之原因），提起訴訟之可能性不大。

B. 相當於無訴訟能力之狀況

《民事訴訟法典》第 49 及第 51 條規範了訴訟程序內不確定人及失蹤人之消極地位。

為了發生訴訟法律制度之效果，法律視這種情況等同於無訴訟能力；不確定人，可作為被告而成為訴訟之一方當事人，故應受到法律之特別保護，保證其可求諸司法裁判。

通則是檢察院依職權保護不確定人。只有無人履行這個角色，檢察院方被要求維護未成年人或失蹤人之利益（第 15 條）。

倘檢察院已代表原告，則失蹤人、無能力人及不確定人應由法院委任之辯護

人任代理（第 49 條第 2 款及第 50 條）。

C. 無訴訟能力之後果及補正

無訴訟能力之後果等同於無當事人能力：

1. 倘這種欠缺屬於明顯，則初端駁回起訴狀《民事訴訟法典》第 394 條第 1 款 c 項或第 55 條第 1 款規定無訴訟能力及代理不當，透過無訴訟能力之人之正當代理人或其保佐人參與訴訟或傳喚該等人參與訴訟予以補正；又或
2. 倘經傳喚被告後，被告在答辯時提出（原告）無訴訟能力之抗辯，又或之後法官依職權審理這個問題，則駁回起訴《民事訴訟法典》第 413 條及第 429 條。

在這兩種情況下（在第一種情況下必駁回起訴，後者只有裁定抗辯事由成立方如此），法官不對實體問題作出裁判，僅作出一個形式裁判，關於其價值及範圍，在上文我們已指出。

但須澄清：根據《民事訴訟法典》第 55 條，第 56 條及第 57 條規定**無訴訟能力**及代理不當是可補正的。但配合第 6 條的規定，法官有義務主動要求補正的。

21.3. 當事人之正當性

A. 概念

《民事訴訟法典》第 58 條界定了正當性這個概念，且更正了舊法典第 26 條所引致之爭論。

正當性亦是關於當事人之**訴訟前提**，以當事人能力及訴訟能力之存在為前提，但亦有別於兩者，並非一個針對所有訴訟程序皆應符合之一個劃一之要件，相反是指當事人相對於某個訴訟之一種具體狀況而言。更嚴格言之，即是指相對於某訴訟法律關係（由請求及訴因確定）之直接標的而言。

按照 Henckel 之理論，最根本的是由正確之當事人作為原告及被告參予訴訟，即按照德國人關於正當性這個概念之理解：這是推動訴訟進行之權力。

須清晰知道的是：並非任何與訴訟無任何關係人，皆可在法庭內對標的進行討論。

按此意思，《民事訴訟法典》第 58 條（正當性之概念）規定：在原告所提出出現爭議之實體關係中之主體具有正當性，但法律另外指明者除外。

為清晰理解《民事訴訟法典》第 58 條（正當性之概念）規定，我們可以援引《民法典》第 251 條第 1 款，第 1301 條第 2 款及第 1926 條第 1 款規定為例，無須為爭議之實體關係中之權利人也具有訴訟當事人正當性。

此外，訴訟所針對之利益亦可以為非自身之利益，而是一集體之利益。如《民事訴訟法典》第 59 條維護大眾利益之訴訟規定：對於尤其旨在維護公共衛生、環境、生活質素、文化財產及公產，以及保障財貨及勞務消費之訴訟或保全程序，任何享有公民權利及政治權利之居民，宗旨涉及有關利益之社團或財團，市政廳以及檢察院，均有提起以及參與之正當性。

B. 單數之正當性與近似之前提之區分

現在對《民事訴訟法典》第 58 條及續後作深入之分析。

屬於法典內其標題：“正當性”，以其為基礎而適用於關於正當性之一般性理論尤其在宣告之訴及保全措施當中¹⁵²。

我們假設只有一個具有爭議之實體法律關係，積極及消極方面之當事人皆為一人，因此在法庭上對該關係進行爭議的只有一個原告及一個被告。

為何如此？

很易明白到：倘對案件之實質問題所作出之裁判有利之人不參與程序，或會受損害，這個裁判不能產生正常有用效果，因為不能約束真正之關係主體。

要求符合這個前提，是因為法律有意避免對案件之實質問題進行無用之訴訟。

曾在上文指出，作為訴訟前提之一之正當性，同其他訴訟前提相近：當事人能力及訴訟能力。但後兩者乃在抽象及概括層面上要求之要件，以便當事人到法院能參與起訴或應訴行為，而正當性則以兩者為前提，屬指相對於案件之具體標的而言、當事人所處之主觀地位。在正當性方面不能排除具體個案之特殊情節¹⁵³。

另一方面，學理亦將正當性同另一個要件區分：稱為**訴之利益**，在《民事訴訟法典》將其特定為訴訟前提——第 72 至第 73 條，其名稱為“訴之利益”。

訴之利益是指在客觀上有充足理由提起司法訴訟；換言之，是與啟動審判權有關——自開始發生利益衝突時起，則可在適時及認為適宜時即可以啟動（《司法組織綱要法》第 4 條）。

一個人可以實際是一個權利之擁有人，故在法庭內是爭執該權利之當事人；然而，倘若關於其權利之存在，並無客觀及嚴重之疑問之存在，倘他提起一確認之訴，目的是宣告該權利存在，則無提起訴之利益。

Magalhães Collaço 教授認為：“可以有權利存在、但無在司法程序上主張該權利之利益”。

作為對實體問題作出審判之訴訟前提，有別於實體正當性（指實體權利之處分權）——此為訴之條件，訴訟理由成立之一個要件。

從《民事訴訟法典》第 58 條中可得知：有時法律賦予其正當性之人並非具爭議之客體法律關係之權利人。

有學者稱這些情況為“非常正當性”。

我們看看某些例子。

《民事訴訟法典》第 215 條第 1 款規定：因生前行為而移轉出現爭議之物或權利時，如取得人未藉確認資格此附隨事項而獲准替代移轉人，則移轉人仍具正當性參與有關案件。將轉讓人之正當性延伸至轉讓之後，直至受讓人之身分獲確認並取代前者為止。

¹⁵² 關於執行之訴，正當性之內容見規範在第 68 條至第 71 條——將是民事訴訟法 II 之分析內容。

¹⁵³ 傳統上，將訴訟能力稱為 *Legitimatio ad processum*，而正當性稱為 *Legitimatio ad causam*（相對於某訴訟之立場）。

在其他情況下，也可能將正當性延伸至其他非實體法律關係之主體之人，但其可以介入以該法律關係為標的為司法訴訟。

例如待分割財產管理人¹⁵⁴，可以提起占有權之訴而訴其他繼承人或第三人，目的是要求其交出應由其管理之財產（《民法典》第 1926 條第 1 款）。

又如遺囑執行人¹⁵⁵——按《民法典》第 2153 條 b 項之規定：監督遺囑處分之執行，及且在必要時向法庭維護遺囑之有效性。

又如共同所有人：任何共同權利人均可以要求第三人返還共有物，而被告則不能以該物並非完全屬於該共同權利人而對抗之（《民法典》第 1301 條第 2 款）。

要有訴訟正當性，在起訴時須有一種特定之利益，只有這樣某人才可以提起訴訟及獲得一份關於實體問題之判決。在 1806 年拿破崙民事訴訟法典生效時，法國人就指出：“有利益才有訴訟”¹⁵⁶。

肯定的是：一如上文所說般，確定正當性是民事訴訟法最困難之一個問題。

在現行成文法內，我們已有指出關於該概念之一般性理論之規範，事實就是並非在任何情況下皆如此：可將其歷史可分成不同之階段，視乎學理之主流取向（無法律明示規定）而定。

過去，學者認為法律應就每一種訴訂立正當性之要件——我們可稱此為按個別情況處理之時期。

但現實往往難以預測，不能將所有情況列入一個普遍及抽象假設內。

為此須建立一個關於正當性之一般理論，在訴訟法無規範之情況下（1876 年之葡萄牙民事訴訟法），由學理去擔任這項工作。

當時將正當性問題與訴之理由成立或不成立互相混淆。在一個複雜綜合性觀念內，正當性之概念包括所有今日我們所稱之，關於當事人之訴訟前提相對獨立於實質問題外之所有概念。在 1876 年之法典內，只在最後判決時才對正當性問題作出審理¹⁵⁷。

這個正當性之綜合觀念得到意大利訴訟學家之認同。其中有 Ugo Rocco，對這位學者來說，正當性概念包括由法律規範以概括及抽象方式確定之一套狀況、條件及身份——這些身份集中在某個法之主體上、容許審判機關從中獲得對某種法律關係之存在或不存在之認定。

在葡萄牙學理內，有人贊同這個理論，例視下述情況為正當性之要件：

——身份（提起訴訟之人與主張權利擁有人身份之人同屬一人）；

——利益；

——可要求性；及

——權利之侵犯。

在所有這些要件之中，似乎只有利益才享有自主性，而最後兩個要件乃訴訟

¹⁵⁴ 其功能見規範在《民法典》第 1917 條。

¹⁵⁵ 其概念見《民法典》第 2147 條。

¹⁵⁶ 葡萄牙訴訟法律對界定正當性而採用之標準受法國學理影響。

¹⁵⁷ 在《立法與司法見解雜誌》公布。

理由成立之條件，而非訴訟前提。

Paulo Cunha 教授主張一個綜合式之正當性概念，除上述要件外，他還補充道：“無被法律明示排除者”。

今日，我們有一個載於第 58 條之較簡單之正當性概念；雖然以程序經濟原則為名，有意給予正當性一種廣泛之功能，但事實並未能做到。

按照 Anselmo de Castro 教授之意見，正當性是辯論原則之必然後果，因為是為確保判決之正常效力。

事實上，是由 Barbosa de Magalhães 與 José Alberto dos Reis 兩位教授引起之分歧，繼續使後來之葡萄牙法律專家意見分歧，而非僅限於兩間學府（里斯本及科英布拉）之分歧，即使如此，意見仍然不統一¹⁵⁸。

雖然採納第 58 條規定（“原告所提出……之關係……”）之解釋並非決定性，然而我們認為是較為可取的。1990 年之葡國法典草案採納之立場為：“提出主張之權利人”（而非具有爭議之實體關係之權利人）。

C. 複數正當性：共同訴訟與及聯合

如上所述，基於程序本身之性質，程序必有雙方性，其中必有立場不同之兩個主體：積極一方之當事人及消極一方之當事人、原告及被告。

我們將注意力集中在當事人為單數之情況，兩體性——此為通則。

當爭議之法律關係在積極及消極方面皆只有一個主體，在程序上稱為**單數正當性**。

當有超過一個以上之積極主體時，或有超過一個以上之消極主體，或在積極及消極方面皆有一個以上主體，稱為複數正當性（積極、消極或混合）¹⁶¹。

在複數正當性之情況下，在非所有利害關係人參與程序可能引致參加人無正當性，因為法律關係之處分權屬於全體利害關係人。簡言之，非全體參加將可引致欠缺一個訴訟前提（《民事訴訟法典》第 61 條）。

然須將之與主體合併之情況區分，表面上一樣，但有不同之性質。

在某些情況下，在第三人與主要當事人間有一種從屬關係：例輔助人之情況（《民事訴訟法典》第 276 條）。一如我們知道般，屬於輔助當事人：在程序內維護自己本身之一個利益（而非他人之利益），但同時從屬地輔助任一方當事人。

在此情況下，當事人為複數，但處於從屬關係，而非平等關係。

不同的情況是第三人與其他參加人在平等層面上參加程序，處於一種平衡之關係上當事人是**主當事人**，廣義上稱為**共同訴訟人**。

此為主體合併之概念，屬於訴訟程序中複數之情況，依 Carnelutti 所說：此為訴訟程序概念，其根源來自羅馬法，且可有不同之方面，可再細分成其他細小概念。

如此：

¹⁵⁸ 例 Luso Soares，他是里斯本學派，似乎傾向於 Alberto dos Reis、Antunes Varela 及 Anselmo de Castro 教授之立場。

¹⁶¹ 應注意到：“當事人之複數”，相對的是“當事人之兩位性”，而絕不會只有一名當事人。

a. 關於複數之性質：

首先須先區分狹意之共同訴訟（《民事訴訟法典》第 60 條至第 63 條）與聯合 Coligação（《民事訴訟法典》第 64 條至第 66 條）。

b. 關於淵源：

應該區分兩種情況，一是當事人爲眾數乃是：

——由法律；

——由當事人約定；或

——基於法律關係之性質（《民事訴訟法典》第 61 條）所強制；

而另一種由於自願所致，即表示一個行使得到法律同意或源自當事人協定之權能（《民事訴訟法典》第 60 條）。

在第一種情況下，我們面對的是**必要共同訴訟**，在第二種情況下爲普通共同訴訟。

一如源自《民事訴訟法典》第 63 條之規範般，在**必要共同訴訟**內，在訴訟中任一方當事人方面有訴訟之共同倚賴性，而無自主性；在**必要共同訴訟**內，相對於其他共同當事人而言，各自保留其本身之自主性。

但在所有這些情況下，除了主體複數外，我們稍後會知道，爭議實體關係具有單一性。

C. 關於出現之時間，訴訟開始時是複數有別於續後或稱嗣後複數。

前者始於程序之開始，即訴訟法律關係成立之時，而後者則在程序行進之過程出現。

這種續後複數，將在“訴訟程序之附隨事項”一章內加以規範，因此當我們研究動態之訴訟法律關係之起始、發展及消滅時將會探討。

I

現在將我們的注意力放在具有法律給予其雙重特性¹⁶²之**共同訴訟**。

普通共同訴訟見規範在《民事訴訟法典》第 60 條及第 63 條第 2 部分內。

從這些規範中可得知：在訴訟程序內當事人爲複數之情況相當於實體法律關係之主體爲複數之情況；但爲了訴訟效果，主體之結合乃源自當事人主動爲之。

在這情況下，爭議實體關係爲多個之主體同時在法院出現以爭辯其權利及義務，是各人共同參加以行使一個權能，並非法律或法律關係之性質強制所有人參加訴訟程序。

在這些情況下，訴訟程序可僅在某些主體參與之情況下有規則地進行：

——或者因爲法律是容認全部或部分主體參加程序。

——又或是因爲法律明示地指出程序可在部分主體參加之情況下進行。

最典型之例子見於債法內，例關於連帶之債：其中有多個連帶債權人（權利

¹⁶² 在 1939 年《民事訴訟法典》生效之前，只是學理及判例使用 *Litisconsórcio* 一字，一如 Paulo Cunha 所述般，這個字從意大利引入。

在 1939 年之法典內，這字作爲概括性用語，似乎包括當事人之全部情況，故引起很大爭議。

連帶性)，任一債權人可對其中一個債務人或多個債務人提起訴訟，或屬於一種義務連帶性，債權人可對其中一個債務人提起訴訟（《民法典》第 510 條）。法律在這方面非常明確。

關於**必要共同訴訟**，我們可以再細分成：

a. 法定必要共同訴訟，即由法律訂定。

例針對配偶兩人之訴訟（《民事訴訟法典》第 62 條），由配偶兩人作出之行爲而產生之訴；又例如不可分之債之訴內，倘債權人希望獲得一給付，須起訴給付之所有債務人（《民法典》第 528 條第 1 款）；

b. 約定之必要共同訴訟：指由實體法律關係主體約定所致。

例 A 將一筆現金借給 B 及 C。在該借款合同內，A、B 及 C 約定 A 只可以同時要求 B 及 C 同時還款。

c. 自然之必要共同訴訟：指實體法律關係性質本身所強施之共同訴訟

倘無全部主體參加訴訟，審理問題之判決將不能發生其正常有用效果。

倘裁判確定性地解決爭議，法院之裁判將發生其正常有用之效果。

例如以撤銷由 A（債權人）與 B 及 C（債務人）所定立之合同爲目的之訴內，倘 B 有意撤銷該合同，指稱他因爲錯誤或故意而承擔債務。

B 應針對所有參加人（A 及 C）而起訴，否則裁判將不發生其正常有用之效果：倘其中一個債務人不參與訴訟，將不能確定性地解決爭議，因爲法院之裁判只約束訴訟參加人。爲此，倘由於 C 無被起訴，故在另一新訴內再次就合同是否有效提出爭議，此有可能引致判決間之矛盾¹⁶⁴。

出現上述三種之任一情況，如不遵守必要共同訴訟必引致無正當性之情況。

II

現在我們看看載於《民事訴訟法典》第 64 及第 66 條所述之聯合。

由於亦是屬於**複數當事人**之情況，須將其與**共同訴訟**情況作一比較，以便得知其不同之處。

這個問題引起很大爭議。所有的人皆同意：在**共同訴訟**內，當事人爲複數，但關於其他元素則爲屬於單一性；在聯合內，除了當事人爲複數外，其他元素亦爲複數。

到底這兩個概念有何分別？

倘稍爲留意，《民事訴訟法典》似乎使用兩個不同標準作區分：在第 60 條及第 61 條，共同訴訟係以爭議之實體關係之**單一性**作界定（這個術語一定是單

¹⁶⁴ 另一個例子就是由澳門高等法院在上訴案內解決之一個例子（1994 年 5 月 4 日之合議庭裁判（見 1994 年之中文版《司法見解》第 354 至 356 頁）。其概要爲：“在提交賬目之訴”內，如有權請求提交賬目的權利人係多於一人的，則這一些權利人必須全體參與訴訟，否則就不具正當性因僅存有唯一的實體法律關係，其性質使到全體利害關係人須參與訴訟程序，以便所宣示的裁判產生正常有用的效力。

數)；第 64 條及第 65 條則是指聯合，故指出請求為複數。

這樣，意見開始出現分歧：對於一些人來說，區分之標準是利益之單一或複合標準；對於其他人來說，須考慮請求為單一或複數。

最多人支持之理論是：在聯合內（亦稱為 *conjunção*——倘被告為複數；請留意在第 64 條第 1 款所使用之副詞），具爭議之實體法律關係亦為複數。

此為我們認為較適合之立場，似乎並無同法律關於訴訟主體合併之兩類情況有衝突。

一方面，有人接受在**共同訴訟**內，可將兩個或多個請求合併，但並非分別地提出，有超過一方以上當事人訴超過一個以上之當事人，並非提出不同之請求，相反請求之內容及依據基本上相同，故互相協調。

另一方面，關於聯合，法律所述之請求為複數乃源自實體法律關係。在聯合內，各個請求都不同，及與不同之當事人有關，基於這個原因，必須對聯合訂立限制，否則引致訴訟程序混亂。

倘無法律障礙，同一個程序可供就不同性質之問題進行爭議，而且所涉及之人不同、利益亦完全不同，此為一種違反共識之行爲。但不妨礙在同一程序內（基於訴訟經濟原則），盡可能解決多些爭議。

《民事訴訟法典》第 64 及第 65 條規定了聯合之實體要件及程序要件。

前者，稱為實體問題之要件，法律用正面之方式規定；後者為形式要件，以否定之餘方式規定。

即聯合訴訟之合法性取決於：

——須符合第 64 條所列之任一實體要件；以及

——無任何第 65 條所指之程序要件出現，但該條文所述之例外則除外（第 1 及第 2 款最後部分）。

換言之，第 65 條之規定表示了對第 64 條內容之一種限制，為此，第 64 條之適用涉及不出現第 65 條所述之情況。

現在我們分別分析各類型之限制，並舉部分例子加以說明：

1-訴因一致及單一，但各個請求不同。

A 訴 B，以由撤銷一份在脅迫的情況下訂立之合同，而同時訴 C 因 C 脅迫其簽訂前述合同而要求 C 賠償。

2-各請求之間存有一種從屬關係。

A 訴 B，請求將兩人訂立之合同宣告為無效，同時訴 C，要求其返還先前 B 交予 C 之款項（返還乃合同無效之後果——《民法典》第 282 條第 1 款）。

3-主請求之理由成立主要取決於對同一事實之認定（訴因不同）：在一宗火災中，被銷毀房地產之各個承租人同時向一公司購買保險，這樣他們可以聯合針對該保險公司提起起訴訟。其理由成立取決於對相同事實之認定，與是否為多份合同無關。

4-主請求之理由成立主要取決於對相同法律規則之解釋及適用：

A 針對 B 及 C 同時提起撤銷與各人簽定之合同之訴訟，依據為這兩份合同

之標的違法，因合同之標的皆被法律規範所禁止。

5-主請求之理由成立取決於對合同條款之解釋及適用：

一保險公司可同時訴多個無交保險金之被投保人，依據就是各份不同之保險合同，但合同之條款一樣（完全一樣是十分普遍）¹⁶⁵。

至於程序要件或形式要件，一如《民事訴訟法典》第 65 條所規定般。基本上有兩個：

- (1) 程序形式相同（倘形式不同是因為訴訟利益值所引致者除外）；
- (2) 法院對審理不同之當事人之各個請求有管轄權，即是說，根據法院管轄權之強行性規則之規定聯合並無產生無管轄權之情況時。

例就一名檢察官之行爲而產生之損害，而向一審法院提出賠償訴訟，同時追究其他人之責任，在這些情況下不能聯合訴訟，因為對這些司法官員之訴，是上級法院享有專屬管轄權（澳門《司法組織綱要法》第 36 條第 2 款。）倘原告在起訴狀提出之請求須以不同之訴訟形式進行，則不能聯合。

例倘其中一個訴訟須以特別程序進行，而另一則以普通程序進行，鑑於進行訴訟之形式不同¹⁶⁶，故很容易明白是不適宜聯合一同處理。

例一原告要求返還一正由第三人占有之房地產，而另一原告之請求為分割該房地產分割，因為普通程序適用於前者，而後者適用《民事訴訟法典》第 946 條及續後之特別程序，故不能聯合。

最後一點是同法律對聯合所定之自願性質有關：1.“容許聯合訴訟……”（第 65 條第 2 款）；2.“同樣可合法地聯合……”（第 65 條第 3 款）。

¹⁶⁵ 在我們繼續分析聯合所需之法定要件之前，爲了更好地理解所述之例子，或須扼要地談談訴因及訴求這兩個概念。

透過《民訴訴訟法典》第 417 條第 4 款可知訴因是指作為原告人之請求之依據之具體法律事實。按照同一條文第 3 款之規定：訴求是指原告人欲得之法律效果。這兩個元素（訴因及訴求）是使首份書狀——起訴狀不會被視為不適當之關鍵要素（《民事訴訟法典》第 139 條第 2 款）。

按照主流學理及司法見解，法律所述之事實是指具體法律事實，現實生活之事實，而非法律抽象所定之事實。

例：援引取得時效（*usucapião*）仍不足夠，還需指出可使占有（*posse*）產生取得時效之具體事實或行爲；僅主張有故意（*dolo*），並不足夠，還須描述構成故意之具體事實；作為離婚請求，僅主張“過錯地違反配偶之義務”還不足夠，應援引構成這個法律術語之具體事實。

正是這些具體事實反映出訴因之特性，即兩個訴訟法律關係之直接客體。

關於形成之訴，第 417 條第 4 款明示地談及具體事實。

原告必須援引產生訴求之具體事實，即擁有權利之依據，指產生該權利之事實，擁有人身份之成因。

訴因是程序之一個獨立元素，是程序之一個直接組成元素。在受理範圍方面法官受制於由原告援引之訴因。故此除了被告援引作防禦之事實外，無需調查形成原告權利之創設性事實，以及有關權利之消滅性、阻止性或變更性事實（見《民事訴訟法典》第 564 條）。

¹⁶⁶ 見條目 5.2 所述之內容。

倘我們特別留心，無論在共同訴訟或聯合訴訟內，有自願形成之情況，亦有強制性出現之情況。如此，在普通**共同訴訟**內，基於意願，多個原告集合在一起，然倘只是其中一個原告合法地針對多個被告起訴，這些被告可被要求參加程序，是無須考慮其意願為何。

共同訴訟或聯合屬於自願性，須由原告或被告並非強制地集體參加程序。

在此情況下，單獨起訴不會產生無正當性，應任何當事人之請求各訴訟可以附文的方式處理，倘程序之狀態或無其他別特別理由不可使以附文方式進行產生不便，法官會批准這項請求（《民事訴訟法典》第 219 條）。

但亦可以發生：有合法之原告之聯合，在清理批示內法官可依職權或應其中一個被告之請求、基於舉證及審判之便利、清晰及適時，宣告以單獨程序分開審理，即使符合聯合所需之要件亦然（第 65 條第 5 款）。

D. 無正當性·其後果及補正

無正當性，一如欠缺其他訴訟前提般¹⁶⁷，可產生兩種後果之其中一種：

- (1) 初端駁回起訴狀：倘在程序首個階段法院已知悉當事人無正當性（《民事訴訟法典》第 394 條第 1 款 c 項）；
- (2) 駁回起訴：倘正當性在程序後期被法院知悉法院不對實體問題作出表示並駁回起訴（《民事訴訟法典》第 412 條第 2 款 e 項）。

當事人無正當性通常是不可補正之程序瑕疵，

然而，倘無複數正當性，法律容許對瑕疵作出補正之可能性，按照《民事訴訟法典》第 66 條規定；或主要參加人在附隨事項中透過傳喚欠缺之人，誘發其參加程序——有關制度見規範第 267 條及續後，則可補正。

因此可知制度之分別所在，因為在無複數正當性之情況下，程序不會在實體法律關係以外之主體間進行：即是只有部分當事人參加程序，另外一部分無參加，但應該參加之情況。

21.4. 強制法院代理¹⁶⁸

A. 概述

關於當事人訴訟前提¹⁶⁹之研究要求我們先認識在法院之代理——指訴訟代理，見《民事訴訟法典》第 74 至第 86 條。

在法院之代理是指由具有專業資格之人士在訴訟中協助及指引當事人，以當事人之名義在法院內行使權力，或作出某些特別之行爲。

為此給予當事人之技術援助，即使是完全有能力人、亦可得到律師、見習律師或法律代辦人之援助，透過其作出適當之訴訟行爲。

法院代理有其本身之一種特殊性質；在強制性之情況下，由於是法律強制規定，應列為訴訟前提，因為倘無律師參加、某些訴訟法律關係不能開展。

¹⁶⁷ 在葡萄牙民事訴訟法典草案內確立了“欠缺訴訟前提”一章，其中包括所有訴訟前提。

¹⁶⁸ 關於這個內容，見民事訴訟註解第 32 至第 44 條所述——舊《民法典》的第 1 條至第 136 條，第 104 頁至第 121 頁，但在理解這問題上需要考慮立法時之立場。

¹⁶⁹ 訴訟法律在這一章之標題為“當事人”——《民事訴訟法典》第一卷第一編第二章。

代理人在法院進行之工作稱為代理及作出訴訟委任。

此外，法院之代理亦需遵守某些行為之前提，因為在需律師代表當事人之情況下，某些行為可自己作出，而另外一些行為則只可由受托人或代理人作出¹⁷²。因此，在法院之代理亦是訴訟前提之一。

通常基於兩個原因而要求有律師之強制代理：

(1) 心理原因：

當事人或大或小欠缺以必需之嚴肅性在法院處理有關爭議，即使是非常專業的律師，在涉及其本人之訴訟中，亦會影響其對事物的客觀性，甚至有人說，那些替自己辯護的人，其顧客就是“瘋癲”。

(2) 技術原因：

在大多數之案件中當事人缺乏經驗及不可或缺之專業知識去推動訴訟良好地進行，因此，若自己進行訴訟，往往不能很好地按照法律要求處理。恰如 Antunes Varela 教授說：“當事人並不是掌管司法行使審判職能之理想伙伴。”¹⁷³

因此，在法院之代理是強制的是以當事人之利益及良好地掌理司法之名義而被要求的，目的是為了保證訴訟之嚴謹性。

當事人與專業人士律師、實習律師或律師業之從業員、或法律代辦（由於核准澳門《民事訴訟法典》之第 55/99/M 號法令於 10 月 8 日第 5 條第 1 款規定，法律代辦將會在澳門消失）間簽立之委任合同賦予代理人權力¹⁷⁴，該行為可以授權書之類似文書為之¹⁷⁵，亦可根據《民事訴訟法典》第 77 條第 2 款規定：以口頭聲明，並載於訴訟程序中採取之任一措施之筆錄內之方式為之。

B.應將法院代理與其他相近之概念區分，否則很易產生混淆。

不應將法院代理與司法援助混淆，後者是指法律對某些經濟狀況欠佳而無能力承擔正常訴訟費用之人、亦即是說，無能力支付律師費及訴訟費用之人。

司法援助起源於雅典及羅馬，當時是基於對不幸人士之同情而設立。

在葡國，這個概念追溯至《亞豐素律例匯編》之時代。

今日，這些人因經濟問題而被拒絕訴諸法律求取公正則屬於違反（《基本法》第 36 條）。

這種優惠既可包括法律諮詢，亦可包括全部或局部免繳訴訟費之預付金及指定代理人，或其中一種利益。在這確立了一個神聖之制度無論權利人之經濟能力為何，都可以通過司法途徑維護任何一個權利。

今日，訴諸法律及求諸法院乃一個基本權利之其中一方面之發展——以法律面前公民平等原則為基礎，載於 1948 年《世界人權宣言》內。

在澳門，該內容載於 8 月 1 日之第 44/94/M 號法令內。

¹⁷² 第 74 條第 2 款準許當事人在必須聘請律師之情況下可提交無法律爭議之問題。

¹⁷³ 見 Antunes Varela 教授 《民事訴訟手冊》第 190 頁。

¹⁷⁴ 關於委托，見《民法典》第 1083 至第 1110 條，亦見現行《司法組織綱要法》第 67 條訴訟代理人及《基本法》第 92 條關於執業律師之規定。

¹⁷⁵ 見《公證法典》第 128 條及《民法典》第 255 條。

亦不應將法院代理同向律師提供之技術援助混淆——後者見載於《民事訴訟法典》第 84 條內。

21.5. 訴之利益或起訴利益

A. 訴之利益之概念

在上文已指出了學理視訴之利益（或稱起訴利益）相對學習任何一個訴訟前提有其本身之自主性：當事人正當性

起訴利益同訴諸司法途徑之需要有關：當某些利益同權利發生衝突則有理由及適時訴諸司法機關。原告主張及證明其擁有一個權利仍不足夠，還需要在客觀上該權利需要得到實際之保護，此為司法訴訟案之基礎。

如此，只有權利被侵犯及其擁有人需要恢復其權利時方有起訴之利益。

在此情況下並無疑問存在。

但假設權利並無被侵犯；即使如此，在某些情況下，是否有訴之利益存在（例確認之訴）？請求判定將來給付之訴及給付持續到期之訴？

因為訴之利益作為有名前提而出現在澳門《民事訴訟法典》草案內，我們看看在各種情況下這個要求之作用。

- (1) 在確認之訴中（《民事訴訟法典》第 73 條第 1 款），如原告採取行動欲解決一客觀上不確定及嚴重之情況，則有訴之利益。
- (2) 在給付之訴中（《民事訴訟法典》第 73 條第 3 款 b 項）如債務仍未到期，只要出現第 393 條所指之任一情況，則仍有訴之利益。
- (3) 在給付之訴中（《民事訴訟法典》第 73 條第 3 款 a 項）如債務已到期，則有訴之利益，但原告擁有明顯具執行力之憑據者除外。
- (4) 在給付之訴中（《民事訴訟法典》第 393 條第 1 款）如屬定期給付之債務，只要債務人停止支付其中一期，則有訴之利益，如原告提出請求請求，法官不單可對已到期之給付作出判決，亦可就在債務維持期間內將到期之給付作出判決。
- (5) 在形成之訴中（《民事訴訟法典》第 73 條第 2 款），如不能透過原告作出一般之單方行為獲得所欲達之法律效果，則有訴之利益，反之無需法院介入。

上述基本上確立了 Antunes Varela 教授所述之學理——見其《Manual de Processo Civil》（第 179 頁至第 187 頁），關於該概念實踐分析之部分。然而，其部分理論受到 Miguel Teixeira de Sousa 之猛烈批評（見由其著之《在宣告之訴內之訴之利益》¹⁷⁷）。

很明顯，一如正當性般，訴之利益亦分成兩個方面：

¹⁷⁷ 為里斯本法學院學會於 1989 年出版之作品，該作者認為：視訴訟之利益作為實體判決之要件正如載於舊《民事訴訟法典》第 26 條關於正當性的規範要求般。有一個例子：倘在一訴待決期間（請求判被告交付一可替代物），而該物已變壞，原告則無訴之利益，因為司法保障對他已沒作用。為此，程序法律確立了一個因嗣後無效用為理由而消滅訴訟關係（舊《民事訴訟法典》第 287 條 e 項）；現行澳門（《民事訴訟法典》第 229 條 e 項）。

- (a) 起訴之利益（從原告立場觀之）及
- (b) 反駁之利益（從被告立場觀之）。

對原告有利及對被告不利是有積極及消極訴訟利益所需之利益，按起訴時之具體狀況加以認定，而不能在抽象層面上申明有或否定有訴之利益。很明顯，原告之訴訟利益與被告之訴訟利益有相關之關連性。

為此，可以指出訴之利益是訴訟前提，因應程序內之雙方當事人之狀況而決定，符合這個前提之特殊性在於要原告本身與對方（被告）同時符合。

簡言之：

訴之利益是指積極一方希望透過某特定之司法措施對一主觀權利獲得司法保護之利益，只要這是權利人實際實現該權利之唯一途徑則可。申言之，訴之利益因應司法保護之實際需要而定。

此外，可以指出：當確保積極一方有訴之利益時，亦同樣保證被告提出反對之利益。

B) 無訴之利益之後果；補正。

有一些學理，一如 Anselmo de Castro 教授之理論，認為欠缺訴之利益是不能補正的。

但欠缺這種利益會發生甚麼後果？

倘在起訴狀內無訴之利益之情況十分明顯，似乎欠缺任一種訴訟前提之法定制度適用：即初端駁回（《民事訴訟法典》第 394 條第 1 款 c 項）。

倘原告請求被告作出一個定期給付或將來之給付，但在《民事訴訟法典》第 393 條規定之情況以外提出此要求，債之不可要求履行之特性只在最後判決時才發現，但在調查及辯論後，只要債務已經到期，被告可被判作出給付，

在形成之訴及確認之訴裏，倘欠缺訴訟利益，結果是駁回對被告之起訴。原因是欠缺一個訴訟前提。

這種由 Antunes Varela 教授主張、得到 Anselmo Castro 教授支持之理解，但在學理上並不一致。

對我們來說，上文所述之欠缺前提之各種後果是真實的及比較適當的，故我們表示認同。

22. 法院

對程序當事人及訴訟前提作詳盡研究後，我們亦談及誰人可提起訴訟以及向誰人提起，現在讓我們了解訴訟法律關係之另一主體“法院”。

在這一節裏我們的注意力將集中在法院這個概念之界定方面，這個司法機關之結構及運作、及其所享有之權力。

對法院之研究分成兩個方面：

- (1) 一方面是關於司法組織——包括分析法院、其結構及職務、法院之內部，即其靜態一面；
- (2) 另一方面是研究法院之管轄權，決定審判權之分配：此為法院之外觀，即其動態一面，其運作方面。

在首章開始時，由於當時是探討民事訴訟法之近似內容，故選用簡握方式介紹。

關於法院管轄權，作為重要之訴訟前提之內容，在本文將繼續學習這點內容。

23. 司法組織

23.1. 作為主權機關之法院

(1) 與民事訴訟法近似之規範制度，兩者有不可分離之關連性。

作為例子：違反澳門《基本法》及《司法組織綱要》法所定之管轄權規則《民事訴訟法典》所定之各種後果。

(2) 法律依據：

主要是《澳門特別行政區基本法》及 12 月 20 日第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》。

(3) 範圍：

包括以分析角度研究作為司法機關之法院，還有擔任該機關職務之工作人員或實體。

(4) 法院之概念

根據 12 月 20 日第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》第 2 條及第 3 條規定法院是司法機關及唯一有權限行使審判職能的機關。

(5) 法院之職能（審判職能）

根據 12 月 20 日第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》第 4 條規定法院有職責確保維護權利及受法律保護的利益，遏止對法律的違反，以及解決公、私利益衝突。

(6) 法院之內部組成

擔任這些職務的基本上有法官（法院司法官）、檢察院人員（檢察院司法官）及司法人員。

司法官團之職責是按照法律掌理司法，其特點如下：

- 1 · 獨立性**——司法官在裁判上不受任何實體之命令及指引約束。在履行掌理司法公正之職務時，法官僅服從法律，但依法律執行上訴之裁判之義務則除外。
- 2 · 無須負責**——作為通則法官不須對其裁判之錯誤承擔民事及刑事及紀律責任（指通過合法之上訴而被糾正之不同司法決定）。僅在法律規定的情況下，方可就法院司法官因履行職務所作的行為而追究其民事、刑事或紀律責任。因上述所指因履行職務所作之行為而提起民事責任之求償之訴予則必須向作出行為之上一級法院提起。（12 月 20 日第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》第 36 條第 2 款及第 44 條第 4 款）。
- 3 · 不可移調性**（根據 12 月 20 日第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》第 5 條第 3 款規定。）而其免職只能根據中華人民共和國《澳門特別行政區基本法》第 87 條第 2 款及第 3 款規定為之。

在澳門特區，法官之任命是由一個獨立委員會之推薦，經行政長官任命而為

之《澳門特別行政區基本法》第 87 條規定。

亦值得指出載於《菲臘律例匯編》內關於法官之內容：“其職責應有耐性及平和地聽取當事人，低下層之人士、不幸之人士，要求救助之人。讓他們訴諸公正，避免他們得不到保護，要有公平及快捷之批示”（卷 I.1）¹⁸³。

23.2. 掌理司法之原則

- （1）獨立性：法院僅服從法律（《澳門特別行政區基本法》第 83 條及 12 月 20 日之第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》第 5 條）以加強既判案之公正無私及強制力。
- （2）法院在履行職責時，有權獲其他當局輔助。（12 月 20 日第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》第 7 條）。
- （3）法院的裁判對所有公共實體及私人實體均具有強制性，且優於其他當局的決定（12 月 20 日之第 9/1999 號法律通過之《司法組織綱要法》第 8 條第 2 款）。
- （4）所作之裁判須說明理由（12 月 20 日第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》第 8 條第 1 款）。
- （5）法院聽證之公開性（《司法組織綱要法》第 9 條）但依據訴訟法律的規定及必須作出保密之決定者除外。

掌理司法不能以秘密方式進行。司法公正應是透明。

23.3. 法院之組織

在本節內先以項目區分：常設法院（是根據法律（《司法組織綱要法》）而產生及組成的、其特色是長期存在。）及仲裁庭（是爲了審理某種爭議而成立之專門法庭）現在，讓我們研究澳門法院之級別。

結合《澳門特別行政區基本法》第 19 條、第 82 條至第 94 條及第 143 條規定中華人民共和國澳門特別行政區“享有獨立的司法權，包括終審權”。

上述規定可見於 12 月 20 日第 9/1999 號法律通過之《司法組織綱要法》第 1 條第 1 款，而司法機關指法院及檢察院（同一法律第 2 條）。

根據（同一法律第 10 條）規定澳門特別行政區之法院設有第一審法院、中級法院及終審法院。第 2 款、第一審法院包括初級法院和行政法院。

而在初級法院中，根據（同一法律第 27 條第 1 款 1 項）規定初級法院，包括刑事起訴法庭，而該文第 2 款規定得在初級法院內設專門管轄法庭及特定管轄

¹⁸³ 《民事訴訟法典》第 311 至第 325 條之一套規範同保證法官審判公正無私（雖然某些規範亦適用於檢察院及司法文員）。

其基本意思十分清楚：因爲在某些實際情況裏，可以懷疑法官之公正及無私性，因爲法官亦是人，亦會出錯及受到影響，可能對其產生良知方面之難以解決之問題（例同時要兼顧法官之義務同家庭之義務）。爲此，法律有意避免法官在有條件衝突之情況下作出審判。法律區分兩種屬於嚴重及不同之情況：自行迴避及聲請迴避。

¹⁸⁸ Mortara 將管轄權定義爲給予每個常設法院或法庭之審判權之範圍。

法庭。

在澳門特別行政區第 9/1999 號法律第 27 條規定了法院分為若干等級，而在第一審法院是以合議庭或獨任庭方式運作（同一法律第 23 條第 1 款）。而各法院之管轄權分別在同一法律第 28 條至第 54 條規定。

有關檢察院之組織規則則載於同一法律第 55 條至第 66 條，而第 67 條至第 69 條為訴訟代理人及輔助人員之制度，在最後是《司法組織綱要法》及過渡規定。

24. 管轄權

24.1. 審判權及管轄權

審判權是作為一個整體及唯一個體去考慮賦予行使國家審判權之所有機關進行審判之權力。現在我們探討的管轄權是賦予各審判機關行使之部分之審判權，是其行使審判權之範圍¹⁸⁸。申言之，管轄權是國家對各個法院之間審判權分配之結果。

審判權這個概念作為一個整體，並相對其他權力或公權之職能而言，帶出了從外部界定法院活動之一個問題；而在國家主權之地域限制範圍內管轄權這個概念則帶出一個由不同法院對審判權作內部分配之一個問題¹⁸⁹。

此為學理之一般及常用之理論。一如我們下文所述般，但在某些情況下，實踐中揭開了這個過於單純之表面。

肯定的是：倘在每個國家法律秩序內只有一個法院，管轄權之問題則無需小心處理。在理論上，為了掌理司法，法律可將整個審判權交予一個法庭，不論案件之基本元素位於何處、其利益或複雜性為何。如此，該法院完全行使其審判職能（藉此宣示及實現法律），唯一可能提出之問題是關於審判權之限制，是指相對於其他國家之審判權而言，或相對於國家之其他職能而言，尤其是行政或執行職能。

然而，在實踐上，上述並不可行的，故出現審判權分配至不同之法院行使之問題。

倘在抽象上可認為無需將這個權分割，以致任何法院可審理任何案件，在行使審判職能時可作出任何行為。但可預計此會產生混亂，出現審判及裁判重複之危險，此定必打擊法律之肯定性、使法院之效益及聲譽受損。

為此，在有多個法院之法律秩序內，法律以抽象之標準劃分審判活動。

作為這種分配之結果，每個法院僅享有審判權之一部分——就是法律給予每個法庭（或每類法庭）之審判範圍——稱為管轄權。

由此可清楚知道：管轄權之概念有一個限制之意思：現代一般學者所持之意思（例 Chiovenda）是：“每個機關所享有之審判權皆受到一定限制。這些限制就構成其管轄權。每個法院之管轄權是其所行使之審判權之一部分。”

管轄權有別於審判權，一如部分有別於整體般，因為後者是指給予法院掌理司法之整體權力。

¹⁸⁹ 審判權與管轄權之劃分並非質之劃分，而是量之劃分。

審判權是整體考慮法院本身活動之外部界限，同行使其他職能之國家機關相對照。

管轄權是各法院之間相對之內部活動之界限。

關於每個法院之管轄權，源自審判職能整體劃分之一部分。一個法院只有權審理某些個案件，只要分配審判權之標準賦予法院審理有關案件之充足審判權力。

24.2. 管轄權前提之理由所在

管轄權是一個訴訟前提，即要求法院對案件之實質問題作出裁判之前必須具備之要件，確保裁判與現行制定法一致，亦保證裁判由更適合審理該沖突之法庭作出。為此，關於其他訴訟前提方面，應在每個具體個案裏加以認定審理，因應每件案。並非法院一個固有特性，而是一個前提——因應某個案件之要素而決定法院之地位角色。

這是指甚麼要素？

按照 Manuel de Andrade 教授引述之一個學理，法院之管轄權：“按爭議之客體決定”，通常指：“管轄權按原告之請求確定之”（見該教授所著之《民事訴訟概論》，第 91 頁）。

我們較喜歡稱為：決定法院之管轄權，應先考慮案件之內容、訴訟法律關係之標的，一如原告向法院所陳述般。所主張權利理由成立與否，存在與否，則同管轄管轄權無關。問題之實體性、案件之實質問題只可由有管轄權裁定該案件標的之法院審定（例要求返還一物，撤銷一合同等）。

但最重要是對訴之實質問題無管轄權之法院有權審定其本身之管轄權，是一種管轄權對管轄權之問題，此為源自一個原則（非直接載於法律內）：每一類法院相對於其他法院而言可以完全獨立地審定其本身之管轄權。

即表示每個法院在審定管轄權時並非由另一個法院輔助，倘自己無管轄權，必須依職權將案移送予有管轄權之法院（《民事訴訟法典》第 33 條第 1 款）。

但上述一切仍未指出管轄權這個前提之合理理由。

了解將一部分審判權給予一個法院時或一類院時，要考慮專門化這個因素。法學之進步產生了許多新之自主法律部門或法律知識專門化，導致了因應須要審理問題之性質而將審判權劃分，針對某類問題而成立專門法院。

亦應糾正審判之可能有之錯誤或瑕疵之需要必須將審判權劃分出等級。正確掌理司法公正之要求，亦為了完全保證公民之權利，確保公正無私及司法裁判之正確性，促成了設立可透過上訴途徑改正可能帶有之錯誤或瑕疵之裁判之法院。

利益值及案件複雜性成為劃定每個法院管轄權之理由，故應完全明白重大之利益值及複雜性較大之案件應由較高級之法院審理。

最重要的是考慮方便公民訴諸司法之重要性——亦是各個具有現代化憲法之國家之基本原則。

24.3. 新《民事訴訟法典》在管轄權上之分類**

*轉述 1999 年 10 月在澳門舉行之“民事訴訟法研討會” Dr^a Isabel Alexandre 所發表之論文。

24.3.1. 標的

由十月八日第 55/99/M 號法令核准的新《澳門民事訴訟法典》(下稱新法典)的第一卷(“訴訟”)第二編以法院為題,當中包括三章,由第 13 條至第 38 條條文組成。

有關此三章所規範的事宜——即“管轄權”、“管轄權之延伸及變更”,以及“管轄權之保障”,本文將嘗試按照法典的次序來逐一介紹。

鑑於時間有限,對新法典第一卷第二編中的所有事宜作詳盡探討是不可能的。然而,基於它們之間息息相關,我認為最好不要遺漏其中任何一項,不過這並不影響細述對前法典更改較多的事宜。

值得細述的包括前稱“國際管轄權”(現僅稱“澳門法院之管轄權”)以及無管轄權的事宜。

24.3.2. 新法典第一卷第二編的術語問題

新法典第一卷第二編中出現的第一個問題是其題目的廣泛性質,因為,就“法院”此名稱所可能概括的事宜的範圍極廣。前《民事訴訟法典》將現有的第一卷第二編中相應的規定集於獨立的一卷中(第二卷),稱為“管轄權及公正無私之保障”。而新法典第一卷第二編所針對的事宜,正如其標題明示,是廣義上的法院的管轄權,當中包括賦予管轄權的制度(在第一章內)、管轄權的延伸及變更(第二章內),以及管轄權之保障(包含於無管轄權以及管轄權之衝突的制度內:分別為第三章第一節及第二節)。此外,與前法典相比較下,僅公正無私的保障的制度被置於外,它被有系統地置於第二卷第二編的審級的附隨事項中(見第 311 條及隨後條文)。

新法典第一卷第二編中出現的最後一個問題配合隨後第三編之各種情節後為決定了當事人及其代理人組成了不同之訴訟前提之制度,因此有關之訴訟前提之制度亦導致產生了訴訟關係中另一主體——法院。在理解“法院”這一個詞的時候需要配合第一卷第二編所規範澳門法院管轄權之職責之制度,從而可以體現有關之制度是指澳門其中一個法院之管轄權。

24.3.3. 管轄權與司法組織——有關之問題已在上文提及,但不是研究第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》有關之條文。

無論該組織法的規劃如何,我們認為將民事管轄權給予初級法院會在新法典中引起極大回響,因為過往的所謂國際管轄權本身是《民事訴訟法典》中規定的事宜(因此原則上不會在《司法組織綱要法》中規定)。且假如排除了執行之訴的範疇,按照事宜及等級來賦予管轄權便不在新法典內規定。《司法組織綱要法》將民事管轄權分配予初級法院,可能影響到的事宜便會是:附隨問題及反訴問題的管轄權的延伸、聯合情況的管轄權、訴之合併、審定案件利益值的附隨事項裁判的後果、第三人異議的管轄權、請求之合併的管轄權、就執行程序作出之結算的附隨事項的管轄權、被執行人之異議的管轄權、有利於債權人的財產清算程序中的負債審定附文的管轄權等。

但需注意有關引用之條文並非源自澳門新《民事訴訟法典》。

《司法組織綱要法》可能影響到的另一事宜，是就無管轄權所作裁判之效力。因為在《司法組織綱要法》的規定下，由中級法院解決初級法院間的管轄權衝突，並由終審法院解決不同審級法院間的管轄權衝突，新法典第 34 條第 3 款及第 4 款內的制度（下文會再作探討），才有意義。因此，根據第 34 條第 2 款規定的就法院無管轄權所作裁判的效力的規則，即獲移送卷宗的法院亦得認為其本身無管轄權；在此情況下，應由具有解決有關管轄權衝突的管轄權的法院分廢止（即確定具管轄權的法院）。

《司法組織綱要法》還可能影響到新法典第 1203 條第 3 款及第 1205 條第 1 款內所載的規則。該等規則假設，對澳門以外法院或仲裁員作出的裁判的審查之訴，須向中級法院提起。假如《司法組織綱要法》排除該法院之管轄權，該等規則便喪失意義。

我們認為，即使新法典第 13 條及第 14 條所載有關規範管轄權之法律及轉移之禁止的規則，該等規定若置於《司法組織綱要法》內比在《民事訴訟法典》內更適當（第 13 條第 3 款所載規則除外）。但因為該等條文規定了程序本身的結構原則：例如第 13 條體現了訴訟經濟原則及維護原告正當利益原則，而第 14 條則體現了法院獨立原則，因此，將不可被《司法組織綱要法》修改。

不會受《司法組織綱要法》影響的事宜，是對司法見解之統一的管轄權，而唯一原因是該事宜已從法典中剔除。該事宜被剔除，是基於未來終審法院只有三名法官，因此只有在《民事訴訟法典》內，規範司法見解之統一（由終審法院院長的職能管轄權到相應上訴的步驟）的管轄權才有意義——假如早知（但實際上非如此）除了將會組成終審法院的三名法官外，按照司法組織法的規定，在審判該上訴時其他實體亦可參與。事實上，假如為了司法見解統一，在上訴時只有該二名作出裁判的法官參與，該上訴便會限於作為一項對剛作出的裁判重新審理的無用請求。

因此，不應為新法典完全沒有規範司法見解之統一的範疇而感驚訝。但即使對此不作規定減低了未來司法體系組織法產生矛盾的風險，亦仍然是法典中一個重要的缺漏（主要是考慮到《澳門刑事訴訟法典》規定了一個確定司法見解的非常上訴）：未來組織法不僅應確定具有統一司法見解管轄權的實體，還應確定該等實體的各自職能管轄權，以及相應上訴的步驟。

23.3.4.《基本法》之影響

特區《基本法》有三項規則或原則對處理有關法院的管轄權事宜有直接的影響。以下我們會作介紹。

23.3.4.1.第 19 條

其中第一項規則（基於其複雜性，在此不容細述），是澳門特別行政區的法院“除繼續保持澳門原有法律制度和原則對法院審判權所作的限制外，對澳門特別行政區所有的案件均有審判權”。具體講，澳門特別行政區法院對“國防、外交等國家行為無管轄權”，但在審理案件中遇有涉及該等行為的“事實問題”時，應取得行政長官的“證明文件”，該文件對法院有約束力，而行政長官在發出證明文

件前，須取得“中央人民政府的證明書”（《基本法》第 19 條）。

《基本法》第 19 條對新法典第 15 條至第 20 條條文的規範（該等規範相等於原法典有關國際管轄權的規則），沒有直接回響，但其中共通的（此方面稍後再述）是不純粹對與其他法律秩序有聯繫的訴訟的情況，為澳門法院的審判權設定限制。事實上，該規定不止於此，而是針對有關事宜，不管法律關係是否涉及多地區的性質，為澳門法院的審判職能的行使設定限制。這實際上是擔當了類似於按照事宜內部分配管轄權的規則的一個職能，雖然是在審判權方面有所擴展。

然而，《基本法》第 19 條相對於典型的國際管轄權的規則，有一個明顯差別：對審查一件涉及“國家行為”問題的案件，該條文似乎沒有禁止其在澳門提起，因為它僅規定該具體問題由特定實體裁判。從某種意義上講，該條文規定了一個類似新法典第 27 條規定的解決行政或刑事侵害問題的機制，雖然涉及“國家行為”的問題並非由一澳門法院，甚或非由一法院裁判。

23.3.4.2. 法院的獨立性

《基本法》中對澳門法院的管轄權方面構成直接影響的另一原則，是司法權獨立原則，當中包括終審權及賦予法院終審權（第 2 條、第 19 條、第 82 條及第 8.條）。

根據《基本法》第 83 條的規定，法院之獨立意味其祇服從法律，不受任何干涉。似乎，不受任何干涉只是指對澳門法院具審判權的事宜而言，因為《基本法》第 89 條規定：“法官不聽從任何命令或指示，但本法第 19 條第 3 款規定的情況除外”。

《基本法》起碼沒有明確地排除了在解決一項偶然涉及“國家行為”的審判權附隨事項的積極或消極衝突時的法院獨立原則。顯然，在此不容探討這複雜問題。我們只可強調一點，我們可得出澳門法院審議其本身管轄權的多少權限，換言之，對在澳門法律體系實踐訴訟程序充足原則的程序。

24.3.4.3. 不同審級的法院

《基本法》在法院管轄權事宜上具直接影響的第三項規則，是初級法院的存在。初級法院可根據需要設立若干專門法庭，並保留原刑事起訴法庭的制度。同時，亦有行政法院、中級法院和終審法院（第 84 條至第 86 條）。

《基本法》中的術語在新法典中反映出來；特別是就平常上訴，規定了可向中級法院（第 600 條及隨後條文）及終審法院（第 638 條及隨後條文）提起上訴。

《基本法》第 84 條至第 86 條規定了未來特區不存在明顯區別的法院體系。與葡國法律相反，在葡國，司法法院的體系與行政法院的體系各自獨立，而第 86 條所指的行政法院並不構成獨立體系的一部分。因此，在新法典中規範法院間的審判權衝突並無意義（原法典第 115 條第 1 款規定“（……）兩個或以上的不同種類的法院，對同一問題均自認具管轄權（……）”。由於未來特區不同活動的兩個或以上當局之間的審判權衝突，新法典僅處理管轄權衝突（第 35 條至第 38 條）。

鑑於特區沒有不同的法院體系，所以視乎案件原應由具特定管轄權（即與提

起訴訟的法院屬同一體系)的法院或不同體系的法院審理，而不可能按照事宜維持不同的無管轄權制度。這項在原法典第 102 條中規定的區分，在現法典中並不存在（見第 31 條第 1 款）。

24.3.5.澳門法院面對其他審判權時的管轄權

24.3.5.1.術語及法律依據

國際管轄權在新法典中沒有規定（這與原法典相反：第 65 條及第 65-A 條），因為此概念包括了一個澳門不能處分的面對其他國家的主權概念之部分。基於此，相等於原國際管轄權規則的新法典第 15 條至第 20 條，僅以“澳門法院之管轄權”來審議某些訴訟。

在上述條文中，我們可討論採用了管轄權而非審判權的概念的準確性，因為該等條文非為確定每一法院對審議特定訴訟的審判權範圍，而是為訴諸澳門法院整體以審理該等訴訟。此問題顯然很重要，事實上，被廢止之 3 月 2 日第 17/92/M 號法令《司法組織綱要法》第 48 條，就視此事宜為有關澳門法院的審判權的事宜處理。然而，一些實際原因不支持在法典中採用此術語：首先，因為此術語就管轄權之保障會要求區分無審判權與無管轄權（基於有關制度有很多共通方面：見第 31 條及第 32 條）；其次，是由於原法典採用國際“管轄權”此名稱；最後，因為在法典中規定一個有關無審判權的制度，可能產生難以銜接《基本法》第 19 條的困難，對於出現該條所指的“國家行為”時避免可能在適用方面造成混亂。

24.3.5.2.第 15 條至第 20 條的功能

新法典第 15 條至第 20 條的規定屬接納性規定，因為它們訂定了澳門法院整體對審議一項與不同法律秩序有關連的問題時具管轄權的條件。

但其功能比接納性規定更廣泛。有關問題可能僅與澳門法律秩序有關，而即使如此，在有關規定下澳門法院整體仍具管轄權審理該問題。在此，一個奇怪的現象是由於新法典廢除內部管轄權的規則而引起的：要證實訴訟的法院是否具管轄權，必須先確定澳門法院整體面對其他審判權時的管轄權（即確定“國際”管轄權），即使訴訟本身僅與澳門法律秩序有關連亦然。完成此步驟後，才可確定內部的管轄權。

24.3.5.3.檢定方法

澳門法院整體的管轄權對審理一項訴訟時，是根據適用已為人知的因果關係原則、互惠原則、必要性原則或一致性原則（見原法典第 65 條）來檢定的，雖然此最後原則須在澳門適用，但本地區不會出現（至少是這樣推定）司法轄區的區劃。

基本上，要根據地區來“變更”原有的管轄權分配規則（原法典第 73 條至第 89 條）；對於旨在僅賦予澳門法院審判權的規則。該等原有規則容許按照一致性原則檢定國際管轄權（原法典第 65 條第 1 款 a）項）；事實上，被廢止之 3 月 2 日第 17/92/M 號法令第 48 條已如此規定。然而，這些規則多數不能“變更”，因為與從舊法典第 65 條第 1 款 a)項字面上理解的相反，僅內部管轄權按地區分配：舊法典第 85 條第 3 款、第 87 條及第 88 條就屬此情況（分別是被告住所及居所

在外國的情況的管轄權，對多名被告的情況的管轄權，以及對上訴之審判的管轄權）。

24.3.5.4.具體檢定

具體地說，澳門法院面對其他審判權時的管轄權由以下方法檢定：

1. 如適用因果關係原則、互惠原則或必要性原則時，無論為哪種訴訟，澳門法院亦具管轄權（第 15 條）；
2. 如不適用上述任一原則，但有關訴訟是根據第 16 條所指的情況而提起的，則澳門法院具管轄權；
3. 如不適用上述任一原則，有關訴訟亦非根據第 16 條所指情況提起時，只要符合第 17 條的任一情況，澳門法院亦具管轄權（基本上第 17 條規定的是有關被告住所的傳統標準）。

對於保全程序、預先調查證據之措施以及訴訟以外之通知，亦適用賦予澳門法院管轄權的本身規則；因此，第 18 條規定，如可向澳門法院提起訴訟，或訴訟正在澳門法院待決，則亦得向澳門法院申請進行保全程序（第 326 條至第 368 條）及採取預行調查證據之措施（第 444 條、第 445 條及第 447 條）；而根據第 19 條的規定，得申請澳門法院向在澳門有居所或住所之應被通知人作出訴訟以外之通知（第 208 條至第 210 條）。

至於賦予澳門法院管轄權的特別規則，可見於第 1280 條至第 1284 條（有關船舶或其貨物之措施）。

最後，根據第 20 條的規定，澳門法院具專屬管轄權審理與在澳門之不動產之物權有關的訴訟，以及旨在宣告住所在澳門之法人破產或無償還能力的訴訟。而第 1200 條第 1 款 c) 項及第 1204 條規定，如違反第 20 條的規定者，不予確認澳門以外地方之法院或仲裁員所作之裁判（倘有關審查之請求向澳門法院提出的話）。

24.3.6.澳門法院的管轄權分配

新法典對內部管轄權的分配沒有作出規定，但就執行之訴的範疇，對等級事宜的管轄權有若干規定。

至於就地區而言的管轄權，上面提過的在澳門不存在司法轄區可解釋此不作為。

就事宜及等級（或訴訟形式）而言的管轄權，在《司法組織綱要法》內規範。在新法典內僅規範了因違反相應規則而造成的無管轄權，對此我們隨後便會提到。

24.3.7.執行事宜上之管轄權

執行事宜上之管轄權在新法典第 21 條至第 25 條中有所規範，相對於原法典的第 90 條至第 95 條而言，沒有重要更改。雖然此等規定被置於獨立的一節中，不代表前一節（有關管轄權的一般規定）的一般規定不適用之：為確定澳門法院面對其他審判權時的管轄權於提起訴訟時確定（第 13 條）或轉移之禁止（第 14 條）的規則如不適用於執行事宜上是說不通的，而上述的因果關係原則、互惠原

則或必要性原則（第 15 條）對執行事宜的可適用性亦未見有特別阻礙。

以下是就執行事宜上的內部管轄權的分配規則：

1. 以澳門法院所作之判決為依據之執行，由審判該案件之第一審法院管轄（第 21 條第 1 款）；
2. 以內部仲裁裁決（第 21 條第 1 款）、上級法院所作之裁判（第 22 條及第 23 條第 3 款）及澳門以外地方之法院或仲裁員所作之裁判（第 24 條）為依據之執行，由初級法院管轄。

法典第 25 條還有兩項以不同於上述名義為依據的賦予澳門法院整體就執行上的管轄權的規則。根據此項在《司法組織綱要法》中確定澳門法院具體管轄權的條文的規定，如屬交付一定物之執行或設有物之擔保之債務之執行，而該一定物或附有負擔之財產在澳門，則澳門法院具管轄權；此外，對有關債務應在澳門履行的其他執行的情況亦然。

24.3.8. 管轄權之延伸及變更

在管轄權之延伸及變更的一章中（第 26 條至第 29 條），新法典規定了對附隨問題、審理前之先決問題、反訴問題，以及排除及賦予審判權之協議等的管轄權。

與舊法典（第 100 條）相反，新法典不承認管轄權協議，此乃基於《司法組織綱要法》不會規定按利益值及地區分配予初級法院管轄權之前提。因此，只可影響該等管轄權分配的管轄權協議（見舊法典第 100 條第 1 款）便不具任何實際意義。

亦由於不存在按利益值及地區的分配予初級法院的管轄權，因為第 26 條第 2 款及第 28 條第 1 款現僅規定按事宜及等級的法院管轄權，而不須列明國際管轄權。

附隨問題及審理前之先決問題的制度與舊法典第 96 條及第 97 條相比基本上維持不變，在此不再贅述。

然而，就反訴問題則有重要更改。如審理該訴訟之法院不具管轄權審理該反訴，後果會是駁回對原告之反訴或將有關反訴之卷宗副本移送具管轄權之法院，視乎因反訴不能在澳門法院提出或有關反訴原應由仲裁庭審理（第 28 條第 2 款），抑或因有別於上述的原因以致反訴不能在審理該訴訟之法院提出（第 28 條第 3 款）。第 28 條第 2 款及第 3 款的制度，與對訴訟本身無管轄權的制度一致，我們會在下一點中探討。

將新法典第 29 條與原法典第 99 條相比較，可輕易察覺到審判權協議制度的差異，那就是更易選擇有管轄權的法院，以及審判權協議得以追溯生效（第 29 條第 1 款及第 2 款 e 項）。

24.3.9. 無管轄權之制度

24.3.9.1. 無管轄權之情況

第 30 條規定，如不得向澳門法院提起有關訴訟，或出現違反內部秩序分配管轄權之規則之情況，則法院無管轄權。在此規定中，無管轄權的概念，正如由

隨後條文所規劃的制度的推斷所得，不僅包括違反法律規則，還包括違反有關管轄權的協定規則：具體來說，規定的前部分不僅包括違反第 15 條及隨後條文的規定，還包括不履行排除審判權之協議（第 29 條）或案件原應由仲裁庭審理，因此，在這些情況下，有關訴訟不能在澳門法院提起。規範的後半部，則包括違反在內部秩序分配管轄權的規則（此等規則會在《司法組織綱要法》中確認），以及其他在法典本身中有關執行之訴的規則。

雖然上文提過，新法典沒有區分國際管轄權與澳門法院的內部管轄權（僅就管轄權而言）。但稍後我們將看到，當規範違反管轄權規則的後果時（即無管轄權），可假定該區分。

要強調的另一點，是新法典沒有區分絕對無管轄權及相對無管轄權（與舊法典相反：第 101 條及隨後條文，以及第 108 條及隨後條文），僅規定了無管轄權（第 30 條、第 139 條第 4 款、第 230 條第 1 款 a）項及第 413 條 a 項）。

有關解釋並不是真正以在澳門不存在司法轄區、因而難以審定按地區的相對管轄權方式此情況為基礎——因為在《司法組織綱要法》中，規定了按訴訟形式將管轄權分配予初級法院，案件原應由初級法院審理可統一一項相對的無管轄權；有關解釋傾向於該區別無多大實際意義。因為所謂的絕對無管轄權（通過依職權審理有關的瑕疵而作出初端駁回或駁回對被告的起訴）只有在一項不可在澳門提起的訴訟的情況下出現，使所謂的相對無管轄權最終保留予不遵守管轄權規定的其餘情況，正如我們將會見到，這些情況都有不同的制度。

24.3.9.2.共同制度

第 30 條至第 34 條有兩項適用於所有無管轄權的情況的共同規則：第 32 條有關對無管轄權作出審理之時刻的規則，以及第 34 條第 1 款有關無管轄權所作之裁判在該訴訟外之效力。

24.3.9.3.違反第 15 條至第 20 條之規則

第 33 條第 2 款前部分規定，如澳門法院無管轄權之情況是基於有關訴訟不可在澳門法院提起，則初端駁回起訴狀，或駁回對被告之起訴。

初端駁回起訴狀是為規范通常宣告訴訟程序（但亦補充適用於其他訴訟程序：第 372 條第 1 款及第 375 條第 1 款），第 394 條第 1 款 b 項又重新（或許無必要地）指出倘不遵守第 15 條及隨後數條的規定，須初端駁回起訴狀。另一方面，作為訴訟程序消滅的原因（第 229 條及第 230 條），規范了駁回對被告的起訴——第 230 條第 1 款 a 項指出，當法官裁定以法院無管轄權的抗辯理由成立，便駁回對被告的起訴——作為特定延訴抗辯理由成立的後果，法院無管轄權是一個例子（第 412 條第 2 款及第 413 條 a 項）。

以違反賦予澳門法院整體面對其他審判權時的管轄權的法定規則為依據的無管轄權，不取決於被告的爭辯；在訴訟程序中任何時刻，如就案件的實質仍未有確定判決，當事人得提出爭辯，指法院無管轄權，而法院亦應依職權提出其本身無管轄權（第 31 條第 1 款）。

24.3.9.4.違反排除審判權的協議

倘澳門法院無管轄權審理一項訴訟，是基於當事人根據第 29 條的規定，約定另一法院具管轄權，那麼唯一的後果便是駁回對被告的起訴（第 33 條第 2 款後半部分），因為僅被告得以違反排除審判權的協議為理由提出反對（第 31 條第 2 款及第 414 條），因此，不得由法官於作出初端批示時審理。

由於在此等情況下無管轄權的爭辯應在特定期間內提出（第 31 條第 2 款），其瑕疵得以補正。

24.3.9.5.案件原應由仲裁庭審理

正如違反排除審判權的協議的情況一樣，案件原應由仲裁庭審理的情況只可在特定期間內由被告提出爭辯（第 31 條第 2 款及第 414 條）。這樣，瑕疵亦得以補正，亦不存在對起訴狀的初端駁回（甚或第 397 條規定的補正批示；不只是因為沒有要補正的方面，亦因為此批示意味依職權審理起訴狀欠缺法定的要件）。其唯一後果是駁回對被告的起訴（第 33 條第 2 款後半部），但就帶出了一個問題，那就是要知道此裁判是否約束仲裁庭確認其本身管轄權。

按照第 31 條第 1 款規定，在訴訟程序中任何時刻，「案件原應由必要仲裁庭審理」的爭辯可由當事人提出，並應由法院依職權提出其本身無管轄權。這樣，由第 31 條第 2 款及第 414 條中可清楚看到，被告須提出爭辯的情況亦只有在案件原應由自願仲裁庭審理時出現。但無論案件原應由必要仲裁庭抑或是自願仲裁庭審理，其效力是一致的：根據第 33 條第 2 款後半部分的規定，駁回對被告之起訴。

24.3.9.6.違反內部管轄權之規則

當某澳門法庭對訴訟無管轄權是由於根據《司法組織綱要法》或法典本身的規定，該訴訟應在另一澳門法院提起時，其後果必然是將卷宗移交該法院，無論發現欠缺前提是在作出初端批示時或其後亦然（第 33 條第 1 款）。瑕疵可在訴訟中任何時刻由任一方當事人提出爭議，並應由法院依職權提出（第 31 條第 1 款）。

即使是在違反按事宜或等級的管轄權規則的情況下，將卷宗移送有管轄權的法院（這些情況在舊法典中規範初端駁回或駁回對被告之起訴的情況：第 101 條、第 105 條及第 474 條第 1 款 b 項）是有根據的，因為澳門地區範圍面積較小。

無論如何，須注意獲移送卷宗的法院本身的獨立性：它沒有理由受被視為無管轄權的法院的裁判所約束，即使該法院甚至可能是等級較低的。就此問題，第 34 條第 2 款至第 4 款具備一個頗為複雜的制度作回應。

對該制度的理解引伸了兩種不同情況：

1. 對無管轄權之裁判未提起平常上訴；
2. 對無管轄權之裁判已提起平常上訴。

請注意，根據第 583 條第 2 款 a 項的規定，不論因訴訟及因所作裁判而喪失利益值為何，只要不違反第 34 條第 3 款的規定，均得以違反管轄權的規則為依據提起上訴。向中級法院提起的上訴具中止效力（第 601 條第 1 款 b 項、第 603 條及第 607 條第 1 款），而向終審法院提起的上訴則僅有移審效力（第 643 條第 1 款）。

倘沒有對無管轄權的裁判提起平常上訴，第 34 條第 2 款規定“獲移送卷宗的法院得依職權提出其本身無管轄權；如其宣告本身無管轄權，則適用管轄權衝突制度”。

倘對無管轄權的裁判提起了平常上訴，便應視乎中級法院裁定因某案件屬另一初級法院，抑或是因某案件屬上級法院管轄，故該初級法院無管轄權審理該案件，而適用第 34 條第 3 款或第 4 款的規定。

第 34 條第 3 款規定，如中級法院裁定因某案件屬另一初級法院管轄，故某一初級法院無管轄權時，對被宣告具管轄權的法院是有約束力的，且不可對此裁判提起平常上訴。前面我們已提過此制度所持的理由：由於按照《司法組織綱要法》的規定，中級法院對審理初級法院間的管轄權衝突具管轄權，在平常上訴中就管轄權分配的問題所作的裁判應亦具約束力及決定性。

另一方面，第 34 條第 4 款規定，如中級法院裁定因某案件屬上級法院管轄，故某一初級法院無管轄權時，則終審法院在其後或有的上訴中須裁定何法院具管轄權，此裁判對被宣告具管轄權的法院有約束力。前面我們亦已提過此制度所持的理由：由於按照《司法組織綱要法》的規定，終審法院具管轄權解決初級法院與中級法院間的管轄權衝突，因此其在平常上訴中就此等法院間的管轄權分配問題的裁判亦應具約束力及決定性。

然而，第 34 條沒有規定，在向中級法院提起的訴訟中（例如由澳門以外法院或仲裁員提起的對裁判審查的訴訟），如中級法院被認為對該訴訟無管轄權，可將卷宗移送初級法院並對此裁判提起平常上訴。在此情況下，我認為應類推適用第 34 條第 4 款內的規定，因為理由是同樣的：終審法院具管轄權解決初級法院與中級法院間的管轄權衝突。

24.3.10.管轄權之衝突

新法典第 35 條至第 38 條對管轄權衝突有所規範。正如上文提過，與舊法典相反，新法典沒有處理審判權衝突，亦沒有規定哪一法院具管轄權解決管轄權或審判權衝突。它只規定了管轄權衝突的概念、規範有關程序步驟及指出這些步驟可適用的情況。

在程序方面，須強調新法典的簡化目標：與前法律相反，（在前法律中，具管轄權解決衝突的法院與衝突中的當局之間的通訊是透過書信、掛號信或郵局的雙掛號公函為之（舊法典第 118 條及第 119 條），在新法典中只靠公函通訊（第 37 條第 2 款及第 3 款）。受到此簡化目標的影響，還須強調現時具管轄權審理衝突的上級法院本身可對人證進行調查，並根據抗告本身的規則而不提及對衝突的審判（新法典第 37 條第 4 款及原法典第 120 條第 2 條）。*

24.4. 管轄權之延伸

24.4.1. 概念

總的來說法院決定對某個案件管轄權是透過適用澳門 12 月 20 日第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》配合澳門《民事訴訟法典》第 13 至第 34 條之規則而

* 轉述 Dr^a Isabel Alexandre 所發表之論文終結。

進行。假如，某些案件已被分發至有管轄權之法院，即使該案其中之部分問題之管轄權是屬於其他法院，在正常之情況下亦不會終止各個法院之管轄權。

為此，我們正面對管轄權延伸之訴訟程序現象（參閱《民事訴訟法典》第 1 卷第 2 章之標題）。

為此，可以發生：在程序進行期間，構成程序標的之訴受到其他問題之擾亂，而這些問題列入程序內，且需作出解決，以便程序可如常進行及達到如期之目的。

符合這些法定條件後，法院需將其管轄權延伸至其他問題方面：倘無這種連繫，法院理應無管轄。

24.4.2. 合理理由

第 26、27 及第 28 條所述者為管轄權延伸之假設情況，屬於上述規則之例外情況。

我們現在分析這些情況。

A）《民事訴訟法典》第 26 條所定附隨事項

這裏包括所有法律定為訴訟之“附隨事項”之情況——見規範於《民事訴訟法典》第 244 至第 325 條，還有其他無明文規定、但具有相同性質之附隨事項²¹³。

所有相對於訴訟標的而言具有工具性、次要或從屬性質之問題，且需先解決這些問題法院方能解決案件之實體問題，皆應視為附隨事項。（見《民事訴訟法典》中之各種附隨事項。）

在第 26 條第 1 款亦都提及“被告作為防禦方法所提出之問題”。

讓我們研究這一個例子（因無相關規範地域管轄權之制度在澳門是不適用的，但在葡國是有的。）。

A 訴 B，要求履行一債務；起訴地點為應履行債務之地（葡國《民事訴訟法典》第 74 條）。

B 以合同無效為抗辯，倘獨立審理合同之問題，應在 B 住所地法院進行，但履行債務地之法院有管轄權乃因延伸規則所至。

然而對於僅因爭議人之利益而延伸法院管轄權之延伸範圍，法律作出了限制，對附隨事項作出之裁判只具形式既判案之價值。但只有其中一方當事人申請裁判有超出訴訟本身之效力，而審理該訴訟之法院具此管轄權即可以適用。

B）《民事訴訟法典》第 27 條所定之先決問題

受理一案件之標的往往取決於對程序中一個問題所作出之裁判，而該問題同將來對案件作出之判決又有關連，例屬於一個有刑事或行政管轄權法院內之問題。

假設在一宗提交帳目之訴裏（特別程序——見規範在《民事訴訟法典》第 879 至 889 條），其中一方聲稱對方要求之某份文件是被對方竊取而得。知道有否欺詐盜竊文件之問題是一個受理訴訟事件之先決問題，為此乃刑事法院之管轄。

第 27 條確定了法院對於先決問題之立場。但並非是指全部之先決問題，僅

²¹³ Alberto dos Reis 持這種見解——見《民事訴訟註釋》，第一冊，第 236 頁。

是一個法院相對於另一類審判權之管轄。面對這些先決問題，法官可做些什麼²¹⁵？

這條條文容許法官：

1. 中止訴訟關係直至（先決）問題被另一個有管轄權之法院解決為止（在此問題下，明顯是管轄權之延伸）。
2. 法官自行對先決問題作出決定，只要符合第 27 條第 2 款所述之情況，中止則不發生效果。

在此情況下，主審之法官藉管轄權之延伸受理先決問題。但所作之裁判不在案件以外發生效果，且不形成實質既判案。

我們舉另一例子加以說明：

對由一場火災引起之損害提起一針對保險公司之賠償之訴，該公司拒絕支付賠償，辯稱該火災屬於縱火，此情況免除其責任。

先決問題乃要知道是否有縱火之犯罪行為。

C) 《民事訴訟法典》第 28 條所定之約定問題

訴訟法容許在某些情況下被告可在其答辯狀內提出其對原告之獨立請求——此請求稱為反訴請求（參閱《民事訴訟法典》第 419 條）。

由於這些反訴請求，訴之標的擴大了，在請求內加了一個與原告之請求有關連之問題。

第 28 條之結果部分及有下述之意思：在澳門之法院提起之訴受理有管轄權之反訴請求，此引致其管轄權延伸或擴展，亦有因管轄權之原因而不能提起反訴，必須獨立提起請求的，為此不能向澳門法院提起有關之請求或另一原應由仲裁庭審理之案件（參閱《民事訴訟法典》第 28 條第 2 款）。

24.5. 管轄權規則之變更

24.5.1. 概念

在《民事訴訟法典》中考慮掌握“管轄權之變更”之情況應從其職責開始及體現在給予一法院決定某個問題之管轄權，倘按訴訟法律及澳門之組織法律之規定，理應無決定該問題之管轄權。

在實踐方面，我們可以指出：管轄權變更之概念有別於延伸之概念，因為在後述情況下，是原告已向有管轄權之法院提起請求（即已存在一訴），基於這種連繫，這個法院將其管轄權擴展至同請求有關之問題；而在變更之情況下，（法律）直接原始地將管轄權授予一法院以審理某個案件，但通常他無這方面之管轄權。

Antunes Varela 教授認為：這種變更管轄權之情況比延伸更為深入²¹⁷。

我們分析兩個法律預計變更之情況。

²¹⁵ 對第 97 條來說，此並非先決問題，按照 1979 年 6 月 28 日之最高法院合議庭裁判——此為屬於勞動法院管轄之案件。此案在 Antunes Varela 教授在其《訴訟法用書》中第 221 頁有引述。

在葡萄牙，勞動法院是特別管轄法院之一類，一如刑事法院般（12 月 23 日第 38/87 號法律）。

²¹⁷ 見 Antunes Varela 教授《民事訴訟手冊》第二版，第 223 頁。

24.5.2. 國際管轄權規則之變更

這類約定變更見規範在《民事訴訟法典》第 29 條。

其中規定了變更澳門法院管轄權規則之兩類情況：

- a) 限制澳門之法院管轄權之約定，將該管轄權授予非澳門之法院，但按第 15 條至第 19 條之一般規則葡萄牙法院理應有此管轄權（管轄之限制性協定）。
- b) 授予澳門法院有管轄權，但按一般規則，它無這方面之管轄權（此為授予管轄之協定，法院管轄之延伸協定，或解除管轄法院之協定）。

要這些協定有效，應符合法律所列出之要件——我們可以將其分類為：

- 1- 形式要件及
- 2- 實質要件。

形式要件：

- (1) 協定或約定之形式。這個協定應符合與其相連之合同之形式，即債源，應具有書面形式（即使附屬合同以口頭方式訂立亦一樣）或經書面確認——《民事訴訟法典》第 29 條第 3 款 e 項。

- (2) 須明確指出何地之法院具管轄權

實質要件為第 29 條第 3 款 b 及 c 項所述之要件。

——b 項被指定之法院所在地之法律接受此為有管轄權之法院；

——c 項該指定符合雙方當事人之重大利益，或符合一方當事人之重大利益，且不會對另一方引致嚴重不便；

——a 項涉及可處分權利之爭議；

——並不屬於《民事訴訟法典》第 20 條所規範之問題

24.5.3. 違反管轄權之規則：無管轄權²²⁰

管轄權之規範為一套不得違反管轄權之規則。

只要當事人不履行該約定，訴訟法規定了罰則，這些懲罰性機制乃針對不遵守而設定之一種預防方法。即對違反管轄權規則之情況而定之罰則乃制止違反法律之行爲，亦是要求遵守這些規定之一種謹慎態度。

為此，法律為此目的而訂立之一套措施稱為管轄權之保障（《民事訴訟法典》第 30 至第 34 條）。

上文已指出了法律沒有容許當事人排除管轄權之規則（《民事訴訟法典》第 15 至第 19 條），亦有不能排除之規則（《民事訴訟法典》第 20 條）。

因為這種雙向因素，亦應對無遵守管轄權規則之性質而產生不同之後果。

24.6.1. 無管轄權

我們正面對受《民事訴訟法典》第 30 條至第 34 條所規範之一個程序瑕疵。

要有系統地研究無管轄權之懲罰，應區分下述幾個方面：

- a) 誰人可以及應該提出無管轄權之問題（第 31 條）。

²²⁰ “法院無管轄權是指對某件案件法院無作出審判之資格，因為決定管轄權之標準無給予該法院作出審理之充足尺度”——見 Miguel Teixeira de Sousa 著之《普通法院之宣告之訴之管轄》，Lex,里斯本，1994 年，第 125 頁。

- b) 至何時可提出此問題（第 31 條）。
- c) 無管轄權之後果（第 33 條）。
- d) 就無管轄權所作裁判之效力（第 33 條）。

1- 關於第一方面，須強調：

- (1) 法院有義務依職權主張無管轄權（第 31 條第 1 款第二部分）。
- (2) 任一方當事人（原告或被告）有權能主張無管轄權；第 31 條第 1 款第一部分，第 2 款及第 3 款）。

2- 關於至何時可提出無管轄權之問題，受第 31 條管制，第 1 款規定之任何時候²²²，**第二款是一種例外情況。**

第 31 條在理解上應配合澳門《司法組織綱要法》之規範。

在不同之階段皆可審理無管轄權之問題：初端批示，清理批示階段前之提交訴辯書狀之階段，在清理批示內，在作出該批示後及最後判決前，在最後判決內，全部見規範在第 394 條第 1 款 b 項、第 429 條及第 32 條。

3- 關於法院無管轄權之裁判，第 34 條指出僅具形式既判力，倘屬於澳門法院之以外管轄權之規則，通則是無任何例外情況。

違反專屬管轄權協議

鑑於國家主權及公權力之範圍等要素，澳門之法院在判決為無管轄權之時，不能命令在澳門以外之法院援引澳門之程序，為此我們分析問題是不能適用《民事訴訟法典》第 33 條第 1 款中之後果，因為否則會引起衝突。

如屬第 33 條第 2 款之情況，則其後果為駁回對被告之起訴。

仲裁庭之先決

當證實雙方當事人曾作出生效及正當之仲裁協定後，應當將有關之訴訟建議交給有關之法庭審議。

這種情況跟上述之不同之處是有關之仲裁協議為由一個在澳門以外之經雙方交予仲裁之法院管轄。

假如為已經符合第 33 條第 2 款之情況，如有關之訴訟交予澳門特別行政區之常設法庭審理，則應當駁回對被告之起訴，。

24.7. 管轄之衝突²²⁵

訴訟法在第 35 條至第 38 條內正規範了這種事宜。

先界定兩個概念以便隨後描述解決這些衝突之程序。

管轄之衝突為指兩個或多個澳門之法院視已有管轄權或無管轄權審理某個案件《民事訴訟法典》第 35 條第 1 款。

²²² 法律所述之：“在程序之任何狀態下，只要無針對實體問題之已轉為確定之判決則可，容許我們，即使在向上一級法院上訴期間，仍可提出無管轄權之問題。

²²⁵ 關於這個內容，見我們著之《民事訴訟法典評語》——澳門現行文本（第 1 條至第 136 條）之第 115 條及續後數條。

但這一審理管轄權衝突之概念需要配合 12 月 20 日第 9/1999 號法律而得出適用之結果：第一審法院間之管轄權衝突（第 36 條第 13 項）以及中級法院與第一審法院間之管轄權衝突（第 44 條第 2 款第 14 項）。

在這兩種衝突內，有一種雙向性：可以是積極或消極；但只是公開宣告裁判已轉為確定方存在（第 35 條第 2 款）²²⁶。

誰人解決這種衝突？

如何解決？

關於澳門：需對 12 月 20 日第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》作適當配合。

雖然現時生效之《民事訴訟法典》（第 35 條至第 38 條）有關審理之衝突對比舊《民事訴訟法典》（第 115 條至第 121 條）——針對某一個案在不同形式之法院間或屬於國家活動不同單位間之有管轄權或無管轄權之條文——會發現為已經不存在，雖然如此，但 12 月 20 日第 9/1999 號法律《司法組織綱要法》之第 36 條第 14 項及第 44 條第 2 款第 15 項已規範了中級法院及終審法院具有上述問題之實質管轄權。

在研究《司法組織綱要法》之第 36 條第 14 項及第 44 條第 2 款第 15 項之結果後，得出有關之特徵是審理行政法院與行政、稅務或海關當局間的有管轄權或無管轄權之衝突為交由中級法院管轄；而審理中級法院與行政、稅務及海關當局間的管轄權衝突為交由終審法院管轄。

而《民事訴訟法典》第 36 條規範了有關對管轄權衝突之請求方式：同條第 1 款規定了任何具有正當性之當事人及檢察院得透過申請書申請；同條第 2 款則規範了有關之申請書之內容及呈交方式。

在第 37 條內規範審理衝突之程序及步驟，在解釋上無任何特別問題存在²²⁸。

未經分析《民事訴訟法典》第 38 條，我們不應視審判權及管轄衝突之問題已完滿解決，雖然其中所定條件限制作用不大。

除了當局或法院之間聲稱對某個案件有管轄權或無管轄權之衝突外（管轄或審判權之衝突），還有一種值得我們特別留意之現象，同我們所認識之衝突有關。

Carnelutti 稱此為可能存在之沖突；而 Alberto dos Reis 教授稱為潛在沖突。

只要同一訴訟案同時在不同法院內待決，但無提出有管轄權或無管轄權之問題。

由於無出現衝突，我們面對的是對一法律關係出現判決重複之情況。必須避免這種情況。第 38 條建議改正這種情況，容許透過第 36 條至第 37 條所指之程

²²⁶ 該條文之第 2 款引起下述考慮：“正是如此，因為決定（裁判）仍未確定，還可作出改變；倘在上訴方面解決了管轄權之問題，無需再提出衝突之問題。但是，將該條文與第 38 條目比較，法律制度似乎十分和諧，因為法律不會期待有兩個處於衝突之裁判，繼而引用解決衝突之程序，只需在超過一個以上法庭內有同一宗待決案，則有衝突存在。

²²⁸ 見我們著之《民事訴訟法典評話》——澳門現行文本（第 1 至第 136 條）第 206 頁，關於第 118 條之評註。

序提出衝突之問題，只要出現下述情況即可：

- (1) 同一訴訟在不同法院中待決，且提出無管轄權之抗辯及訴訟已繫屬之抗辯（*litispendência*）之期間已過（第 38 條 a 項）。
- (2) 同一訴訟在不同法院中待決，而其中一法院裁定本身具管轄權，且已不能向其餘法院提出無管轄權之抗辯及訴訟已繫屬之抗辯（第 38 條 b 項）。
- (3) 其中一法院裁定本身無管轄權，但已將有關卷宗移送予並非正在處理同一待決案件之他法院，且已不能向正在處理同一待決案件之另一法院提出無管轄權之抗辯及訴訟已繫屬之抗辯（第 38 條 c 項）。

訴訟行為

總論

25. 建立程序之理由

我們已知道民事訴訟程序乃法律程序，作為實行民事審判秩序之一個工具，即民事訴訟程序是受理以私法為基礎而提出之請求之工具，包括民事法及商法。我們亦已知道“processo”一字可有不同之意思，最通用的意思是指受法律規範之行爲邏輯及順序之連貫性，以產生某特定法律效果為目的。

亦就訴訟法律關係、其性質及結構之課題，探討其組成元素：

- (1) 程序之主觀要素：包括程序參加人或有關主體；
 - a) 一個公正無私及獨立之機關——法院
 - b) 提出請求之一方，促請該機關運作之原告或起訴人，而另一方為提出請求所針對之人——被告或被訴人；
- (2) 訴訟關係之標的或內容——請求及訴因概念；
- (3) 程序行爲，藉這些行爲實行程序之環節。

這些行爲彷彿如程序之各個原子，按照法院之規定一個接一個，一個整體之配件，以產生一個法律所定之結果。

訴訟程序行爲是順序與目的之一個法益，依此意思，是一種動態實況²³⁰。

現在我們建議探討的是一個關於行爲之總論——作為訴訟程序理論之一部分（繼訴訟法律關係之主體及標的之後），之後討論判決之問題——作為訴訟程序中最典型之行爲。

這個訴訟程序之理論必須配合澳門《民事訴訟法典》之規範為基點之法律制度作為出發點，尤其是第二卷第一篇，並結合其他分散在法典各處及其他輔助法規之相關規範，同時配合我們現行法律秩序之一般原則及總論而定²³¹。

在開始分析訴訟行爲之法定制度之一些特殊方面時，需界定組成這個現象之一般特點，在關於訴訟法律關係結構內我們已談及此點。我們嘗試透過一般特點而界定訴訟行爲之概念，之後我們將這些行爲分類，形成一套彼此間有共通特性之行爲。

26. 訴訟行爲之概念及一般特性

26.1 概念

很難界定訴訟行爲這個概念，為此，我們對於國內及國外訴訟法專家所提出

²²⁹ 在民事訴訟方面亦需區分事實與法律行爲：前者指產生受法律規範之效果，後者是指法律事實之一類，作為意願性之事實，而法律體系給予其某些法律效果。

肯定的是程序事實之影響比民事法內之事實之影響為細，但亦有重要之事實，例在程序進行間其中一個當事人死亡，故引致替代（《民事訴訟法典》第 301 條，或期間過去使程序手續失效）。

相反，訴訟行爲，自願法律事實對訴訟有特別之重要性。

²³⁰ 請緊記已在“Derecho Procesal Civil”掌握之概念：processo 一字源自拉丁 *procedere*，即走向前，為特定目的向某個方面邁進。

²³¹ 一如在民事法內關於法律上行爲及法律行爲理論般。

之不同表述形式感到驚奇。

分析這個詞，可以得出：

- 1- 行爲乃一個自願法律事實，這個事件之特徵是有人之意志介入（對法律產生重要性）；
- 2- 訴訟（程序）——因爲屬於程序環節或與其有直接聯繫，即使在程序以外作出亦然。按照西班牙權威教授 **Jaime Guasp** 之理論：行爲乃指創設或變更組成某個訴訟制度之法律關係之行爲²³²。

我們可以指出作爲訴訟行爲當中一些例子：判決《民事訴訟法典》第 106 條第 2 款將此行爲界定爲法官之行爲，且是結束程序之行爲；《民事訴訟法典》第 29 條所定之排除及賦予審判權之協議：這個協議雖然不屬於程序進行之行爲，但重要性很大。

有學者嘗試劃定訴訟行爲之概念，透過該概念指出那些非程序行爲；爲此可知，困難並沒有因而減少，然不能說這種區分並非無作出。故我們從未能嚴格區分這兩個概念之界限（兩者並無完全獨立之間隔）。

26.2 一般特性

我們可以指出組成程序之訴訟行爲之某些特點：

1. 屬於單方受領行爲，作爲當事人之行爲，對象是法官，而非對兩造當事人；
2. 作出這些行爲是一個負擔，而非法律義務，即爲作出這些行爲之人之利益，而非對方之利益（適用辯論原則及當事人自責原則）；
3. 屬於認知之表示，而非意志之表示，因爲所發生之效果，基於掌理司法公正之公共利益²³³，已預先定於程序法律內。

27. 訴訟行爲之分類

當開始建立一個訴訟行爲總論時，最重要的是將這些行爲分類。我們在上文已述及此點。

一如在其他事宜方面般，在這個內容上，關於所用之最佳標準方面，學者存有意見分歧。或者我們可以說：較稱當及爲學理接受之標準爲考慮作出行爲之主體。載於程序法，標題爲“行爲之總述”。其中規定“當事人之行爲”，“司法官之行爲”及“辦事處之行爲”（《民事訴訟法典》第 100 至第 116 條）。

但有人選擇採用考慮程序步驟之標準，將行爲區分爲開始之行爲，發展之行爲及結束之行爲²³⁴。

在德國學者之間出現另一種分類，例 **Goldschmidt** 之分類。其系統編排有一個原創特點：將當事人之行爲作一個次分類。區分 *actos de postulação* 及 *actos constitutivos*，前者包括請求及提供證據，後者包括協議或協定，管轄延伸之協定²³⁵。

²³² 見其作品《Derecho Procesal Civil》。

²³³ 關於這點，請記起關於訴訟法律關係所作之探討。

²³⁴ 此爲 **J. Guaspa** 所持之立場。

²³⁵ 這部分內容見載於《民事法典評話》，第二卷，作者爲 **Alberto dos Reis**，第 3 頁及續後；

這個問題極受爭議，倘某些標準欠缺其科學性，其他則太過抽象，與現實格格不入。

如上所述，分類之好處基本上是學術方面，將這些程序行為分類有不容爭議之實踐作出，因為任何程序法律皆需針對同類行為訂出一個法律制度。此對法律工作者特別重要。

澳門《民事訴訟法典》正包含這個思想，在其條文結構內，採用了一種分類：我們可稱為傳統之分類——考慮作出行為之主體，由此界定有關制度。

28. 訴訟行為之要件

我們建議制定之總論有一個核心：受訴訟法律規範，我們稱為訴訟行為之要件。

很易明白到訴訟行為，一如其他法律上之行為，須符合一系列要件，有效完整之條件及發生其正常效果之條件。

《民事訴訟法典》對此內容之系統編排順序是關於下述課題：

- 作出訴訟行為之形式（應如何作出這些行為）；
- 作出訴訟行為之時間（何時作出）；
- 作出訴訟行為之地點（應在何處作出）；
- 作出訴訟行為之主體（由誰人作出）；
- 作出訴訟行為之目的（為何作出）；
- 作出訴訟行為之無效。

現讓我們逐點分析。

28.1. 作出訴訟行為之形式

訴訟行為明顯為形式行為。不論作出行為之主體是誰（當事人、法院或行政辦事處），應按法定形式作出，視為更能達主目的之方法。為此，可以指“目的決定了形式”。

古代受過分之形式主義管制——體現現在一種形式之負擔，往往無實際效用，形式勝於實質，此為訴訟行為逐個徵稅、而司法文員可從中得到部分收入之理由所在。

一如上文所述般，首部葡萄牙《民事訴訟法典》就產在這個效果（於 1877 年開始生效，雖然相對於其他程序立法此代表一個很大之進步）。

相反，雖然今日訴訟行為需遵守一定形式，應遵從同訴訟快捷有密切連繫之訴訟經濟原則。

但訴訟經濟原則分成兩個方面。

A. 訴訟行為本身之經濟性

稱為行為**限制**之原則——載於《民事訴訟法典》第 87 條內，按其規定，只可以作有一定效益之行為，禁止無效用之行為。

B. 法定程序經濟性

訴訟行為應有更符合目的之形式。

還有由 Anselmo de Castro 教授所著 “Direito Processual Civil Declaratório” 之第 7 頁及續後。

這種稱當之形式應盡可能簡單（第 88 條第 1 款）。

倘法律明示規定一種較不簡單之司法行為，明顯地這條簡單化之條文不適用，此為規則之一種例外。

28.1.1. 《民事訴訟法典》第 89 及第 90 條規範在作出訴訟行為時所用之語言

從這些條文之每款中似乎可以清楚得出：

- (1) 第 1 款適用於所有司法行為（即使法律無區分）；
- (2) 第 2 款是規範如須參與訴訟程序之人不懂或不諳用以溝通之語言作出口頭聲明。

應委任一名翻譯（訴訟程序輔助人），而其介入僅限於進行即時傳譯這方面之所需。

假如需要使用非澳門正式語文（葡萄牙語及中文）須遵照第 90 條之規定提交文件以附於卷宗上。

關於這點，如有理由懷疑譯文是否恰當，有責任提交文件者附具（經認證之）譯本（第 90 條第 2 款）；（可查閱《公證法典》第 63 條）。

28.1.2. 還有規範訴訟行為形式之其他兩條規範：第 91 及第 92 條：後述條文似乎強調了：包合一個過渡適用之規定（程序法律在時間之適用），適用於訴訟行為之形式之法律為在作出時生效之法律（第 91 條第 1 款）。

這條規範同所採用之訴訟形式無關，訴訟形式以起訴時生效之法律為準（第 91 條第 2 款）。

28.2. 訴訟行為之時間，概述及例外

28.2.1. 《民事訴訟法典》第 93 條第 1 款規定作為通則為訴訟行為須在工作日且在非法院假期期間作出。

第 2 款列出了例外之情況：

- a) 傳喚；
- b) 通知；
- c) 為避免出現不可彌補之損害而作出之行為。（而並非指僅造成嚴重損害或難以彌補之作爲）：例如，提前作證及即使上述該段時間內作出這些行為亦屬適法。

28.2.2. 司法期間

如眾所知，時段包括兩個時間：開始及結束。

在司法方面，為了發生某個程序效果而訂定某個期限，其功能是保證：

一方面，快捷解決爭議之公共利益；

另一方面，保證當事人有主張及維護其權利所需之時間。

司法期間規範了訴訟行為之時段，故相對於實體期間而言，前者有其特點，因為屬於已向法院提起之訴訟內之行為。

可以由法律規定（學理稱此為法定期間）或由法官規定（此稱為狹意之司法期間）。

在後述情況下，可以發生：

- a) 法官有訂定期間之完全自由（自由裁量）；
- b) 法官僅有訂定期間之上限（標示活動）；
- c) 法官有訂定期間之下限限制（平等之標示活動）。

無作出規定期間之情況為適用第 103 條之規定。

28.2.3. 司法期間之特性：

- A) **連續性**（第 94 條）：不論任何手續，期間連續地進行；然而，屬上條第 1 款之情況則會導致中止計算。
- B) **期間之延長**（第 97 條）：應遵從法律所定之期間，但存在受限之延長，因為法定訴訟期間在法律規定之情況下得予延長（第 94 條第 1 款），或經雙方當事人之同意，期間得以延長，但只能以相同時間延長一次（第 94 條第 2 款）。

雖然司法期間連續地進行，第 94 條第 1 款規定了在某些日子內期間會中止。但這方面在葡國民訴改革上作出了不同之修改，而在澳門之民訴制度內，在法院假期期間，訴訟期間中止進行，但有關期間為六個月或六個月以上，或有關行為屬法律視為緊急之程序中須作出者除外。（第 94 條第 1 款）

28.2.4. 司法期間按照《民法典》第 272 條及第 290 條之一般規則計算：首日不計，當在第 272 條 c 項指出期間於最後一日之午夜十二時結束時，當然此不適用於司法期間，乃行政辦事處運作之時間¹⁰⁷。

關於期間之計算，我們有《民事訴訟法典》第 98 條，按其規定倘有中間期間，而行為期間為後一個，應僅以後者為準，彷彿只有一個期間。

28.2.5. 《民事訴訟法典》第 95 條規範司法期間之種類

- a) 同一規範第 2 款界定了中間期間，是為應作出行為之另一方之利益而設定一個休止間，容許在稍後作出有關行為。例《民事訴訟法典》第 532 條第 1 項所述之情況：訴訟之任一方當事人更換證人。

但中間期間可將另一個期間之起算延至稍後另一個時間，例第 403 條第 1 款所定之假設情況：答辯期之開始計算。

- b) 行為期間之目的是作出一程序行為，因為倘該期間消滅，作出這個行為之權利亦依事實而消滅（第 95 條第 3 款）。

這個期間之功能是強制當事人以一定節奏保證程序之快捷。

例為被告設定之答辯期屬於行為期間，期間過後不能答辯。

合理障礙第 96 條為一個與不可抗力相近之概念：指一個通常不可預見、非由當事人意志控制之事實，引致自己或代理人不能作出有關行為。必須屬於一種絕對及完全不能之情況。

似乎只因應每宗個案方能決定是否有合理障礙，由法院因應應作出之行為而審定。

另一方面，應在障礙理由終止時主張合理障礙，以避免期間過去之消滅效果。

¹⁰⁷ 修改者：有關時間之計算須配合 11 月 1 日法令第 73/99/M 號使用。

28.3. 訴訟行為之地點

如並無理由須在其他地方作出行為，原則上訴訟行為在法院內作出——見《民事訴訟法典》第 99 條第 2 款。

例起訴狀及申請書是交到法院辦事處；離婚案之和解及調解在法官辦公室內進行；審判在審判庭內進行。

此為法院之三個組成空間，最低限度功能上是互相連繫²³⁸。

第 2 款包括例外之情況：

(1) 首先，基於更佳利用行為之方便理由，強制要求在其他地方作出行為。

例在《民事訴訟法典》第 523 條（涉及有關問題之地方進行詢問），及第 797 條至第 801 條（之非司法變賣）。

在其他情況下，基於尊敬之理由，關於某些證人（擔任某個職位之人），法律容許在其住所或有關工作地點詢問（例《民事訴訟法典》第 525 條第 1 款所定之情況）。

(2) 最後，因為合理障礙而不適用該一般規則：因病引致不能到法院（第 528 條）。

28.4. 訴訟行為之主體

考慮到作出行為之主體，可將訴訟行為分成三大組別：

- 1 - 當事人之行為；
- 2 - 法院之行為——分成司法官之行為及辦事處之行為；及
- 3 - 訴訟輔助人之行為。

我們已經知道《民事訴訟法典》規範了訴訟行為係以有關主體為基礎，區分當事人之行為、司法官員之行為及辦事處之行為。

而對於最後所述之一組行為並無在法典內特別訂立一個制度。

《民事訴訟法典》第 100 條至第 116 條述及這個內容。

28.4.1. 當事人之行為

在這組行為內，我們知道法律再將其細分為：

- 申請與答覆（第 100 條第 1 款）；
- 訴辯書狀（第 100 條及第 101 條）；
- 陳述（第 102 條第 2 款）。

法典在多處規定中提及這類行為。

關於申請，法律並無在技術之層面視為有需要及界定之規範，但似乎應理解為在程序進行中向法官請求批准之一個書面表述，例，附加在程序中或進行一檢驗。

第 100 條第 1 款所述之答覆乃指這詞本身之意思，是指一份文件，藉此要求法院就某個事宜聽取當事人，就事宜發表其之意見，尤其是他造當事人之申請書在該事宜所採取之立場²³⁹。

²³⁸ 很久以前，在葡萄牙，法官辦法室與審訊室分別在不同之大廈內。

²³⁹ 作為程序行為，要求有一個回覆，理由在於對質原則，因為要就任一方之請求聽取另一方之

當辦事處收到申請書或回覆後，倘不知遞交文書者之身分，（第 100 條第 3 款），可向提交人要求其身份資料之證明。

之後第 102 條規範同由當事人提交申請書及回覆有關之事宜，尤其是強制提交副本（第 2 款）。

在訴辯書狀方面，訴訟法律在第 101 條第 1 及第 2 款訂定了一個定義，明確指出是訴訟程序之基本文書，必須為書面文書，通常有順序數字作標題，稱為分條縷述，藉此向法官界定爭議之標的：原告之請求、被告之防禦（辯護）及有關事實及法律之依據。

訴辯書狀要包括依據及結論部分（原告主張訴訟理由成立，而被告則認為不成立）。

關於陳述（亦是當事人之行為），《民事訴訟法典》在第 100 條及第 101 條內並無提及，似乎無意將這部分作自主化處理。但在其他規定²⁴¹內，則繼續談及這類行為，肯定的是這些行為有別於訴辯書狀，因為陳述基本上是證明及充實在訴辯書狀內所主張之理由，陳述僅概述式地指出事實及法律理由。

無論在第一審法院或上級法院皆可以有陳述書。

第 560 條提及關於法律事宜之書面陳述，彷彿當事人向法院提交之作為最後判決之建議書。

第 598 條同上訴事宜之陳述有關。

最後要注意第 103 條：它對由雙方當事人作出之訴訟行為設定一個一般性期間：10 日。

28.4.2. 司法官之行為

《民事訴訟法典》第 104 條至第 110 條規範這些行為，後述之條文關於檢察院之建議行為，其他則關於法官之行為。

同樣地新與舊之法典在關於系統編排、內容，以及這些法律規定之文本，有許多批評。

如此：

第 106 條第 1 款規則是一條組織或功能性規則，似乎這並非是適當的編排位置。關於這個掌理司法之義務（違反則觸犯拒絕公正罪）²⁴³，已載於 8 月 18 日之第 55/92/M 號法令第 4 條，正與新《民法典》第 7 條第 2 款所定之原則相配合。

而在《民事訴訟法典》第 106 條內談及司法官（而非其他人）之裁判行為，例訊問、勘驗等。

最後，內容之系統編排亦不足，因為僅列出這些裁判行為之部分要件、形式及實質要件（第 107 條及第 108 條），而在關於宣告之訴之形式一章內（第 562 條），除了形式及實質要件外，亦規定了法官判決之其他要件，就是判決；除了所定之批示之一般期間外（第 110 條），關於判決之期間之條文則放在很後之編

意見。

²⁴¹ 第一項為第 102 條第 2 款，以便要求副本。

²⁴³ 嚴重之情況可引致民事及刑事責任，還可有紀律違反。

排內：在第 561 條²⁴⁴。

亦將法官之行爲分成幾類——此源自法律之規定：批示（一般文書，自由裁量或自由及羈束行爲）；判決（獨任法官裁判之行爲）；合議庭裁判（合議庭之決議行爲）。

這種分別有很大重要性，法律針對法官之各種行爲規定了不同之制度，尤其是關於作出之期間²⁴⁵。

在《民事訴訟法典》第 110 條第 2 款內有一個適用於決定法官期間之補充規範，作為對單純事務性批示及其他批示與其他性質之批示之區分。

我們看看《民事訴訟法典》第 584 條規定不得對單純事務性之批示及行使自由裁量權而作出之批示提起上訴。

Jacinto Rodrigues 在其作品（第二卷，第 272 頁）中指出舊之法典：“法官作出之單純事務性批示，或具有純行政性質，或雖為司法行爲，但僅命令作出法律規定之行爲，以便程序能進行，依訴訟法之觀點，只有第二類行爲才重要”²⁴⁶。

我們認為單純事務性質之批示無對任一方當事人之訴訟權利及義務或在程序上引起之爭議作出裁判。

我們認為，不接受對這些批示提出上訴是為了依照法律確保程序之正常進行。

因此，例決定庭審期日及時間乃一般日常批示¹⁰⁸。

根據《民事訴訟法典》第 110 條第 2 款規定單純事務性批示，須於 5 日期間內作出。

按舊《民事訴訟法典》第 159 條第 2 款內 使用了“在當日”，而現行之民事訴訟法明白到需要更改。由於法官不必對這類決定（可自由變更）說明理由，故不發生既判案，立法者認為 5 日的時間足以作出這些行爲，亦可能是由於在適用舊法典之過程中而得出之經驗。

須強調指出：有別於 1876 年之《民事訴訟法典》及其他外國立法，對無遵守第 110 條第 2 款之期間並無訂立任何罰則。這種制度自由化是基於：當法律規定期間，這些期間從不會被遵守，故只是紙上之文字。

我們重述《民事訴訟法典》第 584 條之規定，以便看看法官之其他類別之行爲：在行使自由裁量權而作出之批示（亦不接受上訴）。

這種批示有別於單純事務性批示，屬於同當事人之權利及義務有關之決定，但由法官自由作出，即行使一個自由裁量權。

一如 Rodrigues Bastos 所述般，關於這些批示：“是非自有公論法律給予有管轄權之實體自由選擇作出之機會及針對具體情況之解決方案批示。有別於行使約

²⁴⁴ 見由 Jacinto Rodrigues Bastos 著之《民事訴訟法典之註釋》，第一冊。

²⁴⁵ 關於判決及批示之形式及實體要件，我們稍後學習，尤其是當我們學習訴訟行爲之莊嚴行：判決。

²⁴⁶ 由我們標示。

¹⁰⁸ 見引述之作品。

束權——在將法律意志適用在具體個案時，行為人應在指定期間內對請求作出表示，以及按法律所定之意思解決請求”。

作為行使自由裁量權而作出之司法行為之例子有：法院徵用資料、技術文件、圖則、相片、圖畫、物件（或發現真相所需之文件）（《民事訴訟法典》第 462 條）……，法院詢問無被提出作為證人之人，但承認該人知悉對裁判十分重要之事實（第 548 條第 1 款）。

“不應將自由裁量權與任意混淆”。

“自由裁量權之運用是為滿足某個目的，而這個目的就是賦予這個權力之理由所在，限制了自由裁量固有之自由，以致其欠缺影響行為之有效性”²⁴⁸。

這位最高法院法官之表述形式似乎正確，亦符合《民事訴訟法典》第 3 及第 5 條所定之原則，他提出：“當事人處分原則及自責原則，同時配合法官之主動權，以發現真相為目的（第 6 條第 3 款）、司法公正適時性（第 8 條第 1 款），必屬於合法性內容之行為”。

由法官在行使自由裁量權所作之批示無需附理由說明，亦不形成既判案，為此不可上訴（第 584 條）。應在 5 日或 10 日之一般期內作出這類行為，法律有特別規定則除外（第 110 條第 1 款第 2 款）。

28.4.3. 在結束學習司法官行為時我們看看檢察院之行為²⁴⁹。

在下述情況下檢察院可以介入民事訴訟：

- 1- 作為主要當事人，以代表澳門特別行政區、公眾、不確定人及未成年人，只要這些未成年人在案中是被告及無作出任何防禦，還有強制性遺產案；
- 2- 或作為輔助當事人——當不屬於任何上述情況及成為程序之利害當事人：
——市政機關或臨時市政機關；
——無行為能力人及失蹤人（倘已提出辯護）。

檢察院作出提議之一般期間載於《民事訴訟法典》第 110 條第 1 款及第 2 款：“10 日或 5 日（單純事務性批示及緊急事宜），法律設定其他期間則除外”。

這條規範僅針對檢察院之提議，對當事人無約束力，僅作為法官決定之一般性意見。但在檢察院介入才有這種意見。

倘檢察院為主要當事人，其行為受制於為當事人設定之期間，故亦應用第 103 條之補充規範。

28.4.4. 辦事處之行為²⁵¹

在結束對程序行為之系統研究之餘，因應作出之主體而分類值得看看辦事處之行為——規範在《民事訴訟法典》第 111 條至第 116 條及第 117 至第 125 條，在澳門之《民事訴訟法典》對此作出改革規範了辦事處之行為之“訴訟程序之公開及卷宗之查閱”。

²⁴⁸ 見引述之作品。

²⁴⁹ 此為在法院代表國家及維護民主合法性之機關。

²⁵¹ 請緊記：自 1987 年 2 月 9 日起，澳門擁有條關於自本身之法院辦事處之法律（2 月 9 日第 6/87/M 號法令，公布在第六期政府公執）。

再次，爲了教學上需要而將這些行爲分類，因應法律用語有困難存在並不採用原始及嚴謹之用語。

在第 111 至第 113 條內談及筆錄及書錄，但似乎無將這兩類行爲作區分。

由於無一個方法系統編排，故需閱畢組成這個分節之所有條文方能有條理地作一介紹。

然而，爲了盡可能跟隨法律用語，似乎應區分：

——一般行爲及

——法院辦事處特別行爲。

在第一類行爲中還可區分：

——紀錄或宣示行爲；

——證明及公布行爲。

在第二類行爲裏包括：

——分發；

——傳喚；

——通知。

紀錄或宣示行爲之目的是在程序內記錄當事人或法官之行爲，或發生之其他事件。

這裏包括筆錄、書錄、會議紀錄、附註、結論等。

在這些訴訟行爲中，我們突出筆錄與書錄——《民事訴訟法典》第 111 至第 113 條。

關於筆錄這個詞，值得忠告：除了這個在此所用之意思外（將所採取之措施紀錄在卷宗內），亦可用於指組成整個卷宗之一紙張（卷宗）²⁵³。

另外，書錄是一個程序行爲：卷宗負責之公務員跟進程序之進行。該詞適用於當事人意志之表示：捨棄書錄，自認書錄，或解書錄，認領書等。

程序法律確定作出這些行爲（第 112 至第 113 條）應遵守之要件，某些要件會限制其效力（例簽署）。

關於證明及公布之行爲，《民事訴訟法典》第 124 條提及發出證明書之義務。

但亦有例外之情況：其中程序公開原則受到限制，此難免反映在證明書之發出方面，故有所保留（第 124 條第 2 款）。

29. 特別行爲

以「特別行爲」標題、第 155 條及後續規定了下述三種行爲：

——分發；

——傳喚；

——通知。

我們暫不探討前兩種行爲，因爲在學習宣告之訴之通常程序之行進時，我們會知道有關內容。

²⁵³ 在第一個意思上，視乎是指一個卷宗或多於一個而使用單數或複數。在第二個意思上，則使用複數。

現似乎只值得強調：與通知一樣，傳喚是要求當事人及第三人參加程序之訴訟行為，或屬於傳達某些決定或其他事件之行為。

關於傳達之行為，受第 126 至第 138 條之規範，其中規定辦事處多種方式請求書、電話通知及命令狀，對每種形式皆詳細規定。

通知，內容見載於《民事訴訟法典》第 175 條第 2 款，目的是傳喚某人應訴或知悉對程序十分重要之某個事實，在第 1 款所定之使用傳喚以外之情況下，皆適用通知。

有兩類通知：

——在程序內，即從屬之通知行為；

——在程序以外，即訴訟以外通知，法律在第 208 至第 210 條內規定了有關形式手續。

30. 程序行為之無效²⁵⁴

30.1. 引言

《民事訴訟法典》第 139 至第 154 條界定訴訟行為無效之制度，即管制無遵守作出行為時要遵守之規範之後果。

然而以“行為之無效”為標題之分節，並非包含了全部內容，還需引用《民事訴訟法典》關於其他行為或瑕疵之其他規定，其中相當部分在上文我們已作了分析²⁵⁵，其他部分我們在稍後分析，即我們學習終局判決時（《民事訴訟法典》第 569 條及續後）²⁵⁶。

但肯定的是：訴訟行為要遵守特定之要件，是關於我們已分析之各個方面：形式、時間、地點……等。任何偏離法律規定而作出行為必引致不完全有效，視乎行為在整個程序所擔當之功能，其無效之幅度亦可大可小。

如此，從立法政策角度言之，有需要在兩種反向之趨勢之中選擇其中一種：強調只有完全嚴格地遵守法律規定之行為方為有效；另一個趨勢是：雖然行為是不規則地作出，但對實現程序目的有一定作用，則應挽救這些程序行為。

較可取之立場是在兩個反向之立場中找尋一個協調兩者之立場，因為任何極端立場會引致訴訟紛亂。

一如大家所知般，民事訴訟程序不能豁免對一定形式之遵守（作為其本身紀律之保證），但不應誇張至犧牲形式本身之作用。

《民事訴訟法典》在其條文內確立了這種協調立場，但趨向於以功利主義為主，某種程度是為了訴訟經濟原則。

30.2. 概念

²⁵⁴ 關於這個內容，見 Antunes Varela 教授之作品，第 387 至第 393 頁；還有 Manuel de Andrade 之作品，第 176 至第 184 頁；還有 Anselmo de Castro 之作品，第三冊。

²⁵⁵ 例見《民事訴訟法典》第 55 條：由無能力作出之行為無效，雖然而予補正。

²⁵⁶ 西班牙學者亦埋怨：民事訴訟法無對程序行為及其有效性作出一般性規故這個內容混亂及含糊——見 José San Martín 之作品：《Lecciones de Derecho Procesal》，Bilbao，1989 年，第 162 頁。

程序無效之概念有別於實體法之無效，即私法法律上行爲之無效²⁵⁷。

程序無效是一個形式性質之瑕疵，其概念源自《民事訴訟法典》第 201 條第 1 款之規範。

可有下列三類瑕疵：

1. 作出被法律禁止之行爲；
2. 法律所規定之行爲或形式之不作為；
3. 作出一個由法律強制規定或容許之行爲，但無遵守所要求之形式手續。

只有法律規定爲無效，或不規則性對案之評定或裁判有影響才有無效。

可以明白到：程序行爲之目的，除了是爲了審定實體問題外，亦是爲了在各個程序階段裏實行一連串活動：起訴、舉證、辯論及決定（工具目的），只有因應每宗個案，發現所作出之行爲並不符合有關目的方視爲無效。

亦可知：引致程序行爲無效所用之尺度會引致程序本身無效或部分無效。故有第 139 條第 1 款，第 140 條及第 145 條之規範。

這些見解容許我們明白：“訴訟行爲無效之積極規定（以形式程序性原則爲啓發思想）與私法或行政法行爲無效作區分之重要性。爲此，訴訟行爲無效之法律制度應僅在法典內找尋，不能採用法典以外之規範，因爲這些規範是基於不同性質之活動，而受其他方面需要之影響”²⁵⁸。

30.3. 無效之種類與有關法律制度

從“行爲之無效”爲標題之《民事訴訟法典》之規範中（第 139 至第 154 條）中可得出下述結論：程序無效有兩大組別：

- （1）一方面我們有一級無效，或稱爲主級無效，在法律上有特別之規定，按嚴重性進行等級排列，即在程序內其效果之幅度而排列：

- 1- 起訴狀不當（第 139 條）；
- 2- 無傳喚被告或檢察院——當後者應作爲主要當事人而參加時（第 146 條）；
- 3- 程序形式錯誤（第 145 條）；

（2）另一方面，我們有二級無效或稱爲次級無效，法律僅在第 147 條概括地提及，指法律規定對案件裁判造成影響之無效。

學理及判例視爲屬於這類無效之例子有：

- I. 由獨任法官審理事實事宜，但理應由合議庭審理；
- II. 無通知將答辯狀或反答辯狀；
- III. 無將提交之文書通知另一方；
- IV. 第二次召集當事人進行調解²⁶⁰；
- V. 對每個事實疑問聽取超過法律容許之證人數目（參閱 1969 年 6 月 20 日之里斯本中級法院之合議庭裁判）。

²⁵⁷ 一如 Antunes Varela 教授所述般見《民事訴訟手冊》第 387 頁：“法律行爲無效乃以行爲組成要素之內在本質之瑕疵爲基礎，是作出行爲之前或作出時之瑕疵。”

²⁵⁸ 見 Anselmo de Castro 教授，“obra e local citados”，第 104 頁。

²⁶⁰ 這些例子可見 Antunes Varela 教授《民事訴訟手冊》之作品，第 391 頁。

對於這兩類無效，《民事訴訟法典》定立了有關制度，對次級無效之後果訂立了一般性規則，關於主級無效則訂立了特別規則。

受訴訟經濟原則啓發之第 147 條第 2 款及第 3 款：

- 對一個程序行為之撤銷影響到被撤銷續後之行為要素，因為程序是有組織連貫之一連串行為第 147 條第 2 款。
- 應利用無效行為所有之有效益，除非行為之瑕疵阻止這種效果之發生；
- 倘期間已過，不能重新作出無效行為，除非更新對另一方當事人有利，而另一方當事人在出現無效方面並無責任存在第 154 條。

這類無效原則上不被法官依職權認定（第 148 條），引致無效之一方當事人，或其曾明示或默示地放棄主張該無效之一方，不得主張（第 149 條）。只可由有意遵守程序之利害關係方或重覆作出有瑕疵之行為之一方主張（第 149 條第 1 款）。

只要有人提出異議，**次級無效**應由案件法官評審（第 152 條第 3 款）²⁶¹。

程序法律還規定了關於**主級無效**之特別規則。法院依職權認定，除非已被補正。

現在我們看法律所述之四類**主級無效行為**：

一、起訴狀不當（第 139 條）

第 139 條第 2 款界定了不當之效果，當我們分析宣告之訴之首份訴辯書狀時已作了詳細分析。

我們知道：當法官認定不當後，會引致初端駁回（按第 394 條第 1 款 a 項），繼而使訴訟關係消滅。我們亦知道這個解決方案之理由在於訴訟經濟之基本原則，我們亦學習了其他情況：雖然起訴狀有一些不規則或不足，法官可邀請原告將該書狀糾正或補充（因應各種情況），同時指定提交新書狀之期間（第 397 條第 1 及第 2 款）。

現在，我們將注意力集中在法律為這種訴訟瑕疵所定之制度，尤其是其後果之幅度。

第 139 條第 1 款很果斷地規定：整個程序無效，指使整件案之首份基本書狀不具效用²⁶²。

二，這是**主級無效**之最重要之一個，是因起訴狀不當所致。

B. 無傳喚被告或檢察院——當後者應作為主要當事人而參加。

按第 141 條之規定，屬於欠缺傳喚：

- a) 完全遺漏了該行為（第 1 款 a 項）；
- b) 傳喚另外一個（被傳喚人身份錯誤）（第 1 款 b 項）；

²⁶¹ 倘“次級無效”並非向法官提出異議之對象，而在程序裏已作出決定，爭執該有瑕疵行為之特有方法為上訴。一如 Alberto dos Reis 教授所主張般——見《民事訴訟法評話》，第 2 卷，第 507 頁：對於批示，提起上訴，對於無效，提出異議。”

係向上一級法院上訴，已異議則向案本身之法官提出。

²⁶² 見 Antunes Varela 教授《民事訴訟手冊》第 388 頁。

——不當使用公告傳喚（第 1 款 c 項）；無遵守同一條文第 2 款所列出之基本程序；在被傳喚人死亡後才被傳喚或應被傳喚之法人在消滅後才被傳喚（第 1 款 d 項）；又或須向本人傳喚時，應被傳喚之人因不可對其歸責之事實而未知悉傳喚行為（第 1 款 e 項）。

無傳喚是一個特別嚴重之瑕疵，因為違反了對質這個基本原則，故可作為再審之非常上訴之依據（《民事訴訟法典》第 653 條 f 項）。

值得指出：訴訟法律將傳喚與另外兩個近似概念相區分：傳喚無效及傳喚不規則性——載於第 144 條。

這兩個概念有別於“無傳喚”，因為前兩者體現在無先遵守基本或從屬程序。最後要留意第 142 條之規範：規定了因無傳喚被告或檢察院參加訴訟（但無立即主張其傳喚欠缺）而產生之無效之補正方式。